

Curso Examen de Grado

Módulo 4: Las Obligaciones

Presentación.

Módulo 4: Las Obligaciones

En este módulo se analiza el vínculo obligacional, independiente de la fuente que lo ha creado. Los alumnos deben conocer el concepto de obligación y sus elementos. Se estudiarán las distintas clasificaciones de las obligaciones, como también sus efectos, y lo qué ocurre en caso de su incumplimiento, analizando cada una de las posibilidades que tiene el acreedor. Finalmente se estudiarán los modos de extinguir las obligaciones, y el principal de todos, el pago, que es el efecto normal de las obligaciones.

Al final del módulo los alumnos deberán: a) conocer el concepto de obligación (derecho personal) y sus diferencias con los derechos reales; b) conocer las distintas clasificaciones de las obligaciones; c) comprender los efectos de las obligaciones, y las consecuencias del incumplimiento de las mismas; d) conocer, comprender e identificar cada uno de los modos de extinguir las obligaciones.

Los contenidos se presentan a través de las siguientes unidades:

- Unidad 1: Conceptos Generales.
- Unidad 2: Fuentes de las Obligaciones.
- Unidad 3: Clasificación de las Obligaciones.
- Unidad 4: Obligaciones Condicionales.
- Unidad 5: Efectos de las Obligaciones.
- Unidad 6: De la Evaluación de los Perjuicios.
- Unidad 7: Derechos Auxiliares del Acreedor.
- Unidad 8: De los Modos de Extinguir las Obligaciones.

Durante el desarrollo del módulo, los y las participantes dispondrán de los contenidos a través del sitio del curso. Accederán a recursos como PDF, sitios de interés, multimedios y bibliografía relacionada con los contenidos, así como también se propone la realización de actividades de evaluación para medir sus progresos.

Las consultas sobre contenidos, serán canalizadas a través del correo electrónico y el Foro de Debate.

Bien, iniciemos ahora nuestro aprendizaje, revisando el tema de los derechos reales y los derechos personales o créditos.

Unidad 1: Conceptos Generales.

Tema 1: Derechos reales y derechos personales o créditos.

El artículo 576 del CC dispone: **“Las cosas incorporales son derechos reales o personales”**. El artículo 577 del CC define como derecho real **“Aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”**. El artículo 578 del CC define al derecho personal como el **“Que sólo puede reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas”**.

Tema 2: Las nociones de derecho personal o crédito y obligación son correlativas.

No puede concebirse una sin la otra, en efecto, se hablará de **derecho personal o de obligación**, según la relación entre los sujetos se mire desde el punto de vista del acreedor, titular del crédito, o del deudor, obligado en esa relación, como lo deja en evidencia el artículo 578 del CC.

Tema 3: Diferencias entre derechos reales y personales.



La doctrina clásica contrapone los derechos reales a los personales, destacando varias diferencias:

- a) En los derechos reales existe una relación de persona a cosa; en cambio, en los derechos personales la relación es entre dos sujetos determinados: acreedor y deudor.
- b) En cuanto al contenido; los derechos reales confieren un poder jurídico inmediato sobre la cosa; en cambio, en los derechos personales, el titular, acreedor, sólo puede obtener el beneficio correspondiente mediante un acto del obligado, deudor.
- c) En cuanto a la forma de adquirir ambos tipos de derechos; los reales se adquieren por la concurrencia de un título y de un modo de adquirir; en cambio, en los derechos personales basta un título.
- d) Los derechos reales, se dice, son derechos absolutos, en cuanto al titular le corresponde una acción persecutoria y restitutoria, dirigida al reintegro de la cosa y ejercitable contra terceros; en cambio, los derechos personales son relativos porque sólo se pueden exigir del deudor.
- e) En lo relativo a su ejercicio; la diferencia presenta un doble aspecto: en los derechos reales, el hecho de recaer directamente sobre cosas hace que permitan una ilimitación que no puede darse en los derechos de obligaciones, habida cuenta de la presencia de la persona del deudor; y, en otro aspecto, los derechos reales se consolidan o reafirman a través de su

ejercicio, en contraste con los de obligaciones, en los que el ejercicio, mediante el cumplimiento o pago, lleva aparejada la extinción.

- f) En lo que se refiere a la contravención; los derechos reales pueden ser violados por cualquiera, no así los personales, que sólo pueden serlo por el deudor.
- g) Finalmente, se argumenta que los derechos reales sólo los puede crear la ley, *númerus clausus*, quedando inhibidas las partes de establecerlos, situación totalmente distinta a la de los derechos personales en que las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad pueden generar cualquier tipo de derecho personal, sin más limitación que la ley, el orden público o la moral, *númerus apertus*.

Tema 4: Críticas a la concepción clásica.

La concepción clásica que diferencia con nitidez **los derechos reales y personales es objeto de fuertes críticas**. No es cierto, se argumenta, que en los derechos reales exista un solo sujeto, su titular, pues también hay un sujeto pasivo constituido por la colectividad toda, en cuanto sus integrantes tienen la obligación de abstenerse de ejecutar cualquier acto que perturbe o impida el ejercicio del derecho. La situación es más clara todavía, se agrega, en los derechos reales limitados que constituyen desmembraciones del dominio, pues éstos derechos deben ejercerse sin perturbar el derecho de propiedad.

Tampoco es efectivo **que en los derechos reales exista una relación de persona a cosa**, pues siempre las relaciones jurídicas se dan entre personas, ya que todos los derechos y deberes conciernen a las personas y afectan su comportamiento. Sin embargo, no debe desconocerse que las cosas tienen un significado distinto en los derechos reales y personales: son fundamentales en los primeros en tanto que pueden faltar en ciertas obligaciones, como ocurre en las de hacer o no hacer. Las cosas sólo integran el objeto en las obligaciones de dar.

En cuanto a que los **derechos reales sean perpetuos y los personales eminentemente transitorios**, ello no constituye una diferencia esencial, desde que ello sólo sería así en el derecho de propiedad, y todavía con la salvedad de que existen propiedades transitorias como la propiedad fiduciaria, pero no lo es en algunos derechos reales, como el caso del usufructo, que siempre está sujeto a plazo.

Los **derechos reales son absolutos** en cuanto confieren a su titular un derecho de persecución, que se hace valer de un modo igual ante cualquiera. No ocurre lo mismo en los derechos personales que sólo se pueden ejercer respecto del deudor, de sus herederos y causahabientes.

Tema 5: Concepto de obligación.

Tradicionalmente se define la **obligación como el vínculo jurídico entre dos personas determinadas, deudor y acreedor, en virtud del cual el primero se encuentra en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo a favor del segundo**. Se agrega que enfocada desde el punto de vista del acreedor la obligación implica un crédito; para el deudor, supone una deuda.

- ➡ Que se trate de un vínculo jurídico significa que nos encontramos ante una relación protegida por el derecho objetivo, lo que hace la diferencia entre obligación y otros deberes, como los morales. De esta forma, si el deudor no cumple con su prestación puede ser compelido a hacerlo respondiendo con su patrimonio. El artículo 2465 del CC dispone: *“Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1618 del CC”*. De esta manera, cuando se contrae una obligación el deudor está respondiendo de su cumplimiento con todo su patrimonio, lo que se denomina derecho de prenda general, denominación inadecuada pues no hay propiamente un derecho de prenda, que es un derecho real.

Tradicionalmente las definiciones que la doctrina ha dado de la voz obligación tienen en común la subordinación del deudor hacia el acreedor, en un plano inclinado en que los derechos son todos del acreedor y los deberes corresponden todos al deudor. Agrega que la tendencia actual es a corregir este criterio absolutista, reconociéndose derechos al deudor y la imposición de deberes al acreedor. Ello lleva a definir a la obligación como una relación de derecho entre dos o más personas, en cuya virtud una parte tiene el deber jurídico de satisfacer una prestación determinada a favor de otra, a la vez que el derecho a que el poder del acreedor no se exceda en sus límites, y a ser liberada al tiempo del cumplimiento, y la otra parte la facultad de exigir tal prestación, aun coercitivamente, a la vez que el deber de no excederse en su pretensión.

Tema 6: Elementos constitutivos de la obligación.

Se discute en doctrina lo que constituye en esencia la obligación. Para algunos, **consiste en el deber del deudor de observar un determinado comportamiento frente al acreedor**. En este sentido toda obligación importa una restricción de la libertad del deudor, sin que pueda llegar a eliminarla, y una extensión de la libertad del acreedor, situación a la que se pondrá fin con el cumplimiento de la obligación. El incumplimiento **de la obligación genera un**

ilícito que hace nacer una nueva obligación: la de indemnizar, la que es una obligación nueva y no una fase de la precedente incumplida.

Frente a esta concepción se alza otra que pone el acento en la **responsabilidad del deudor**. De acuerdo a ella, lo que en esencia constituye la obligación, es el hecho que el patrimonio del deudor quede afecto a su cumplimiento. No es el deber lo esencial en la obligación, pues es posible su incumplimiento. Según esta tesis, el derecho de crédito recae sobre el patrimonio. Se puede observar que ambas concepciones se fundan en forma diferente. La primera, la del **deber**, se apoya en una base ética, persona o conducta, en tanto que la segunda, la de la **responsabilidad**, es una tesis elaborada sobre una base económica-patrimonio resultado. Las posiciones antitéticas en que se colocan las dos concepciones de la obligación examinadas, se superan a través de otras fórmulas: una es la cifrada en sostener que el concepto de la obligación, unitariamente entendido, comprende tanto el deber de prestación, deuda, como el sometimiento del patrimonio del deudor al derecho del acreedor, responsabilidad; y la otra es la que, rompiendo con la unidad conceptual de la obligación, proclama la existencia autónoma de la deuda y la responsabilidad, las cuales pueden, sí, yuxtaponerse, pero también presentarse independientemente. Desde un punto de vista práctico, puede ser importante la diferencia conceptual de que se viene tratando, para explicar, por ejemplo, la naturaleza de las obligaciones naturales. En ellas habría una deuda, deber, pero faltaría el elemento responsabilidad, desde que el acreedor no podría obtener el cumplimiento coactivo de ese deber en el patrimonio del deudor.

Tema 7: Sujetos de la obligación: acreedor y deudor.

Los sujetos de toda obligación son el **acreedor** y el **deudor**. El **acreedor que es el titular del derecho personal o crédito en virtud del cual puede exigir del deudor una determinada prestación. El deudor es quien debe dar, hacer o no hacer algo a favor del acreedor.**

En los contratos bilaterales, aquellos en que ambas partes se obligan recíprocamente, ambas partes tendrán el carácter de acreedoras y deudoras, de sus respectivos derechos y obligaciones. Los dos sujetos tienen que ser personas determinadas o a los menos determinables. Tanto el deudor como el acreedor pueden ser una o varias personas, de acuerdo al artículo 1438 del CC que dispone que cada parte de un contrato puede ser una o muchas personas. Frente a la concepción clásica que entiende la obligación como una relación de dos personas, acreedor y deudor, surgen doctrinas nuevas, que ven más bien una relación de patrimonios.



Tema 8: Del objeto de la obligación.

El objeto de la obligación es la prestación a que se obliga deudor. Consiste en un determinado comportamiento, positivo o negativo, que éste asume a favor del acreedor. De acuerdo al artículo 1438 del CC es lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. En las obligaciones de dar y en las de entregar, la cosa que debe darse o entregarse se incorpora al objeto de la obligación, de tal suerte que si el deudor no cumple, el acreedor va a perseguir justamente esa cosa.

Tema 9: Características de la prestación.

La prestación debe reunir las siguientes características:

- i. Debe ser física y jurídicamente posible.
- ii. Debe ser lícita.
- iii. Debe ser determinada o a lo menos determinable.

Que sea **posible quiere decir que se debe poder realizar**. En caso contrario nos encontramos ante la imposibilidad de la prestación, que puede ser absoluta, cuando la prestación no puede cumplirse bajo ningún respecto, o relativa, cuando objetivamente no hay imposibilidad pero para el deudor no es realizable la prestación. Que la **obligación sea lícita significa que no debe estar prohibida por la ley ni ser contraria a las buenas costumbres o al orden público**, conforme al tercer inciso del artículo 1461 del CC. Que **sea determinada importa decir que la prestación tiene que estar precisada, identificada**; y que sea determinable implica que pueda llegar a definirse sin necesidad de un nuevo acuerdo de las partes. El artículo 1461 del CC, refiriéndose a las obligaciones de dar o de entregar, nos dice que cuando lo que se debe es una cosa, la cantidad puede ser incierta, con tal que en el acto o contrato se fijen las reglas o datos que sirvan para determinarla.

Tema 10: Para que exista obligación ¿debe la prestación tener contenido patrimonial o pecuniario?



Respuesta

Así se entendía antiguamente. De esa forma, **el derecho de las obligaciones venía a ser esencialmente un derecho patrimonial**. Posteriormente se comienza a distinguir entre la prestación en sí y el interés del acreedor. La primera debe tener siempre un contenido patrimonial pues, en caso contrario, no se podría ejecutar la obligación en el patrimonio del deudor; no así el interés del acreedor que puede ser patrimonial, moral,

humanitario, científico o artístico. Si negamos la validez de una obligación por el hecho de faltarle contenido económico, limitamos arbitrariamente la autonomía de la voluntad, y dejamos sin juridicidad un posible elenco de deberes extrapatrimoniales capaces de cumplimiento voluntario.

Unidad 2: Fuentes de las Obligaciones.

Tema 1: Concepto.

Se han definido las fuentes de las obligaciones como los hechos jurídicos que dan nacimiento, modifican o extinguen las relaciones de derecho y las obligaciones. Otros dicen que se llaman fuentes de las obligaciones los

Tema 2: Clasificación.

El artículo 578 del CC al definir los derechos personales o créditos hace una primera distinción al expresar que éstos sólo pueden reclamarse de ciertas personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas. De esa forma, las fuentes serían un hecho del deudor y la ley. Pero el hecho de deudor cubre distintas hipótesis: primero, que importe un acuerdo de voluntades y sea un contrato; segundo, que sea un hecho voluntario, lícito y no convencional, o sea, un cuasicontrato; tercero, que constituya una conducta negligente que cause daño a otro, llamado cuasidelito civil; y, cuarto, que se trate de un hecho dolo que cause daño a otro, un delito civil.

El artículo 1437 del CC dispone: **“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos o cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padre e hijos de familia”.**

En resumen, pues, para nuestro CC las fuentes de las obligaciones son las siguientes:

- i. El contrato.
- ii. El cuasicontrato.
- iii. El delito.
- iv. El cuasidelito.
- v. La ley.

Tema 3: Críticas a la clasificación anterior.

Por una parte, la noción de cuasicontrato tiene detractores, pues o hay acuerdo de voluntades, y en ese caso hay contrato, o no lo hay y, en tal supuesto la obligación sólo puede tener su origen en la ley. Según una opinión muy generalizada, **sólo la voluntad y la ley pueden generar obligaciones**. En los cuasicontratos, los delitos o cuasidelitos, las obligaciones nacen porque así lo establece la ley. Sin embargo, siguiendo la misma lógica, habría que concluir que también en el caso de los contratos, éstos generarían obligaciones, porque así lo establece la ley, con lo que las fuentes quedarían reducidas exclusivamente a ésta última.

Tema 4: La voluntad unilateral como fuente de la obligación.

A mediados del siglo XIX surgió en Alemania la idea de que una persona pudiera resultar obligada por su sola manifestación de voluntad, sosteniéndose que la voluntad unilateral es la única fuente de todas las obligaciones creadas por los particulares. Hasta el contrato, según ellos, se disociaría en dos actos distintos, y cada parte se obligaría por un acto único de su sola voluntad. Por voluntad unilateral como fuente de la obligación se entiende a la que contrae un sujeto mediante su mera manifestación de querer obligarse. Una obligación contraída por mera declaración unilateral vincula desde el primer momento al declarante sin necesidad de aceptación y, correlativamente, se inserta desde entonces, como un valor activo, en el patrimonio del acreedor. Los **autores franceses** se resistieron en un comienzo a aceptarla pues estimaban indispensable un acuerdo de voluntades, pero, finalmente, terminaron aceptando la innovación en razón de que en los textos positivos se encuentran casos de obligaciones generadas por la sola voluntad del deudor, como por ejemplo, el artículo 632 del CC que contiene la promesa de recompensa de una especie al parecer perdida o el artículo 99 del CCO que contiene el caso del oferente que se obliga a no disponer de la cosa sino pasando cierto tiempo o desechada la oferta. Los autores destacan la paradoja que significa que la fuerza vinculante de voluntad unilateral no coincida con el apogeo del dogma de la autonomía de la voluntad, aunque se señala que la tesis se ha instaurado no sobre bases psicológicas de signo voluntarista, sino a virtud principalmente de consideraciones sociológicas y sistemáticas, seguridad jurídica y respecto a la buena fe.

Si bien se puede admitir que la voluntad unilateral sea fuente de obligaciones, debe entenderse naturalmente que esa obligación llegará a ser eficaz cuando alguien adquiera la calidad de acreedor, para lo cual será necesaria su voluntad, desde que nadie puede adquirir derechos contra y, ni siquiera, sin su voluntad. Puede observarse que si la obligación nació es porque ha nacido también el correlativo derecho, porque no se concibe una obligación sin el derecho correspondiente.

Tema 5: En Chile ¿se acepta la voluntad unilateral como fuente de obligaciones?

Por regla general nuestro CC no acepta la voluntad unilateral como fuente de obligaciones, salvo la situación excepcional del segundo inciso del artículo 632 del CC. Se fundamenta esta opinión en el hecho que Bello siguió la doctrina de Pothier recogida en el Código de Napoleón, quien manifestó claramente su pensamiento contrario al señalar que no se puede por promesa propia conceder derecho alguno contra la persona del declarante hasta que otra persona concurre con su aceptación a adquirir lo prometido. **La jurisprudencia nacional en forma reiterada ha sostenido que no hay más fuentes de las obligaciones que las que indica el artículo 1437 del CC.** No obstante, hay fallos relativamente recientes que aceptan que la sola voluntad del deudor pueda ser fuente de obligaciones, señalando que hay actos unilaterales que no son delitos, cuasidelitos ni cuasicontratos que obligan a quien los ejecuta.

Tema 6: Otras fuentes doctrinarias.

Se señala por algunos autores que también se pueden considerar como fuentes de las obligaciones **al enriquecimiento sin causa, la protección de la apariencia, el respeto de la buena fe**, etc. *No lo pensamos así, y creemos que se trata únicamente de principios orientadores de la legislación en cuyos casos la fuente es la ley.*

Unidad 3: Clasificación de las Obligaciones.

Tema 1: Diversas Clasificaciones (reseña)

- a) **Atendiendo a su eficacia:** obligaciones civiles y naturales.
- b) **Atendiendo al objeto o prestación:**
 - Según la forma: positivas y negativas.
 - Según la determinación del objeto: de especie o de cuerpo cierto y de género.
 - Según el contenido de la prestación: de dar o entregar, de hacer y de no hacer.
 - Obligaciones de dinero y obligaciones de valor.
 - Según el número de cosas que integran la prestación: de objeto singular y de objeto plural, las que, a su vez, pueden ser de simples objetos múltiples, alternativas y facultativas.
- c) **Atendiendo al sujeto.**
 - De unidad de sujetos.
 - De pluralidad de sujetos, las que, a su vez, pueden ser simplemente conjuntas o mancomunadas, solidarias e indivisible.
- d) **Atendiendo a la forma de existir:**
 - Principales.
 - Accesorias.
- e) **Atendiendo a sus efectos.**
 - Puras y simples y Sujetas a modalidad.
 - De ejecución instantánea y de tracto sucesivo.

Tema 2: Nuevas Categorías de Obligaciones.

2.1 Obligaciones de medio y de resultado.

Son de **medio aquellas en que el deudor se compromete únicamente a hacer todo lo posible y necesario, poniendo para ello la suficiente diligencia para alcanzar un resultado determinado**; en cambio, **son obligaciones de resultado aquellas en que el deudor para cumplir debe alcanzar el resultado propuesto**. Se entiende por obligación de medio aquella cuya prestación consiste en el despliegue de una actividad del deudor dirigida a proporcionar cierto objeto, interés o resultado al

acreedor; es una actividad o comportamiento lo que constituye la sustancia de la prestación. En resultado no está in obligatione, no forma parte directa de la prestación. Por obligaciones de resultado se entienden aquellas en que el deudor se obliga a proporcionar, en forma directa e inmediata, la satisfacción de un interés del acreedor, mediante la obtención de un resultado, el cual integra la prestación. La distinción cobra importancia para saber cuando la obligación se va a entender cumplida o incumplida. En las de resultado está incumplida cuando el deudor no ha proporcionado al acreedor el resultado al que se comprometió. En cambio, en la de medios el deudor incumple la obligación cuando no actúa con la diligencia debida. Tanto en las obligaciones de medio como en las de resultado corresponde al deudor probar el cumplimiento. Sin embargo, el contenido de la prueba en ambos casos es distinto, como se explicó anteriormente. Nuestro CC, al igual que la mayoría de los códigos civiles, no contempla esta distinción. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la distinción entre obligaciones de medio y de resultado, señalando que es desconocida al CC y que tampoco la acepta parte de la doctrina, por cuanto la disposición del artículo 1547 del CC presume la culpa contractual sin hacer diferencias.

2.2 Obligaciones reales, propter rem o ambulatorias.

Se caracterizan **porque la persona del deudor queda determinada por su calidad de dueño, poseedor o titular de un derecho real sobre una cosa, de manera que la obligación se traspasa junto con ella o con el derecho real en que incide.** Un ejemplo de este tipo de obligaciones lo encontramos en el artículo 4 de la Ley No. 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria, que señala que la obligación del propietario de una unidad por los gastos comunes que siempre seguirá al dominio de la unidad, aun respecto de los devengados antes de su adquisición. Creemos competente consignar que la obligación compete no sólo al propietario, sino también al poseedor de la cosa o de un derecho real limitado sobre ella. La calidad de mero tenedor no es bastante para imponer este tipo de obligaciones. Tres observaciones nos parecen de interés:

- ➡ La obligación propter rem, como toda obligación, se puede hacer efectiva no sólo en la cosa que la motiva sino en todo el patrimonio del deudor.
- ➡ El deudor puede liberarse abandonando o renunciando la cosa, siempre que ello lo haga antes del incumplimiento.
- ➡ Aunque se ha discutido, por la relación que tienen con los derechos reales no pueden ser creadas por las partes, siendo su única fuente la ley.

2.3 Obligaciones causales y abstractas o formales.

Toda obligación debe tener una **causa real y lícita**, aunque no es necesario expresarla, conforme lo dispuesto en el artículo 1467 del CC. De manera que no se piense que sólo tiene causa las

primeras. Lo que ocurre es que en las obligaciones abstractas o formales, se produce una separación entre la relación subyacente y la obligación, por ejemplo, cuando una persona suscribe un pagaré, la obligación de pagar las cantidades que en esos documentos se indica, tiene una causa, que no aparece en el mismo, y que proviene de un contrato diferente. Con el objeto que dichos documentos puedan circular, se ha creado esta categoría de documentos abstractos en que el deudor no puede oponer al tercero la excepción de falta de causa. Así lo consigna el artículo 28 de la Ley No. 18.092 que dispone: “La persona demandada en virtud de una letra de cambio no puede oponer al demandante excepciones fundadas en relaciones personales con anteriores portadores de la letra.

Tema 3: Obligaciones Civiles y Naturales.

3.1 Concepto y definiciones.

El artículo 1470 del CC dispone: **“Obligaciones civiles son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento. Obligaciones naturales o imperfectas, son las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas”**. Aunque no lo dice la definición, la obligación civil también otorga excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ella.



3.2 Origen y fundamento de las obligaciones naturales.

Fueron creadas en Roma para moderar los efectos del *sistema del ius civile que negaba la capacidad de obligarse civilmente a los esclavos y a las personas sujetas a patria potestad*, y que desconocía la fuerza obligatoria a los simples pactos, es decir, a las convenciones en que no se observaban las formas rígidas establecidas por la ley para la contratación. Las legislaciones modernas han conservado la institución, pero su fundamento es eminentemente ético.

3.3 Naturaleza de la obligación natural.

Para algunos es una obligación no jurídica, sino moral o de conciencia, o social, etc., que sólo produce un efecto jurídico: que no se puede repetir lo pagado. Para otros, la obligación natural sólo se convierte en jurídica con el pago. Finalmente otros estiman que jurídicamente es un hecho que justifica la atribución patrimonial que se hizo al acreedor, es decir, es sólo una causa justa de tal atribución, entrega o pago. El ordenamiento **considera justa causa de la atribución la denominada obligación natural, por el hecho de que si se permitiese al que pagó pedir la**

devolución, que es lo que habría que hacer de no considerar justificada la entrega, se protegería un acto inmoral consistente en deshacer lo que se había realizado por considerarlo moralmente necesario. Para nuestros autores, las obligaciones naturales son obligaciones, por cuanto constituyen un vínculo jurídico entre personas determinadas que produce efectos jurídicos, retener lo dado o pagado en su virtud. No son simples deberes morales. Quien cumple una obligación moral está pagando lo que debe; en cambio, quien cumple un deber moral está realizando una liberalidad.

3.4 Las obligaciones naturales en el derecho chileno.

Están reglamentadas en los artículos 1470 a 1472 del CC. El artículo 1470 del CC las enumera señalando: “Tales son: **1° Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos; 2° Las obligaciones civiles extinguidas por prescripción; 3° Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida; 4° Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.”.**

3.5 Las obligaciones naturales ¿Son taxativas en Chile?

Señalamos de inmediato que siendo las obligaciones naturales excepcionales, no hay más que las que la ley contempla. Claro Solar estima que el artículo 1470 del CC es **taxativo** por las siguientes razones:

- i. El artículo antes de hacer la enumeración emplea la frase tales son, frase que importa taxatividad.
- ii. El pensamiento del autor del CC es claro en el sentido de determinar y señalar las obligaciones que calificaba como naturales.
- iii. El artículo 2296 del CC hace referencia a las obligaciones naturales mencionándolas como las enumeradas en el artículo 1470 del CC, demostrando con ello que no hay otras.

En general, se ha impuesto la tesis de que la enumeración del artículo 1470 del CC **no es taxativa** por las siguientes razones:

- i. El artículo 1470 del CC las define por lo que siempre que nos encontremos frente a una situación que corresponda a esa definición estaremos ante una obligación natural.
- ii. Por que la expresión tales son significa taxatividad sino ejemplificación.

Si bien la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que el artículo 1470 del CC no es taxativo, no hay unanimidad sobre cuáles serían los otros casos de obligaciones naturales no comprendidos en el artículo. Se mencionan varios:

i. **La multa en los esponsales del artículo 99 del CC.**

Si se ha estipulado multa para el caso de que uno de los esposos no cumpla, no podrá reclamarse la multa, pero si se hubiere pagado no podrá pedirse la devolución. La mayor parte de la doctrina estima que no constituye una obligación natural porque el artículo 98 del CC señala que los esponsales no generan obligación alguna ante la ley civil. Otros estiman que se trataría de una obligación natural.

ii. **Lo dado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.**

El artículo 1468 del CC señala que no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas. No parece en este caso haber una obligación natural sino simplemente una sanción para un acto ilícito, fundado en el principio de que nadie puede alegar su propio dolo.

iii. **Situación del deudor que paga más allá de lo que debe por gozar del beneficio de inventario del artículo 1247 del CC o del beneficio de competencia del artículo 1625 del CC.**

En ambos casos el deudor tiene limitada su responsabilidad, sin embargo, si paga más allá de ese límite, no tiene derecho a obtener la devolución de lo indebidamente pagado. En general la doctrina estima que no hay obligación natural sino renuncia al respectivo beneficio, por lo que el deudor está pagando una obligación civil.

iv. **Pago de intereses no estipulados conforme al artículo 2208 del CC y al artículo 15 de la Ley No. 18.010 sobre Operaciones de Crédito de Dinero.**

Nos parece que tampoco hay obligación natural sino que lo que ocurre, en conformidad al artículo 12 de la Ley No. 18.010 es que la gratuidad no se presume, por lo que si no se han convenido intereses y éstos se pagan se está pagando una obligación civil. Tanto es así que si el deudor no los pagare podría el acreedor demandarlos, ya que el préstamo se presume oneroso.

v. **Pago de una deuda de juego o apuesta en que predomina la inteligencia.**

Conforme al primer inciso del artículo 2260 del CC el juego y la apuesta no producen acción sino solamente excepción y el que gana no puede exigir el pago. Es importante tener presente que el juego y la apuesta puede ser de tres clases: primero, de azar, en que si se paga hay objeto ilícito; segundo, juegos y apuestas en que predomina la destreza física, que generan obligaciones civiles; y, tercero, juegos y apuestas en que predomina la inteligencia, que corresponde al caso que estamos tratando. Se estima que aquí sí nos encontramos frente a una verdadera obligación natural.

3.6 Obligaciones naturales contempladas en el artículo 1470 del CC.

Dentro de esta disposición se establecen dos tipos de obligaciones naturales:

1. **Obligaciones nulas y rescindibles**, que son las contempladas en los números uno y tres del artículo 1470 del CC, o sea, las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos; y, las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida.
2. **Obligaciones naturales que provienen de obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas**, que son las contempladas en los números dos y cuatro del artículo 1470 del CC, o sea, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción; y, las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.

Caso del primer número del artículo 1470 del CC.

Corresponde a las **obligaciones contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento son**, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. Están referidos a los incapaces relativos, jamás a los absolutos, porque estos últimos no tiene suficiente juicio y discernimiento y, además, conforme a lo señalado en el segundo inciso del artículo 1447 del CC, sus actos no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Los incapaces relativos son, hoy día, los menores adultos y los disipadores bajo interdicción de administrar lo suyo, conforme al tercer inciso del artículo 1447 del CC. Respecto a los menores adultos no hay duda que se encuentran comprendido pero surgen dudas respecto de los disipadores. Algunos autores creen que no se les aplica la norma porque están interdictos justamente por no tener suficiente juicio y discernimiento. Otros estiman que el disipador no es un enajenado mental sino un individuo que administra sus bienes en forma imprudente; por ello, tiene suficiente juicio y discernimiento y les es aplicable la norma.

Cabe señalar que si la obligación es nula por otras razones, error, fuerza, dolo, etc., no hay obligación natural, sino una obligación civil nula, por lo que declarada la nulidad deberá restituirse lo dado o pagado en virtud de ella, de acuerdo a las reglas generales, conforme al artículo 1687 del CC.

Respecto a si la obligación es natural desde que nace o desde que se declara la nulidad, la doctrina se encuentra dividida. Algunos sostienen que sólo hay obligación natural desde que se declara la nulidad, pues antes la obligación es válida y produce todos sus efectos. Otros autores sostienen que la obligación natural existe desde que el acto se celebró por los incapaces relativos. La primera

tesis, sostenida principalmente por Alessandri, se funda en que con arreglo a los artículos 1684 y 1687 del CC la nulidad no produce efectos jurídicos entre las partes ni respecto de terceros sino en virtud de sentencia judicial que la declare y mientras la sentencia no sea dictada el acto goza de la presunción legal de que es válido y que se ha ajustado a la ley en su celebración. La opinión contraria, defendida por Claro Solar, se apoya en las siguientes consideraciones:

- i. El primer número del artículo 1470 del CC habla de las contraídas, lo que demuestra que la obligación se contrajo como natural.
- ii. El primer número del artículo 2375 niega la acción de reembolso al fiador que ha pagado al acreedor cuando la obligación del deudor principal es puramente natural y no se ha validado por la ratificación o por el lapso del tiempo; y sólo pueden validarse las obligaciones antes que se declare la nulidad, pues una vez declarada no cabe validarlas sino contraerlas de nuevo.

Por las razones dadas y porque el primer número del artículo 1470 del CC no habla de obligaciones nulas, nos pronunciamos por la segunda opinión, y en el mismo sentido algunos fallos. La discusión tiene importancia porque de seguirse la primera opinión todo deudor que pague una de estas obligaciones antes de pronunciarse la sentencia judicial que la declare nula paga una obligación civil, aunque los vicios que la hicieron anulable o rescindible hayan desaparecido.

Caso del tercer número del artículo 1470 del CC.

Corresponde a las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida.

La primera duda que se plantea es la de determinar a qué clase de actos se refiere. El problema lo plantea la expresión actos, mereciendo dudas si quedan comprendidos sólo los actos unilaterales o también los bilaterales. Claro Solar sostiene que se aplica a ambos tipos de actos. Alessandri, en cambio, defiende la tesis restringida. La jurisprudencia es vacilante. Nos quedamos con la tesis restringida por las siguientes razones:

- i. Porque normalmente la expresión actos se emplea para referirse a los actos unilaterales.
- ii. Porque el ejemplo que el CC pone también corresponde a un acto unilateral, y según el Mensaje de CC los ejemplos ponen a la vista el verdadero sentido y espíritu de una ley en sus aplicaciones.
- iii. Por una razón histórica, ya que la norma fue tomada de Pothier, que lo entendía sólo referido a los actos unilaterales.
- iv. Porque sería injusto aplicar la norma a los actos bilaterales como se puede apreciar en el siguiente ejemplo: si se vende un bien raíz por instrumento privado, el comprador no podría obtener la tradición de la cosa porque el CBR no inscribiría el título y tampoco podría obtener la devolución del precio por tratarse de una obligación natural.

El segundo problema que la disposición plantea consiste en precisar el momento desde que existe la obligación natural. Y la situación es igual a la ya estudiada en el primer número del artículo 1470 del CC, con la salvedad de que aquí dice las que proceden de un acto nulo en lugar de las contraídas, y que no juega en este caso el argumento del primer número del artículo 2375 del CC pues tratándose de una nulidad absoluta no cabe la ratificación.

En relación con el tercer número del artículo 1470 del CC se ha fallado que son obligaciones naturales las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, pero no la firma de cualquiera de las partes que comparecen al acto o contrato, porque en este caso no nace obligación alguna, ni civil ni natural.

Caso del segundo número del artículo 1470 del CC.

Corresponde a las **obligaciones civiles extinguidas por prescripción**. Señalemos que el décimo número del artículo 1567 del CC contempla a la prescripción como uno de los modos de extinguir las obligaciones lo que en realidad no es efectivo, porque, atendido lo que dispone esta norma, prescrita una obligación civil ésta se transforma en natural. Así las cosas, lo que se extingue por prescripción no es la obligación sino la acción para exigir su cumplimiento.

Respecto al momento en que la obligación es natural, se discute si este sería desde que transcurre el tiempo para alegar la prescripción o desde que ésta es declarada. Claro Solar sostiene la primera tesis y el grueso de la doctrina nacional la contraria. Abeliuk señala que le parece más lógica la primera posición pero le ve el inconveniente que si se acepta se confunde dos cosas: la renuncia de la prescripción con el cumplimiento de la obligación natural. Nos parecen más sólidas las razones dadas por los que sustentan la segunda posición, esto es, desde que se declara la prescripción, por los siguientes motivos:

- i. Antes que se declare existe una obligación civil aunque haya transcurrido el plazo de prescripción.
- ii. De seguirla tesis contraria se confunde dos instituciones: la renuncia de la prescripción y el cumplimiento de una obligación natural.

La lógica nos está evidenciando que el deudor que paga una obligación, sin hacer valer la excepción de prescripción que la ley le otorga, no está pagando una obligación natural sino que renunciando a la prescripción. Las sentencias de nuestros tribunales, sin embargo, se han inclinado por la primera tesis.

Caso del cuarto número del artículo 1470 del CC.

Corresponde a las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Para que nos encontremos en este caso, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- i. Que haya habido un pleito demandándose el pago de la obligación.
 - ii. Que el deudor haya ganado el pleito, es decir, no fue condenado a pagar.
 - iii. Que la absolución se deba a que el acreedor no pudo probar la existencia de la obligación.
- Si el pleito se perdió por otra razón, no hay obligación natural y el acreedor no podrá volver a demandar la misma obligación por existir cosa juzgada.

3.7 Efectos de la obligación natural.

Los efectos de las obligaciones naturales son los siguientes:

- a) **Pagadas**, dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas, en conformidad al tercer inciso del artículo 1470 del CC.

Para que se produzca este efecto el pago debe reunir los siguientes requisitos: primero, que cumpla con las exigencias generales de todo pago; segundo, que sea hecho voluntariamente por el deudor; y, tercero, que quien paga tenga la libre administración de sus bienes conforme al inciso final del artículo 1470 del CC.

En cuanto a la voluntariedad del pago, no existe uniformidad en la doctrina sobre lo que ello significa. Un sector entiende que voluntariamente implica que el deudor pague sabiendo que soluciona una obligación natural. Otros, en cambio, sostienen que voluntariamente quiere decir en forma espontánea, sin coacción. Se dice que no puede admitirse la primera tesis ya que sería dar patente de legalidad al fraude y a la inmoralidad ya que no faltarían deudores poco escrupulosos que, después de cancelar su obligación natural, solicitaran la devolución de lo legítimamente pagado pretextando ignorar la falta de acción. Algunas sentencias siguen la última doctrina al fallar que no puede reputarse pago espontáneo que importe cumplimiento de una obligación natural e imposibilite para exigir su devolución, el realizado en virtud de una sentencia dictada en juicio ejecutivo.

En cuanto a la exigencia de que quien paga debe tener la libre administración de sus bienes, debe ser entendida por libre disposición de sus bienes, pues todo pago supone transferir la propiedad del objeto pagado.

b) Pueden ser novadas.

Conforme al artículo 1630 del CC, para que valga la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos, a lo menos naturalmente.

c) Pueden ser caucionadas por terceros conforme al artículo 1472 del CC.

La razón de que sólo se admita que puedan ser caucionadas por terceros es que al ser natural la obligación principal el acreedor no tiene acción para demandar su cumplimiento. Por esa razón, y en virtud del principio que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tampoco podría demandar el cumplimiento de la caución.

d) No producen la excepción de cosa juzgada.

El artículo 1471 del CC dispone: “La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural”.

e) No pueden compensarse legalmente.

Ello por no ser actualmente exigibles conforme al tercer número del artículo 1656 del CC.

Tema 4: Obligaciones Positivas y Negativas.

Es **obligación positiva** aquella en que el deudor se obliga a una determinada acción, dar o hacer; y **negativa**, aquella en que debe abstenerse de realizar algo que de no mediar la obligación podría efectuar, abstenerse de dar o de hacer.

Tiene importancia la distinción para el caso de incumplimiento, pues en las obligaciones de no hacer se siguen los efectos contemplados en el artículo 1555 del CC. También presenta interés para los efectos de la indemnización de perjuicios, pues ésta se debe, en el caso de las obligaciones positivas, desde que el deudor se ha constituido en mora, y en el caso de las negativas, desde el momento de la contravención, conforme al artículo 1557 del CC.

Tema 5: Obligaciones de Especie o Cuerpo Cierta y Obligaciones de Género.

5.1 Concepto.

Las obligaciones de dar o entregar pueden ser de especie o cuerpo cierto y de género. Son de especie o cuerpo cierto aquellas en que la cosa debida está perfectamente especificada e individualizada. Se debe un individuo determinado de un género determinado. Las obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, conforme al artículo 1508 del CC.

5.2 Importancia de la distinción.

Esta clasificación interesa para varios aspectos:

- a) Si la obligación es de especie o cuerpo cierto, sólo se cumplirá pagando con la especie debida y no con otra, aun cuando se de un valor superior, conforme al segundo inciso del artículo 1569 del CC. Si la obligación es de género el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana, conforme al artículo 1509 del CC.
- b) Si la obligación es de dar o entregar una especie o cuerpo cierto, el deudor tiene una obligación adicional, el cuidar de la cosa, conforme al artículo 1548 del CC. Si lo debido es un género no existe esta obligación de cuidado, pues el género no perece conforme al artículo 1510 del CC.
- c) La teoría de los riesgos opera exclusivamente en las obligaciones de especie o cuerpo cierto porque, como acabamos de decir, el género no perece.
- d) La obligación de especie o cuerpo cierto se extingue por el modo de extinguir pérdida de la cosa debida, del séptimo número del artículo 1567 del CC. Y esto sólo si la pérdida ha sido fortuita pues si es culpable la obligación subsiste pero varía de objeto, pudiendo el acreedor demandar el precio de la cosa e indemnización de perjuicios conforme al primer inciso del artículo 1672 del CC.

Tema 6: Obligaciones de Dar, Hacer o No Hacer.



Se desprende de los artículos 1438 y 1460 del CC. El primero al definir el contrato o convención, señala que es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa; y, el segundo expresa que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer.

6.1 Obligaciones de dar.

Es obligación de dar aquella en que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real sobre la cosa a favor del acreedor. El artículo 1548 del CC dispone: “**La obligación de dar contiene la de entregar**”. No se crea que ello significa que obligación de dar y de entregar sean sinónimos, pues en la entrega no hay obligación del deudor de transferirle dominio o constituir un derecho real, sino simplemente de poner materialmente la cosa en manos del acreedor, por ejemplo, en el contrato de compraventa el vendedor debe transferir la cosa vendida, lo que supone una obligación de dar; y en el contrato de arrendamiento el arrendador tiene la obligación de entregar la cosa arrendada, lo que no supone transferir el dominio.

6.2 Naturaleza de la obligación de entregar.

En doctrina la obligación de entregar es una obligación de hacer. **El deudor se obliga a realizar un hecho determinado que consiste en poner la cosa a disposición del acreedor.** Sin embargo, en Chile, se aplican a estas obligaciones las mismas reglas de las obligaciones de dar, lo que se pone a prueba con los siguientes antecedentes:

- i. El artículo 1548 del CC dispone que la obligación de dar contiene la de entregar.
- ii. Así fluye también de los artículos 1438 y 1460 del CC, que contraponen las obligaciones de dar a las de hacer y no hacer. Al no referirse a las de entregar resulta evidente que las engloba en las primeras, pues nada tiene en común con las de hacer o no hacer.
- iii. Así resulta también de los artículos 580 y 581 del CC. Según el primero, los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse o que se deba; y, de acuerdo al segundo, los hechos que se deben se reputan muebles.
- iv. En todo caso, cualquier duda queda disipada con un argumento de historia fidedigna. En efecto, al discutirse el CPC se dejó constancia que para obtener el cumplimiento forzado de una obligación de entregar, se aplicarían las normas dadas para las obligaciones de dar.

Cabe agregar que el propio CC ha incurrido en algunas imprecisiones, confundiendo las obligaciones de dar y entregar. Así por ejemplo, en la compraventa se dice que una de las partes debe dar una cosa en el artículo 1796 del CC, sin embargo, en el artículo 1824 se habla de entrega o tradición. En resumen, en Chile las obligaciones de entregar están asimiladas a las de dar, por lo que se le aplican las mismas normas.

6.3 Obligaciones de hacer.

Obligación de hacer es aquella en que el deudor se obliga a realizar un hecho. Este hecho no podrá ser la entrega de una cosa pues ya hemos dicho que en ese caso se aplican las reglas de las obligaciones de dar, por ejemplo, construir una casa, pintar un cuadro, etc. En algunos casos las obligaciones de hacer tendrán que ser realizadas personalmente por el deudor, cuando la obligación se contrae en consideración a la persona del deudor. En este supuesto suele hablarse de obligación de hacer no fungible. Si es indiferente la persona del deudor, la obligación de hacer podrá ser realizada por un tercer, como lo prueba el segundo número del artículo 1553 del CC al permitir que el acreedor pueda ejecutar el hecho por un tercero a expensas del deudor.

6.4 Obligaciones de no hacer.

En estas obligaciones el deudor debe abstenerse de efectuar un hecho que de no existir la obligación podría realizar. Es corriente, por ejemplo, establecer la prohibición contractual de no abrir un negocio en un determinado sector conforme al artículo 404 del CCO. En doctrina se afirma por algunos que dentro de las obligaciones de no hacer debe hacerse una diferenciación entre aquellas en que el deudor se obliga a abstenerse de desarrollar determinados actos y se reflejaría en la prohibición de hacer algo; de aquellas otras en que el deudor debe dejar de hacer alguna cosa, o lo que es lo mismo, debe tolerar una determinada actuación del acreedor, absteniéndose de perturbarla. Sin embargo autores estiman que dicha distinción es inocua y que en el fondo siempre se obliga a la misma conducta omisiva.

6.5 Importancia de la distinción entre obligaciones de dar, hacer y no hacer.

Tiene trascendencia la distinción para varios efectos:

- i. Para determinar la naturaleza, mueble o inmueble, de la acción encaminada a exigir su cumplimiento. Si la obligación es de hacer o no hacer la acción será siempre mueble conforme al artículo 581 del CC; en tanto, si la obligación es de dar será mueble o inmueble según lo sea la cosa en que ha de ejercerse o que se debe conforme al artículo 580 del CC.
- ii. El procedimiento ejecutivo para obtener el cumplimiento forzado está sujeta a reglas diferentes.
- iii. El modo de extinguir pérdida de la cosa debida, contemplado en el séptimo número del artículo 1567 y en el artículo 1670 del CC y en el quinceavo número del artículo 464 del CPC, sólo se aplica a las obligaciones de dar. El modo de extinguir equivalente en las obligaciones de hacer es la imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida contemplado en el artículo 534 del CPC.
- iv. En los contratos bilaterales, en caso de incumplimiento de una obligación de dar, el contratante cumplidor no puede demandar derechamente el pago de la indemnización de perjuicios, por cuanto tal indemnización es accesoria a las acciones de cumplimiento o resolución del contrato conforme al artículo 1489 del CC. En cambio, si la obligación es de hacer, el acreedor puede demandar directamente la indemnización de perjuicios conforme al tercer número del artículo 1553 del CC.

Tema 7: Obligaciones con Unidad y con Pluralidad de Sujetos.

7.1 Concepto.

Obligaciones con unidad de sujetos son aquellas en que existe un deudor y un acreedor. **Obligación con pluralidad de sujetos** es aquella en que hay un acreedor y varios deudores, **pluralidad pasiva**; varios acreedores y un deudor, pluralidad activa; o varios acreedores y varios deudores, pluralidad mixta. Lo autoriza expresamente el artículo 1438 del CC al disponer que cada parte pueda ser uno o muchas personas.

La pluralidad puede ser originaria o derivativa. Originaria, cuando la obligación nace con pluralidad de sujetos. Derivativa cuando la obligación nace con unidad de sujetos y durante su vida se transforma en plural, por ejemplo, cuando fallece una de las partes y sus herederos son varios o cuando el acreedor cede sus derechos a varios sujetos.

Las obligaciones que debemos estudiar son las con pluralidad de sujetos, que pueden revestir tres modalidades:

- i. Simplemente conjuntas o mancomunadas.
- ii. Solidarias.
- iii. Indivisibles.

7.2 Obligaciones Simplemente Conjuntas o Mancomunadas.

Son aquellas en que existiendo pluralidad de acreedores o de deudores y recayendo sobre una cosa divisible, cada acreedor sólo puede exigir su cuota a cada deudor, que sólo está obligado a la suya. Constituyen la regla general según los artículos 1511 y 1526 del CC.

7.2.1 Características de las obligaciones simplemente conjuntas.

- a) Constituyen la regla general, conforme a los artículos 1511 y 1526 del CC. En otros países, con el objeto de robustecer el crédito, esto no es así, presumiéndose la solidaridad como en Italia y Alemania.
- b) Pluralidad de prestaciones y pluralidad de vínculos; es decir, independencia absoluta entre los distintos vínculos.

- c) Deben recaer las obligaciones sobre un objeto divisible, de manera que puedan cumplirse por parte pues, en caso contrario, nos encontramos frente a las llamadas obligaciones indivisibles.
- d) La regla general es que la división se haga por partes iguales, a menos que la ley o el hombre establezcan otra proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 2307 del CC en materia de comunidad y el artículo 2367 del CC en materia de fianza. Una excepción en que se establece otra proporcionalidad la encontramos en el artículo 1354 del CC en el caso de los herederos que dividan las deudas hereditarias a prorrata de sus cuotas al señalar: “Las deudas hereditarias se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas”. De aquí fluye que es importante saber si las mancomunidades son originarias o derivativas.

7.2.2 Efectos de las obligaciones simplemente conjuntas.

- a) Cada acreedor puede cobrar su cuota y cada deudor sólo se obliga a la suya conforme a los artículos 1511 y 1526 del CC.
- b) La extinción de la obligación respecto de un deudor no extingue la obligación respecto de los otros.
- c) La cuota del deudor insolvente no grava a los demás conforme al artículo 1526 del CC.
- d) La interrupción de la prescripción que opera a favor de un acreedor no favorece a los otros acreedores y, recíprocamente, la interrupción que afecta a un deudor no perjudica a los demás conforme al artículo 2519 del CC.
- e) Si se declara la nulidad de la obligación respecto de uno de los obligados o de uno de los acreedores, este efecto no alcanza a los otros, porque la nulidad es de efectos relativos conforme al artículo 1690 del CC.
- f) La mora de un deudor no coloca en mora a los otros.
- g) Si uno de los deudores incumple la obligación y de ello se genera responsabilidad contractual, indemnización de perjuicios, ésta sólo afecta al incumplidor y no a los otros conforme al tercer número del artículo 1526 y al artículo 1540 del CC.
- h) Cada deudor demandado puede oponer a la demanda, las excepciones reales, o sea, aquellas que emanan de la naturaleza de la obligación como el pago, la nulidad absoluta, la remisión, etc., y únicamente las excepciones personales suyas como la incapacidad y la nulidad relativa.
- i) La prórroga de la jurisdicción que opere a favor de uno de los deudores no afecta a los demás.
- j) Finalmente, se ha sostenido que cuando en un contrato bilateral hay varios acreedores, el contratante cumplidor puede pedir por sí sólo, sin necesidad de ponerse de acuerdo con los demás, la resolución del contrato bilateral de objeto único. El punto ha sido discutido pues generalmente se estima que si hay varios acreedores tienen que ponerse de acuerdo para elegir entre la acción de cumplimiento o la resolución, lo que se desprendería del sexto número del artículo 1526 del CC.

7.3 Obligaciones Solidarias o In Sólidum.

7.3.1 Concepto.

El artículo 1511 del CC señala que son aquellas en que debiéndose un objeto divisible y habiendo pluralidad de acreedores o de deudores, o pluralidad de ambos, cada acreedor puede exigir la totalidad de la obligación a cualquiera de los deudores y cada deudor está obligado a la totalidad de la deuda, de modo que cumplida así la obligación ella se extingue.

7.3.2 La solidaridad es excepcional y no se presume.

Los incisos segundo y tercero del artículo 1511 del CC disponen: *“Pero en virtud del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o a cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establezca la ley”*.

Del hecho de que sea excepcional fluyen varias consecuencias:

- i. Para que haya solidaridad tiene que haber una fuente de solidaridad: convención, testamento o ley. No cabe que se declare la solidaridad por sentencia judicial.
- ii. La solidaridad es de derecho estricto y de interpretación restringida. Por ello, si en un contrato bilateral hay solidaridad para una de las partes, no puede entenderse que también la hay para la contraparte.
- iii. La solidaridad no se presume y debe ser declarada expresamente en el testamento o la convención, si no se halla establecida en la ley. Por lo tanto, no puede deducirse de antecedentes procesales que no son convención, testamento ni ley.
- iv. Quien alegue la solidaridad debe probarla.

7.3.3 Clases de solidaridad.

La solidaridad admite diversas clasificaciones:

i. Activa, pasiva o mixta, según haya pluralidad de acreedores, de deudores o de ambos.

Sin duda que la solidaridad realmente importante es la pasiva pues constituye una garantía muy eficaz, superior a la fianza porque no hay beneficio de excusión ni de división. La solidaridad activa, en cambio, tiene poca utilidad práctica. Pensamos que puede tenerla para facilitar el cobro de documentos bancarios; sirve más para el deudor que el acreedor, pues tiene más facilidades para pagar desde que puede hacerlo a distintas personas.

ii. Según su fuente, puede ser legal o voluntaria, y ésta última puede provenir del testamento o de la convención.

Ejemplo de solidaridad legal lo encontramos en el artículo 2317 del CC que dispone que si un delito o cuasidelito ha sido cometido por dos más personas cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del delito o cuasidelito. Otro caso lo hallamos en el artículo 174 de la Ley No. 18.290 sobre tránsito, que establece que el dueño de un vehículo es solidariamente responsable de los daños que causare el conductor a menos que pruebe que ha sido tomado sin su conocimiento o autorización expresa o tácita.

iii. Perfecta, que es la que produce todos los efectos propios de la solidaridad; imperfecta, que es la que sólo genera algunos efectos.

Esta clasificación en Chile no tiene cabida.

7.3.4 Elementos de la solidaridad.

Se estima que para que exista solidaridad es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

i. Pluralidad de deudores o de acreedores conforme a los artículos 1511 y 1512 del CC.

Si no hay pluralidad de deudores, cada deudor debe pagar la totalidad porque el pago debe ser completo conforme al artículo 1591 del CC.

ii. La cosa debida debe ser divisible.

Pues en caso contrario la obligación será indivisible conforme al artículo 1524 del CC.

iii. La cosa debida debe ser la misma conforme al artículo 1512 del CC.

Si lo debido por los distintos deudores fueren cosas distintas, habrá pluralidad de obligaciones, tantas cuantos objetos hubiere. Por esta razón se ha fallado que si una se obligó a entregar una cosa y otra a pagar una indemnización si el primero no cumplía con esa obligación, no eran codeudores solidarios. Se ha fallado también que en la solidaridad convencional no concurre prohibición alguna que impida a un deudor solidario acceder sólo a una parte de la obligación, pues este acuerdo no quebranta la unidad de prestación, ya que subsiste entre todos los deudores hasta el monto de lo acordado.

iv. Fuente de la solidaridad conforme al segundo inciso del artículo 1511 del CC.

La fuente puede ser la convención, el testamento o la ley. La Corte Suprema ha dicho que la sentencia judicial no es fuente de solidaridad, pues ellas no crean obligaciones sino que las reconocen. También se ha fallado que no existe inconveniente alguno en que la solidaridad convencional se encuentre referida a una parte de la obligación respecto de un deudor solidario y a la totalidad de la obligación respecto de otro.

7.3.5 La solidaridad convencional, en principio, debe establecerse en un solo instrumento.

En el caso en que la fuente de la solidaridad fuere la convención, lo normal será que se la establezca en el mismo instrumento en que se contrae la obligación. Sin embargo, la doctrina estima que no habría impedimento para que pudiera pactarse con posterioridad siempre que en el segundo instrumento se haga referencia expresa al primero.

7.3.6 Unidad de prestación y pluralidad de vínculos.

Si bien la cosa debida por los deudores es la misma, cada uno de ellos puede deberla de diferente manera; los vínculos pueden ser distintos. El artículo 1512 del CC dispone: “La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, ha de ser la misma, aunque se deba de diversos modos, por ejemplo, pura y simplemente respecto de unos, bajo condición o plazo respecto de otros”.

De este principio derivan importantes consecuencias:

- i. Algunos de los vínculos pueden estar sujetos a modalidades.
- ii. La causa de las obligaciones puede ser diversa.
- iii. Los plazos de prescripción pueden ser diversos según la naturaleza del vínculo.
- iv. Puede ser válida la obligación respecto de uno y nula respecto de otro.
- v. Respecto de uno de los deudores puede existir título ejecutivo no respecto de los otros.
- vi. El acreedor que tiene un crédito que goza de privilegio respecto de un deudor no puede invocarlo respecto de los bienes de un codeudor solidario.

7.3. 7 Solidaridad Activa.

7.3.7.1 Concepto.

Se caracteriza porque junto con existir varios acreedores de una obligación con objeto divisible, cualquiera de ellos puede exigir su pago total, de manera que, cumplida en esa forma, se extingue la obligación.

Los elementos de la solidaridad activa son:

- i. Pluralidad de acreedores.
- ii. Cualquier acreedor puede demandar la totalidad de la obligación.
- iii. Extinguida la obligación por un acreedor, se extingue respecto de todos.

El primer inciso del artículo 1513 del CC dispone: “El deudor puede hacerle pago a cualquiera de los acreedores solidarios que elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos, pues entonces deberá hacer el pago al demandante”. Lo anterior no ocurre sólo cuando la obligación se extingue por pago, sino que por cualquiera de los modos de extinguir. El segundo inciso del artículo 1513 del CC dispone: “La condonación de la deuda, la compensación, la novación que intervenga entre el deudor y uno cualquiera de los acreedores solidarios, extingue la deuda con respecto a los otros, de la misma manera que el pago lo haría, con tal que uno de éstos no haya demandado ya al deudor”.

7.3.7.2 Naturaleza jurídica de la solidaridad activa.

El problema consiste en cómo explicar que si se le paga a un acreedor se extinga la obligación respecto de los otros acreedores, lo que lleva a hablar de la naturaleza jurídica de la solidaridad. Hay dos teorías para ello:

i. Teoría romana.

De acuerdo a ella cada acreedor es mirado como propietario exclusivo de la totalidad del crédito, lo que explica que cada uno de ellos pueda cobrar el total o extinguir íntegramente la obligación por cualquier modo, oneroso o gratuito.

ii. Teoría francesa o del mandato tácito y recíproco.

Según ella cada acreedor es dueño sólo de su cuota en el crédito, y respecto de las otras actúa como mandatario de los demás acreedores. El mandato es tácito, porque no lo establecen las partes y recíproco porque cada acreedor tiene un mandato de cada uno de los demás.

No es indiferente que se siga una u otra, pues de adoptarse la primera, cada acreedor puede no sólo cobrar la deuda sino también perdonarla; situación que no puede darse si se sigue la tesis del mandato tácito y recíproco, pues es obvio que no hay mandato tácito para condonar la deuda y no se puede suponer un mandato tácito en tal caso.

No hay dudas de que en Chile, en materia de solidaridad activa, se sigue la tesis romana, y así lo demuestran los siguientes argumentos:

- i. El inciso segundo del artículo 1513 del CC señala que la condonación de la deuda por uno de los coacreedores extingue la deuda respecto de los otros de la misma manera que el pago lo haría.
- ii. Dos notas de Bello en que señala que, en materia de solidaridad activa, se sigue el modelo romano, apartándose de la tesis francesa. En la solidaridad pasiva se sigue la doctrina francesa.

En conclusión, nuestro legislador en materia de solidaridad activa sigue la doctrina romana y en materia de solidaridad pasiva la del mandato tácito y recíproco. No obstante, aparecen dudas en el artículo 1521 del CC que dispone: “Si la cosa perece por culpa o durante la mora de uno de los codeudores solidarios, todos ellos quedan obligados solidariamente al precio, salva la acción de los codeudores contra el culpable o moroso”. Se discute que sea razonable que en este caso los no culpables dieran un mandato al culpable para destruir la cosa. Por ello hay algunos que estiman que se sigue la doctrina romana en ambos tipos de solidaridad. Tiene trascendencia el que en materia de solidaridad pasiva se siga la teoría del mandato tácito, porque si se demanda a un deudor y el acreedor pierde el juicio no podría demandar a otro, pues habría identidad legal de personas, representante y representado. También tendría utilidad en el caso de la prórroga de la jurisdicción, pues producida ésta respecto de un deudor, operaría respecto de todos, porque éste actuaría por sí y como mandatario de los otros aceptando la prórroga.

7.3.7.3 No hay solidaridad activa legal.

Según algunos sólo habría un caso, el establecido en el artículo 290 del CCO que dispone: “La comisión colectivamente conferida por muchos comitentes produce en ellos obligaciones solidarias a favor del comisionista, del mismo modo que la aceptación colectiva de varios comisionistas produce obligación solidaria a favor del comitente”. Se trata de un caso de solidaridad pasiva. En resumen, no hay casos de solidaridad activa legal, por lo que su fuente sólo podrá ser el testamento o el acuerdo de las parte por una convención.

7.3.7.4 La solidaridad activa tiene graves inconvenientes y pocas ventajas.

Los inconvenientes son que el acreedor cobre y que después caiga en insolvencia, con lo que sus coacreedores no tendrán forma de recuperar su parte. Las ventajas son muy pocas y consisten, básicamente, en facilitar el cobro de un crédito y facilitar al deudor el pago, pues puede elegir a quien paga. Opera en las cuentas corrientes bipersonales en que puede girar cualquiera de los interesados. Pero, para lograr este resultado no es necesario recurrir a la solidaridad, bastaría con que los coacreedores se otorgaren poderes recíprocos.

7.3.7.5 Efectos de la solidaridad activa.

Tanto en la solidaridad activa como en la pasiva deben distinguirse las relaciones externas y las internas. Relaciones externas son las existentes entre los coacreedores y el deudor. Las relaciones internas son las que se producen entre los coacreedores entre sí.

Los efectos que se producen respecto de las relaciones externas son los que a continuación de detallan:

- i. Cada acreedor puede demandar el total de la obligación conforme al segundo inciso del artículo 1511 del CC.

ii. El deudor puede hacer el pago al acreedor que elija, a menos que ya estuviere demandado, pues en tal caso sólo se puede pagar al demandante conforme al primer inciso del artículo 1513. Pagando de esta manera extingue la obligación respecto de todos los acreedores.

iii. Los otros modos de extinguir obligaciones que operen entre un acreedor y el deudor, extinguen la obligación respecto de todos, a menos que el deudor estuviere demandado por uno de ellos conforme al segundo inciso del artículo 1513 y al artículo 2461 del CC.

iv. La interrupción de la prescripción natural o civil que aprovecha a un acreedor solidario, beneficia a los otros, conforme al artículo 2519 del CC. Con respecto a la suspensión de la prescripción regirá la regla general que no aproveche a los otros por no haber dicho nada la ley, pero en el fondo da lo mismo porque basta que uno de los acreedores pueda gozar del beneficio para que el asunto se resuelva cobrando el crédito él.

v. La constitución en mora que hace un acreedor, a través de la demanda por ejemplo, constituye en mora al deudor respecto de todos los acreedores, aunque no lo diga el CC, por ser un efecto propio de la solidaridad.

vi. Las medidas precautorias a favor de un acreedor favorece a los otros, aunque no lo diga el CC, por ser un efecto propio de la solidaridad.

Con respecto a las relaciones internas, extinguida la obligación, ellas surgen entre los coacreedores. El acreedor que cobró el total deberá rembolsar a los demás su respectiva cuota, a menos que haya algunos no interesados, caso en que nada les corresponde. Cada uno de los otros acreedores no podrá reclamar al que recibió el pago sino la porción que le corresponde, a prorrata de su cuota, pues la solidaridad sólo existe entre los acreedores solidarios y el deudor. Si obtuvo sólo una parte parcial del crédito deberá rembolsar a cada uno la parte correspondiente. En el caso en que la obligación se haya declarado nula respecto a uno de los acreedores solidarios, cualquiera de los otros acreedores podría demandar el total deducida la cuota correspondiente a esa parte de la obligación. Pero si antes de declarada la nulidad uno de los acreedores hubiere exigido el total y el deudor lo hubiere pagado, no podría después pedir restitución fundándose en que se ha pagado indebidamente, porque el pago total que él ha hecho corresponde efectivamente a su deuda con respecto al acreedor a quien ha pagado, que se considera en sus relaciones con él como dueño de todo el crédito sin deducción alguna.

7.3.8 Solidaridad Pasiva.

7.3.8.1 Concepto.

Es aquella que recayendo sobre una cosa divisible, y en que hay varios deudores, el acreedor puede demandar la totalidad de su crédito a cualquiera de los deudores, extinguiéndose la obligación respecto de todos.

7.3.8.2 Características de la solidaridad pasiva.

i. Es una garantía para el acreedor, en cuanto puede dirigir su acción en contra del deudor que le parezca más solvente.

Como garantía es mejor que la fianza porque no ha beneficio de excusión ni de división. La Corte Suprema ha dicho que es una garantía personas porque ella permite al acreedor hacer efectivo el derecho de prenda general sobre tantos patrimonios cuantos sean los deudores solidarios y en condiciones más ventajosas para el acreedor, ya que aquellos no pueden oponer los beneficios de división y de excusión como en el caso del fiador. Es corriente ver en la práctica que una persona se obliga como fiador y codeudor solidario, y con ello se está demostrando que se trata de un codeudor solidario que no tiene interés en la obligación, lo que le va a beneficiar al momento de resolver las relaciones internas. Desde el punto de vista del acreedor no tiene significación porque simplemente lo va a perseguir como deudor solidario. No es lo mismo estar obligado como fiador y codeudor solidario que como fiador solidario, pues éste último se refiere al caso en que habiendo varios fiadores éstos se han obligado solidariamente entre sí, cada uno de ellos responde por el total, pero como fiador, esto es, subsidiariamente, con beneficio de división y de excusión.

ii. Tiene mucha aplicación en el derecho mercantil.

Así el avalista responde en los mismos términos que el aceptante de una letra de cambio conforme al artículo 47 de la Ley No. 18.092, o sea, todos los que firman una letra de cambio, sea como libradores, aceptantes, endosantes, quedan solidariamente obligados a pagar al portador el valor de la letra más los reajustes e intereses en su caso.

iii. Presenta todos los caracteres que hemos visto para la solidaridad.

Sus fuentes pueden ser la convención, el testamento o la ley.

iv. Ya hemos visto que, en general, se acepta que respecto de esta solidaridad se sigue la teoría francesa del mandato tácito y recíproco.

7.3.8.3 Efectos de la solidaridad pasiva.

Tenemos que distinguir entre las relaciones externas, obligación a las deudas; y, las relaciones internas, contribución a las deudas.

Con respecto a las relaciones externas, o sea, la obligación a la deuda, se mira a las relaciones del acreedor con los deudores, y se distinguen las siguientes características:

- a) El acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores conjuntamente o en contra de cualquiera de ellos por el total de la deuda, sin que éste pueda oponer el beneficio de división, conforme a los artículos 1511 y 1514 del CC.**

Se ha fallado que cuando se demanda a dos personas, a uno como deudor personal y a la otra como deudora solidaria, empecen al actor emplazar a ambas o tan sólo a una. Si el juicio se sigue en contra de un deudor no se puede embargar bienes a otro pues la solidaridad por sí sola no puede despojar de pleno derecho a los demás deudores que no han sido demandados del derecho de representar sus intereses por mandatario legal y de hacer valer las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación y también de las personas que pueden tener contra el acreedor en virtud del artículo 1520 del CC. Por otra parte, el hecho de demandar a un codeudor no significa que no se pueda demandar a otro en juicio aparte pues el artículo 1514 del CC dice que el acreedor puede dirigirse en contra de todos los deudores solidarios conjuntamente, no dice que tengan que serlo en un mismo expediente o por una misma cuerda, y, además, porque el artículo 1515 del CC señala que la demanda intentada en contra de uno no extingue la acción solidaria en contra de los otros. La demanda dirigida contra uno de los codeudores no extingue la obligación solidaria sino en la parte en que no hubiere sido satisfecha por el demandado.

- b) Si el deudor demandado paga el total de la obligación o la extingue por cualquier modo, tal extinción opera respecto de todos los codeudores solidarios, sin perjuicio de sus relaciones internas.**

Así lo dice el artículo 1519 del CC en materia de novación; el artículo 1668 del CC en materia de confusión, desde que se autoriza al codeudor solidario para repetir por la parte o cuota que a los otros codeudores corresponda en la deuda. En el caso de la compensación, el codeudor demandado puede oponer en compensación sus propios créditos, pero no los de los otros conforme al primer inciso del artículo 1520 del CC.

- c) Si el acreedor demanda a un deudor y no obtiene el pago total, podrá dirigirse en contra de cualquiera de los otros, por el saldo.**

Así lo señala el artículo 1515 del CC que dispone: “La demanda intentada por el acreedor contra alguno de los deudores solidarios no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en que hubiere sido satisfecha por el demandado”.

- d) El título ejecutivo contra el deudor principal lo es también en contra del fiador y codeudor solidario.**

Se funda en la existencia del mandato tácito y recíproco, lo que implica identidad legal de personas. Se argumenta, además, que la cosa juzgada es una excepción real que, por la misma

razón, pueden oponer todos y cada uno de los deudores solidarios. Un fallo dispone que de diversas normas de derecho común aparece de manifiesto que las obligaciones que contrae el fiador y codeudor solidario se hallan forzosamente subordinadas a la naturaleza y características de aquellas de que debe responder el deudor principal. La conclusión de dicha sentencia es discutible si el problema se analiza desde el punto de vista de lo que es el título ejecutivo. Sabemos que el título ejecutivo debe bastarse a sí mismo, no aceptándose la yuxtaposición de títulos, esto es, que se junten dos instrumentos para configurar un título ejecutivo. Por otra parte, el artículo 1512 del CC es muy claro en cuanto a que si bien la cosa debida por los distintos codeudores ha de ser una misma, puede deberse de diversos modos, por lo que el hecho de que exista un título ejecutivo en contra de un deudor no significa que también lo haya en contra de los demás. Por estas razones, lo recomendable desde el punto de vista del acreedor, es que al pactarse la solidaridad lo sea por todos los codeudores en un mismo instrumento.

e) La sentencia dictada en contra de un codeudor produce cosa juzgada respecto de los otros.

Ello ocurre porque hay identidad legal de personas, ya que, si se sigue la teoría del mandato tácito al demandarse a uno se demanda a todos; y porque la cosa juzgada es una excepción real, que mira a la naturaleza de la obligación y tal obligación compete a todos los codeudores.

f) La interrupción de la prescripción que opera en contra de uno de los deudores solidarios perjudica a los otros.

El artículo 2519 del CC dispone: “La interrupción que obra a favor de uno de varios coacreedores no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad y ésta no se haya renunciado”. En virtud del principio de la pluralidad de vínculos puede la prescripción empezar a correr en momentos distintos, y la prescripción se contará, respecto de cada deudor, desde que su obligación se hizo exigible. Se ha fallado que hace excepción a ello el artículo 100 de la Ley No. 18.092 puesto que en ese caso la interrupción de la prescripción que opera respecto de un codeudor solidario en un pagaré no perjudica ni afecta a los restantes por cuanto la prescripción se interrumpe sólo respecto del obligado a quién se notifica la demanda judicial. No hay en la solidaridad pasiva problema de suspensión de la prescripción, porque éste es un beneficio a favor del acreedor que aquí es uno solo.

g) Producida la mora respecto de un deudor quedan también constituidos en mora los otros.

No lo dice expresamente el CC pero la doctrina lo desprende de la naturaleza propia de la obligación solidaria.

h) La pérdida de la especie o cuerpo cierto debida por culpa de uno de los codeudores genera responsabilidad para todos, respecto del pago del precio, pero no respecto de la indemnización de perjuicios que sólo debe pagar el culpable conforme a lo dispuesto en el artículo 1521 del CC.

En caso que sean dos o más los culpables la ley nada dice. Para algunos, cada deudor respondería de los perjuicios sólo por su cuota, salvo que haya habido dolo o culpa graves, pues entonces, de conformidad con el artículo 2317 del CC, habría responsabilidad solidaria. Otros autores estiman algo contrario argumentando que, frente a diferentes interpretaciones se debe buscar la más útil, y, en este caso, siendo culpables todos los deudores o estando en mora todos ellos, es más útil que la acción sea también solidaria. Además, conforme a lo dispuesto en el tercer número del artículo 1526 del CC aquel de los codeudores que por hecho o culpa suya ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor. Si hay cláusula penal no se aplica la regla del artículo 1521 del CC de que respecto de los perjuicios no hay solidaridad, pues la doctrina estima que puede demandarse el total de la cláusula penal a cualquiera, o sea, la solidaridad estipulada en el contrato alcanza y se hace extensiva a la pena.

i) La prórroga de la jurisdicción respecto de un deudor afecta a todos.

Así se ha fallado basado en la existencia de un mandato tácito y recíproco.

j) Si el acreedor cede su crédito a un tercero, no es necesario que notifique la cesión a todos o que todos tengan que aceptarla conforme al artículo 1902 del CC.

Basta que se notifique a cualquiera de los deudores por aplicación de la teoría del mandato tácito y recíproco.

Con respecto a las excepciones que puede oponer el deudor demandado, digamos de partida que de conformidad al artículo 1514 del CC, demandado un deudor no tiene beneficio de división, lo cual también se desprende del segundo inciso del artículo 1511 del CC. La regla general es que el deudor solidario pueda oponer a la demanda todas las excepciones que resulten de la naturaleza de la obligación, y, además, las personales suyas conforme al primer inciso del artículo 1520 del CC. Las excepciones que miran a la naturaleza de la obligación se denominan excepciones reales, y, generalmente, están referidas a vicios de que adolece la fuente de la obligación solidaria y que generan nulidad absoluta, por ejemplo, falta de consentimiento, falta de objeto, etc. Las excepciones personales son aquellas que sólo las pueden oponer el deudor o deudores respecto de los cuales se reúnen las causas o circunstancias en que se fundan, por ejemplo, nulidad relativa, incapacidad relativa, etc. Se habla también de las excepciones mixtas por reunir características tanto de las reales como de las personales, por ejemplo, la excepción de compensación, la

remisión parcial de la deuda, etc. Se ha fallado que si se dirige una demanda en contra del deudor directo y del fiador y codeudor solidario pero éste último no es notificado, la sentencia no le empuja por no haber sido parte ni intervenido en forma alguna en dicha causa ejecutiva.

Se discute si entablado un juicio en contra de uno de los codeudores solidarios el otro podría intervenir en dicho juicio. La afirmativa nos parece evidente pues si hemos aceptado que la sentencia que se dicte en ese juicio va a producir cosa juzgada respecto de todos, no puede merecer duda que cada uno de ellos tiene un interés legítimo en el resultado del juicio, cumpliéndose de ese modo la exigencia del artículo 23 del CPC para intervenir como tercero coadyuvante.

Respecto a las relaciones internas, contribución a las deudas, extinguida la obligación respecto del acreedor, debe resolverse lo que ocurre entre los codeudores. Las relaciones internas sólo se van a generar si el deudor extinguió la obligación por el pago o por un modo equivalente al pago, esto es, que implique un sacrificio económico conforme al artículo 1522 del CC. Luego, si la deuda se extinguió por prescripción, por ejemplo, o por condonación de la deuda, no hay problema de relaciones internas. Para el estudio de las relaciones internas debe distinguirse: primero, si todos los codeudores tienen interés en la obligación; y, segundo, si sólo alguno de ellos tiene interés en la obligación. En este segundo caso debe subdistinguirse, a su vez, si paga quien tiene interés o si paga quien no tiene interés.

i. Si todos los deudores tienen interés en la obligación, el deudor que paga se subroga en el crédito, con todos sus privilegios y seguridades, y puede dirigirse en contra de los demás codeudores pero sólo por su cuota.

No se subroga, entonces, en la solidaridad conforme al primer inciso del artículo 1522 del CC. De manera que el deudor que paga podrá dirigirse en contra de cada uno por su cuota, incluida a cuota del deudor insolvente, conforme al inciso final del artículo 1522 del CC. El deudor que paga tiene además de la acción subrogatoria, una acción personal de reembolso, que emana del mandato tácito y recíproco si aceptamos esa teoría, que le permitirá dirigirse en contra de los demás codeudores para que le reembolsen lo que pagó en representación de ellos. Se afirma que esta acción de reembolso le puede convenir más porque le permite cobrar intereses corrientes de conformidad al cuarto número del artículo 2158 del CC.

ii. Si sólo alguno de los deudores tienen interés en la obligación, los efectos serán distintos según si pagó un interesado o un no interesado.

Si pagó un codeudor interesado, se subroga en la acción del acreedor a quién pagó y puede dirigirse en contra de cada uno de los demás codeudores interesados por su correspondiente

cuota. No puede dirigirse en contra de los no interesados porque sólo tienen la calidad de fiadores, conforme al segundo inciso del artículo 1522 del CC.

Si pagó un codeudor no interesado, la prueba de que no es interesado le corresponde a él, el artículo 1522 del CC lo considera como fiador y, consecuencia de ello, es que se subroga en la acción del acreedor, incluso en la solidaridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2372 del CC, pudiendo demandar intereses y gastos.

7.3.8.4 Extinción de la solidaridad pasiva.

Puede extinguirse conjuntamente con la obligación solidaria, o bien, extinguirse sólo la solidaridad. Esto último ocurre en los casos de muerte del deudor solidario y de renuncia de la solidaridad.

i. Muerte del deudor solidario.

Cuando muere el deudor solidario los herederos suceden en la obligación, pero no en la solidaridad, o sea, todos los herederos están obligados al pago total de la deuda, pero cada heredero será solamente responsable de aquella cuota que corresponda a su porción hereditaria conforme al artículo 1523 del CC. Sin embargo, la muerte del causante no extingue la solidaridad cuando se ha convenido lo contrario, lo cual es una cláusula frecuente en los contratos, y está permitida en el segundo inciso del cuarto número del artículo 1526 del CC y en el artículo 549 del CC, a propósito de la responsabilidad de los integrantes de una corporación.

ii. Renuncia de la solidaridad.

El acreedor puede renunciar a la solidaridad pues está establecida en su solo beneficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del CC. La renuncia de la solidaridad consiste en el acto en cuya virtud el acreedor prescinde de su derecho a cobrar el total de la obligación sea respecto de todos los deudores, renuncia total, sea respecto de alguno o algunos de los deudores, renuncia relativa. Conforme al artículo 1516 del CC puede ser expresa o tácita. Se renuncia en forma expresa cuando se hace en términos formales y explícitos. Se renuncia tácitamente a favor de uno de ellos cuando le ha exigido o reconocido el pago de su parte o cuota de la deuda, expresándolo así en la demanda o en la carta o recibo de pago, sin reserva especial de la solidaridad o sin la reserva especial de sus derechos, conforme al segundo inciso del artículo 1516 del CC. La jurisprudencia ha dicho que la acción judicial dirigida conjuntamente contra todos los deudores no hace presumir por sí sola la renuncia de la solidaridad. También se ha fallado que no hay renuncia tácita cuando sólo consta que el ejecutante ha aceptado los abonos que uno y otro deudor han hecho a la deuda, pero no que haya recibido a cada uno su parte o cuota.

Respecto de los efectos de la renuncia; el primero de ellos es que si la renuncia es parcial, el deudor liberado de la solidaridad sólo está obligado a pagar su cuota o parte en la deuda, continuando los demás obligados solidariamente al pago en la parte del crédito que no hay sido cubierta por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad, conforme a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 1516 del CC. Por otra parte, si la renuncia es total, se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios y, por lo tanto, el acreedor consiente en la división de la deuda, conforme al inciso final del artículo 1516 del CC, o sea, la obligación se convierte en simplemente conjunta o mancomunada.

Se puede renunciar a la solidaridad cualquiera que sea su fuente, porque la ley no hace distinción alguna. De manera que la solidaridad legal es renunciable.

En cuanto a la renuncia de una pensión periódica, esta materia la trata el artículo 1517 del CC señalando que esta renuncia, expresa o tácita, se limita a los pagos devengados. Para que se extienda a las pensiones futuras tiene que expresarlo el acreedor, lo que es lógico porque las renunciaciones no se presumen pues son de derecho estricto. Luego no hay renuncia futura tácita.

7.4 Obligaciones Divisibles e Indivisibles.

La divisibilidad o indivisibilidad de la obligación no ofrece ningún interés cuando es uno el deudor y es uno el acreedor. En tal caso, la **obligación divisible** se comporta y debe ser ejecutada como si fuera indivisible, o sea, el deudor debe cumplirla íntegramente, no puede pagarla por partes, conforme al artículo 1591 del CC que establece una regla fundamental en el pago, al disponer que el deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes lo que se le deba, esto es, el pago ha de ser total.

La cuestión tiene interés si hay pluralidad de sujetos, y, especialmente, cuando fallece el deudor o el acreedor, dejando varios herederos. Si es **indivisible la obligación**, no se dividirá ni activa ni pasivamente; a cada heredero del deudor podrá forzársele al pago íntegro y cada heredero del acreedor podrá reclamar el pago total. En esto radica la importancia de la indivisibilidad y la ventaja que presenta para el acreedor, la obligación indivisible respecto de la solidaria, pues la indivisibilidad pasa a los herederos conforme al artículo 1528 del CC.

7.4.1 Obligaciones divisibles e indivisibles.

Para juzgar si la obligación es divisible o indivisible debe **atenderse a la naturaleza de la prestación que constituye su objeto**. El artículo 1524 del CC dispone: **“La obligación es divisible o indivisible según tenga o no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota”**.

De este modo, la obligación será divisible si no hay imposibilidad física o jurídica para que el objeto debido pueda dividirse física o intelectualmente. Es indivisible, al contrario, si el objeto no es susceptible de división física o intelectual. La división física es una división material, real, por ejemplo, un campo que puede dividirse en parcelas. Jurídicamente una cosa es susceptible de división física cuando puede dividirse sin que pierda su individualidad o utilidad, por ejemplo, un caballo puede dividirse de hecho, físicamente, pero se convierte en algo distinto a un caballo. La división intelectual es aquella que se hace con la sola inteligencia, es una división imaginaria, una abstracción, por ejemplo, el caballo puede pertenecer a varias personas. Esta forma de división es aplicable aun a las cosas que no son susceptibles de una división física o material. Con ello el campo de lo indivisible se restringe enormemente, pues las cosas que no son susceptibles de división física lo serán, casi siempre, de división intelectual o de cuota. El artículo 1524 del CC señala como ejemplo de obligación indivisible la de hacer construir una casa, pero tal obligación es intelectualmente divisible y, en el hecho, es frecuente que una persona se encargue de la construcción de la obra gruesa, otra de las maderas, otra de las instalaciones eléctricas, etc.

7.4.2 Diversas clases de indivisibilidad.

Se distinguen tres clases de indivisibilidad, que a continuación se señalan:

Indivisibilidad absoluta	Es aquella que resulta de la naturaleza misma de la obligación. Lamente no concebiría la posibilidad de una división en el cumplimiento de la prestación que forma su objeto. La voluntad de las partes no entra en juego. De esta especie es la indivisibilidad de la obligación de conceder una servidumbre de tránsito, pues no se concibe su ejecución parcial. Otro tanto ocurriría con la obligación de hacer un viaje de Santiago a Temuco y la persona se baja en Talca, entendiéndose que no ha cumplido la obligación en lo absoluto.
Indivisibilidad de obligación	El objeto de la obligación y, por lo tanto, la obligación misma, son divisibles, pero las partes han querido que ésta sea indivisible. Se concibe la posibilidad de fraccionar el cumplimiento, pero la intención expresa o tácita de las partes hace indivisible la obligación. Tal es el caso de hacer construir una casa, pues el objeto de la obligación es la casa construida y una prestación parcial no procurará una satisfacción adecuada al acreedor, no se conseguirá el fin perseguido. Es la intención de las partes lo que hace indivisible la obligación que, teóricamente, admite división.
Indivisibilidad de pago	Concierne únicamente al cumplimiento de la obligación y no a la obligación misma. El objeto es divisible y la obligación puede dividirse activa y pasivamente. Por ejemplo, Pedro debe cien y se estipula que si fallece la obligación podrá reclamarse íntegramente a los herederos. El objeto es típicamente divisible, la indivisibilidad radica

en el pago que los herederos deben efectuar íntegramente. Si por la inversa fallece el acreedor y deja varios herederos, no podrá cada uno de ellos reclamar el pago total porque la obligación activamente se divide y la indivisibilidad de pago es puramente pasiva. En ello radica la diferencia entre la indivisibilidad de obligación y la indivisibilidad de pago, que se parecen bastante porque en ambas la voluntad de las partes es determinante. La indivisibilidad de obligación impide que la obligación se divida activa y pasivamente; no se divide ni entre los herederos del deudor ni entre los del acreedor. La indivisibilidad de pago no impide la división entre los herederos del acreedor y solamente opera respecto de los herederos del deudor; es puramente pasiva.

7.4.3 Sistema del Código Civil.

Nuestro CC ha adoptado un criterio eminentemente práctico e ignora la terminología tradicional.

Si la cosa es susceptible de división física o intelectual la obligación es divisible, de otro modo es indivisible.

No hace distinción entre indivisibilidad absoluta e indivisibilidad de la obligación, como lo demuestran los ejemplos del artículo 1524 del CC. La indivisibilidad de pago se presenta como una excepción a las reglas que rigen los efectos de las obligaciones divisibles; el CC no les asigna nombre siquiera a las obligaciones indivisibles.

El CC, pues, conoce dos clases de indivisibilidad: la indivisibilidad propiamente tal y las excepciones a la divisibilidad que, aproximadamente, corresponden a la indivisibilidad de pago en la terminología tradicional.

7.4.4 Efectos de las Obligaciones Divisibles

El primer inciso del artículo 1526 del CC dispone: **“Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los acreedores sólo puede exigir su cuota, y cada uno de los codeudores solamente es obligado al pago de la suya”**. Activa y pasivamente la prestación se divide y hay tantas obligaciones como acreedores o deudores. Como una lógica consecuencia, el artículo 1526 del CC concluye que la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores.

7.4.5 Excepciones a la divisibilidad o indivisibilidad de pago.

Por excepción, sin embargo, la obligación divisible no puede cumplirse parcialmente, porque tal es la intención de las partes, expresa o tácitamente manifestada. En verdad, el estudio de las obligaciones indivisibles se traduce más bien en el examen de estas excepciones a la divisibilidad. Pese a que el objeto es divisible, en su cumplimiento la obligación se comporta como indivisible.

Las obligaciones propiamente indivisibles son rarísimas y su interés, por lo mismo, prácticamente nulo; las excepciones a la divisibilidad, en cambio, ofrecen un interés práctico considerable.

Primera excepción: La acción hipotecaria o prendaria.

En una obligación garantizada con una prenda o una hipoteca se distinguen, nítidamente, la obligación principal y la obligación accesoria de las que emanan, respectivamente, una acción personal y una acción real hipotecaria o prendaria. La obligación principal puede ser divisible, como cuando consiste en el pago de una cantidad de dinero; en consecuencia, siendo varios los deudores, no puede el acreedor demandar a cada uno sino su parte o cuota en la deuda. La obligación accesoria, en cambio, es siempre indivisible.

La indivisibilidad de la prenda y de la hipoteca comprende varios aspectos:

- a) La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea, en todo o parte, la cosa hipotecada o empeñada, conforme al primer número del artículo 1526 del CC. El acreedor tiene dos caminos a seguir: primero, ejercitar la acción personal y cobrar a cada acreedor su cuota; y, segundo, ejercitar la acción real y cobrar la totalidad de la deuda pero únicamente al poseedor. Por ejemplo, Pedro es deudor hipotecario por ciento veinte; fallece y le suceden tres personas. El acreedor puede cobrar la totalidad al que se adjudicó la finca hipotecada, pero solamente cuarenta a cada heredero, porque ello sería su cuota en la deuda.
- b) Mientras no se cancela íntegramente la deuda ninguno de los deudores puede reclamar la restitución de la prenda o la cancelación de la hipoteca. Por la inversa, ninguno de los acreedores que ha recibido el pago de su parte en el crédito puede remitir la prenda o cancelar la hipoteca, mientras no hayan sido enteramente sus coacreedores, conforme al primer número del artículo 1526 y a los artículos 2396 y 2405 del CC.
- c) Todos los bienes hipotecados o empeñados y cada una de sus partes están afectos al cumplimiento íntegro de la obligación. El artículo 2408 del CC dispone: “La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella”. Si las fincas hipotecadas son varias, el acreedor podrá perseguir en cada una el pago íntegro conforme al artículo 1365 del CC; si la finca se divide, sobre cada uno de los lotes gravita la deuda total.

Segunda excepción: Deuda de especie o cuerpo cierto.

El segundo número del artículo 1526 del CC dispone: “Si la deuda es de una especie o cuerpo cierto, aquel de los codeudores que lo posee es obligado a entregarlo”. La materialidad de la entrega, como se comprende, tendrá que verificarla, en último término, el detentador de la cosa. La obligación de dar contiene a la de entregar la cosa, es decir, ponerla materialmente a disposición del acreedor. La obligación de dar, propiamente tal, es divisible. Cada uno de los

deudores se obliga a transferir su parte o cuota en el dominio. Pero la entrega anexa a la obligación de dar puede reclamarse de aquel de los varios deudores que tiene la cosa.

Tercera excepción: Acción de perjuicios contra el deudor culpable.

El tercer número del artículo 1526 del CC dispone: “Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor”. La obligación de indemnizar perjuicios es divisible, porque regularmente consiste en el pago de una suma de dinero. No obstante, la ley coloca en la necesidad de pagarla íntegramente al deudor culpable. Es indiferente que la obligación violada sea divisible o indivisible, conforme al artículo 1533 del CC. El propósito del legislador es que siempre expíe el pecado quien lo ha cometido. Los términos de la disposición son notoriamente impropios, toda vez que dice que el deudor es exclusiva y solidariamente responsable, aunque lo hace para significar que es el único responsable del total de los perjuicios, pues la existencia de un responsable único excluye la idea de solidaridad.

Cuarta excepción: Testamento, convención de los herederos o acto de partición que impone a un heredero el pago total.

Las deudas hereditaria, o sea, las que el causante tenía en vida, y las deudas testamentarias, esto es, las que tienen su origen en el testamento mismo, se dividen entre los herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias, conforme a los artículos 1353 y 1360 del CC. Pero el testador, los mismos herederos o el partidor de la herencia, pueden distribuir las deudas de otra manera que a prorrata. El cuarto número del artículo 1526 del CC dispone: “Cuando por testamento o por convención entre los herederos o por la partición de la herencia se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda o contra cada uno de los herederos por la parte que le corresponda a prorrata”.

Quinta excepción: Convenio entre el causante y el acreedor que impone a un heredero el pago total.

El caso es totalmente diverso del anterior. Esta vez es un convenio entre el deudor y el acreedor el que impone a los herederos del primero la obligación de satisfacer la deuda íntegramente. El cuarto número del artículo 1526 del CC dispone: “Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo, salva su acción de saneamiento”. La expresión salva su acción de saneamiento significa que el heredero que ha pagado el total tiene derecho para que sus coherederos le reembolsen lo pagado en exceso sobre su cuota. Pero la indivisibilidad es puramente pasiva; los herederos del deudor deben pagar el total, pero los herederos del acreedor no pueden demandar el pago íntegro si no obran de consuno. Tal es una de las características de la indivisibilidad de

pago que destaca el cuarto número del artículo 1526 del CC al disponer: “Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el pago de la deuda, sino a prorrata de sus cuotas”.

Sexta excepción: Cosa cuya división acarrea perjuicio.

El quinto número del artículo 1526 del CC dispone: “Si se debe un terreno o cualquier otra cosa indeterminada, cuya división ocasionare grave perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros para el pago de la cosa entera, o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los otros”. El caso es muy parecido al anterior, pero, mientras que en aquél la indivisibilidad resulta de una expresa declaración de voluntad, en éste la ley establece la indivisibilidad, presumiendo la intención de las partes. Se presume que las partes no han querido una división que causa al acreedor un grave perjuicio. Pero la indivisibilidad es, también, puramente pasiva, porque, conforme al quinto número del artículo 1526 del CC: “Los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera, sino intentando conjuntamente su acción”.

Séptima excepción: Obligaciones alternativas.

La elección de la cosa que ha de servir para efectuar el pago, de entre las varias alternativamente debidas, puede corresponder al deudor o al acreedor y, si son varios, deben efectuar la elección de común acuerdo. El sexto número del artículo 1526 del CC dispone: “Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerla todos de consuno; y si de los deudores, deben hacerla de consuno todos éstos”.

7.4. 6 Efectos de las Obligaciones Indivisibles.

Los artículos 1527 y siguientes del CC tratan de las obligaciones propiamente indivisibles. Estas normas se inspiran, en sustancia, en la idea de que cada deudor no lo es sino de su cuota y cada acreedor no lo es sino de la suya. Si cada deudor ha de pagar el total y cada acreedor tiene derecho para demandarlo, es porque el objeto de la obligación no puede dividirse. Cada acreedor y cada deudor son acreedor y deudor del todo, pero no del total. La indivisibilidad puede ser activa y pasiva.

➡ Indivisibilidad pasiva.

Se trata de examinar los efectos de la indivisibilidad cuando son varios los deudores:

- i. El artículo 1527 del CC dispone: “Cada uno de los que han contraído unidamente una obligación indivisible, es obligado a satisfacerla en el todo”. Lo dicho para el deudor rige para sus herederos, se dice, por esto, que la indivisibilidad pasa a los herederos, conforme al artículo 1528 del CC.
- ii. El artículo 1531 del CC dispone: “El cumplimiento de la obligación indivisible, por cualquiera de los obligados, la extingue respecto de todos”.

- iii. El deudor demandado para el pago de la obligación puede pedir un plazo para entenderse con sus codeudores para cumplirla entre todos, salvo que la obligación sea de tal naturaleza que él solo pueda cumplirla, porque en tal caso podrá ser condenado desde luego al total cumplimiento, quedándole a salvo su acción contra los demás deudores para la indemnización que le deban, conforme al artículo 1530 del CC. Si la obligación consiste, por ejemplo, en constituir una servidumbre de tránsito en una heredad adjudicada a uno de los deudores, el plazo para deliberar es estéril.
- iv. El artículo 1529 del CC dispone: “La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible, lo es igualmente respecto de los otros”.
- v. Es divisible la obligación de indemnizar perjuicios por el incumplimiento de una obligación indivisible. Cada deudor debe repararlos en la parte que le quepa, conforme al primer inciso del artículo 1533 del CC. Si el cumplimiento se ha hecho imposible por hecho o culpa de uno de los deudores, éste será responsable único de los perjuicios causados, conforme al segundo inciso del artículo 1533 del CC. El artículo 1534 del CC dispone: “Si de dos codeudores de un hecho que deba ejecutarse en común, el uno está pronto a cumplirlo y el otro lo rehúsa o lo retarda, esto sólo será responsable de los perjuicios que de la inejecución o retardo resultaren al acreedor”.
- vi. Cada deudor debe su cuota y se ve en la necesidad de pagar el total por la naturaleza indivisible del objeto debido. Pagada la deuda íntegramente, tiene el deudor que pagó derecho a que sus codeudores le indemnizen porque, a la postre, ha pagado más de lo que verdaderamente debía, conforme a lo dispuesto en el artículo 1530 del CC.

➡ **Indivisibilidad activa.**

Corresponde ahora examinar los efectos de la indivisibilidad cuando son varios los acreedores:

- i. Cada uno de los acreedores de una obligación indivisible tiene derecho a exigir el total, conforme al artículo 1527 del CC. Del mismo modo, cada uno de los herederos del acreedor puede exigir su ejecución parcial conforme al artículo 1528 del CC.
- ii. El pago a un acreedor extingue la obligación respecto de todos. Pero el acreedor de la obligación indivisible no puede ejecutar ninguno de los actos de disposición del crédito que le están permitidos al acreedor solidario. El artículo 1532 del CC dispone: “Siendo dos o más los acreedores de la obligación indivisible, ninguno de ellos puede, sin el consentimiento de los otros, remitir la deuda o recibir el precio de la cosa debida. Si alguno de los acreedores remite la deuda o recibe el pago de la cosa, sus coacreedores podrán todavía demandar la cosa misma, abonando al deudor la parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de la cosa”.
- iii. El acreedor que recibe el pago debe a sus coacreedores su parte o cuota en el crédito.

7.4.7 Paralelo entre la Solidaridad y la Indivisibilidad.

Sus semejanzas	Ambas clases de obligaciones tiene semejanzas, de tal modo que el legislador ha creído oportuno disponer en el artículo 1525 del CC: “El ser solidaria una obligación no le da el carácter de indivisible”. a) En ambas clases de obligaciones el sujeto activo o pasivo es múltiple. b) En ambas clases de obligaciones el acreedor tiene derecho a demandar el pago íntegro y cada deudor está en la necesidad de efectuar el pago total. c) En fin, en ambas categorías de obligaciones el pago que hace cualquiera de los deudores a cualquiera de los acreedores extingue la obligación respecto de todos.
Diferencias. El principio y sus consecuencias	Las diferencias entre ambas clases de obligaciones son considerables. En la obligación solidaria cada deudor debe el total y por esto puede reclamársele el pago íntegro. En la obligación indivisible, cada deudor no debe sino su cuota, pero se ve forzado a efectuar un pago integral, porque la obligación no es susceptible de ejecución parcial. De aquí resulta: a) La solidaridad tiene como fuente la ley, un testamento o una convención que determinan que no pueda cumplirse por partes una prestación naturalmente divisible. La indivisibilidad resulta de la prestación misma que no puede dividirse por su naturaleza o por la voluntad de las partes. b) La solidaridad no pasa a los herederos, conforme al artículo 1523 del CC; la indivisibilidad pasa a los herederos y para ellos la obligación sigue siendo indivisible conforme al artículo 1528 del CC. c) Si perece la cosa debida en la obligación indivisible, la obligación se torna divisible, los deudores deben cada cual su parte o cuota del precio y de los perjuicios conforme al artículo 1533 del CC; si perece la cosa en la obligación solidaria, la obligación de pagar el precio, que reemplaza a la cosa debida, es también solidaria, conforme al artículo 1521 del CC. d) En la obligación solidaria cada acreedor se reputa dueño absoluto del crédito, y puede condonar la deuda, novarla, etc., conforme a los artículos 1518 y 1519 del CC. En la obligación indivisible cada acreedor es dueño de su cuota, no puede novar la obligación o remitirla, conforme a lo dispuesto en el artículo 1532 del CC. e) En las obligaciones solidarias, como cada deudor lo es del total, no puede oponer ninguna excepción para pedir el concurso de los codeudores para efectuar el pago; en las obligaciones indivisibles puede el deudor pedir un plazo para entenderse con sus codeudores y cumplir de consuno, conforme a lo dispuesto en el artículo 1530 del CC.

Tema 8: Obligaciones Principales y Accesorias.

8.1 Concepto.

Del artículo 1442 del CC, que clasifica los contratos en **principales** y **accesorios**, podemos inferir que las **obligaciones principales son aquellas que pueden subsistir por sí solas, sin necesidad de otras**; y, que son **obligaciones accesorias, las que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella**. Por ejemplo, la obligación del mutuario de restituir o la del comprador de pagar el precio son obligaciones principales; en cambio, son accesorias las que derivan de una caución, prenda, hipoteca, cláusula penal, etc.

8.2 Importancia de la distinción.

Tiene importancia esta distinción por cuanto lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y ello es relevante, porque si se extingue la obligación principal se extingue la obligación accesorio por vía de consecuencia. Aplicación de este principio es el artículo 1536 del CC que dispone que la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal. También importa la distinción para los efectos de la prescripción, pues la obligación accesorio prescribe junto con la obligación principal, conforme al artículo 2516 del CC que dispone: “La acción hipotecaria, y las demás que procedan de una obligación accesorio, prescriben junto con la obligación a que acceden”.



Tema 9: Obligaciones Puras y Simples o Sujetas a Modalidad.

9.1 Concepto de Modalidad.

La regla general es que las obligaciones sean puras y simples, que produzcan sus efectos normalmente desde su nacimiento hasta su extinción. Sin embargo, en virtud del testamento, de la voluntad de las partes o de la ley, se puede agregar a la obligación una modalidad con el objeto de alterar sus efectos normales, sea en cuanto a su nacimiento, a su ejercicio o a su extinción. Que una obligación produzca sus efectos normales significa que:

- i. El derecho y la correlativa obligación nacen coetáneamente con el acto mismo que los crea.
- ii. Que generada la obligación, el acreedor puede ejercer sus derechos de inmediato.
- iii. Que la obligación va a subsistir en el tiempo hasta su extinción normal, si que deban volver las partes al estado anterior al acto de su creación.
- iv. Que el deudor debe cumplir su obligación, sin que le impongan cargas al acreedor, para que pueda tener por suyo el contenido de la prestación.

Estos efectos normales se alteran cuando se incorpora una modalidad. De acuerdo a lo dicho, podemos definir las modalidades como los elementos establecidos por la ley, el testamento o la voluntad de las partes con el objeto de alterar los efectos normales de un negocio jurídico.

9.2 La condición, el plazo y el modo son las principales modalidades pero no las únicas.

En efecto, cualquiera alteración constituye una modalidad, de manera que también tienen este carácter la solidaridad, las obligaciones alternativas o facultativas y la representación.

9.3 Características de las modalidades.

- a) **Son elementos accidentales de los actos jurídicos**, porque ni esencial ni naturalmente le pertenecen, sino que se le agregan mediante cláusulas especiales, conforme al artículo 1444 del CC. En forma excepcional las modalidades pueden no ser elementos accidentales, sino de la naturaleza del acto o incluso esenciales, por ejemplo, la condición resolutoria tácita es un elemento de la naturaleza de los contratos bilaterales, y en el contrato de promesa, la condición o el plazo pasa a ser un elemento de la esencia del mismo.
- b) **Son excepcionales**, pues la regla general es que los actos sean puros y simples, y como consecuencia de ello, quien las alegue deberá probarlas, son de interpretación restringida y no se presumen. Excepcionalmente, en el caso de la condición resolutoria tácita, el legislador la presume.
- c) **Requieren de una fuente que las cree**, que puede ser el testamento, la convención o la ley. La sentencia judicial no es fuente de modalidades salvo que la ley lo autorice expresamente, como ocurre en el artículo 904 del CC en que se faculta al juez para fijar un plazo para que el poseedor vencido restituya la cosa reivindicada.
- d) **La regla general es que en el ámbito patrimonial cualquier acto jurídico puede ser objeto de modalidades**. Por excepción la ley no lo permite respecto de ciertos negocios, por ejemplo, el usufructo no puede constituirse bajo condición o plazo alguno que suspenda su ejercicio de acuerdo al artículo 768 del CC. Lo contrario ocurre en derecho de familia, pues en él no se aceptan las modalidades, consecuencia ello de que no opera el principio de la autonomía de la voluntad en dicha materia, siendo normas de orden público.

Tema 10: Obligaciones a Plazo.

10.1 Toda obligación puede estar sometida a un plazo.

La regla general es que dentro del ámbito patrimonial cualquier obligación puede estar sometida a plazo. Podrían señalarse como excepciones, entre otros, el artículo 1192 del CC que prohíbe las modalidades respecto de la legítima rigurosa.

10.2 Reglamentación del plazo en el Código Civil.

El plazo está tratado en forma inorgánica en el CC:

- a) En el Título Preliminar, artículos 48 a 50 del CC, se dan las normas sobre las formas de computar los plazos.
- b) En las obligaciones a plazo, artículos 1494 a 1498 del CC.
- c) Al tratar de las asignaciones testamentarias a día.
- d) Distintas disposiciones hacen referencia al plazo extintivo, como modo de extinguir los contratos de tracto sucesivo, como el artículo 1950 del CC en el arrendamiento y el artículo 2163 del CC en el mandato.

10.3 Concepto de plazo.

El artículo 1094 del CC dispone: “Plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación”, definición que comprende al plazo suspensivo pero no al extintivo. Por esta razón es mejor definirlo como un acontecimiento futuro y cierto que suspende la exigibilidad o la extinción de un derecho y que produce sus efectos sin retroactividad.

10.4 Elementos del plazo.

Es un hecho futuro y cierto, éste último elemento es el que lo diferencia de la condición. De manera que cuando una obligación está sujeta a plazo el hecho necesariamente va a ocurrir, por lo que no existen plazos fallidos como ocurre con la condición. Por la misma razón, al definirlo, hemos dicho que suspende la exigibilidad, no el nacimiento del derecho.

El CC al tratar las asignaciones testamentarias a día analiza en qué casos esas asignaciones son condicionales o a plazo, lo que va a depender de la forma como jueguen los elementos incertidumbre y determinación. Sobre este punto, dos reglas facilitan bastante las cosas:

- i. Todas las asignaciones desde son condicionales, salvo las desde día cierto y determinado, que son plazos.
- ii. Todas las asignaciones hasta son plazos, salvo las hasta día incierto e indeterminado, que son condicionales.

En conformidad a estas reglas, la asignación desde día cierto y determinado da al asignatario, desde el momento de la muerte del testador, la propiedad de la cosa asignada y el derecho de enajenarla y tramitarla, pero no el de reclamarla antes que llegue el día, conforme al artículo 1084 del CC. Se trata de asignaciones sujetas a un plazo suspensivo, por ello, el derecho del asignatario

existe pero no es exigible. La asignación desde día cierto pero indeterminado es condicional, porque envuelve la condición de existir el asignatario ese día, de acuerdo al artículo 1085 del CC.

10.5 Clasificación de los plazos.

Los plazos se clasifican del modo siguiente:

Determinado e Indeterminado	El plazo será determinado cuando se sabe cuándo va a ocurrir el hecho que lo constituye. Es indeterminado cuando se sabe que el hecho va a ocurrir pero no se sabe cuándo.
Fatal y No Fatal	El plazo es fatal cuando por su solo cumplimiento se extingue irrevocablemente un derecho. No lo es cuando no obstante estar vencido el plazo puede ejercerse todavía válida y eficazmente el derecho, mientras no se acuse la rebeldía correspondiente. El artículo 49 del CC señala: “Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine el último día de dicho espacio de tiempo”. El artículo 64 del CPC dispone: “Los plazos que señala este código son fatales cualquiera sea la forma en que se exprese, salvo aquellos establecidos para la realización de actuaciones propias del tribunal. En consecuencia, la posibilidad de ejercer un derecho o la oportunidad para ejecutar el acto se extingue al vencimiento del plazo”. No es lo mismo fatal que no prorrogable, pues hay plazos que son fatales pero que el juez puede prorrogar, por ejemplo, los artículos 280 y 302 del CPC.
Expreso o Tácito	El tácito es el indispensable para cumplirlo. El expreso es el que estipulan las partes, conforme al artículo 1494 del CC. Tiene importancia esta clasificación para efectos de constituir en mora el deudor. El artículo 1551 del CC dispone: “El deudor está en mora cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla”.
	Será convencional si lo estipulan las partes; legal si lo establece la ley; y judicial si lo fija el juez. La regla general es que los plazos sean convencionales. Los legales son excepcionales en materia civil, por ejemplo, el plazo de veinticuatro horas en el pacto comisorio calificado del artículo 1879 del CC. Los plazos judiciales son excepcionales conforme al segundo inciso del artículo 1494 del CC que dispone: “No

Convencional, Legal y Judicial	podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designen, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación, sólo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros, sobre cuya inteligencia y aplicación discuerden las partes”. Respecto del denominado plazo de gracia, el artículo 1656 del CC dispone: “Las esperas concedidas al deudor impiden la compensación, pero esta disposición no se aplica al plazo de gracia concedido por un acreedor a su deudor”. No es más que una espera o prórroga que otorga el acreedor.
Continuo y Discontinuo	Plazo continuo o corrido es el que no se suspende durante los días feriados. Plazo discontinuo o de días hábiles es aquel que se suspende durante los feriados. La regla es que los plazos sean continuos. El artículo 50 del CC dispone: “En los plazos que se señalaren en las leyes, o en los decretos, o de tribunales o juzgados, se comprenderán aún los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así, pues en tal caso no se contarán los feriados”. La excepción más importante la encontramos en el artículo 66 del CPC que señala: “Los plazos de días que establece el presente código se entenderán suspendidos durante los feriados, salvo que el tribunal por motivos fundados haya dispuesto expresamente lo contrario”.
Suspensivo y Extintivo	Plazo suspensivo, primordial o inicial, es el que marca el momento desde el cual se empezará el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación. Plazo extintivo, resolutorio o final es el que por su cumplimiento extingue un derecho y la correlativa obligación.

10.6 Efectos del plazo.

Para estudiar esta materia es necesario distinguir entre plazo suspensivo y extintivo y volver a distinguir, en ambos casos, los efectos del plazo pendiente y del plazo cumplido.

10.6.1 Efectos del plazo suspensivo pendiente.

Pendiente el plazo el derecho ha nacido pero no es actualmente exigible. Las consecuencias de ello son las siguientes:

1. El acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación por no ser actualmente exigible, por lo que no corre prescripción en contra de él y no opera la compensación legal, conforme a los artículos 2514 y 1656 del CC.
2. Si el deudor paga antes, paga lo debido y, por lo mismo, no puede pedir la restitución, conforme al artículo 1495 del CC. El pago anticipado significa simplemente que ha renunciado

al plazo. Sin embargo el mismo artículo señala que esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones, los que no existen, pero lo que quiere decir es que no se aplica al caso del artículo 1085 del CC, esto es, a las asignaciones desde día cierto pero indeterminado, que se consideran condicionales, siendo la condición que el asignatario esté vivo el día en que se cumple el plazo.

3. El acreedor a plazo puede impetrar medidas conservativas, conforme a los artículos 1078 y 1492 del CC.
4. El derecho y la obligación a plazo se transmiten conforme al artículo 1084 del CC.

10.6.2 Efectos del plazo suspensivo vencido.

Vencido el plazo la obligación del deudor pasa a ser actualmente exigible, por lo que empieza a partir de ese momento a correr la prescripción, y la obligación puede extinguirse por compensación legal. Además, si el plazo es convencional, su solo cumplimiento constituye en mora al deudor, en conformidad al primer número del artículo 1551 del CC.

10.6.3 Efectos del plazo extintivo pendiente.

El acto o contrato produce todos sus efectos, como si fuera puro y simple.

10.6.4 Efectos del plazo extintivo vencido.

Se extingue el derecho por el solo ministerio de la ley, pero sin efecto retroactivo. En los contratos de tracto sucesivo cumplido el plazo se extingue el contrato, por ejemplo, en el arriendo, artículo 1950 del CC, y en el mandato, artículo 2163 del CC.

10.6.5 Extinción del plazo.

El plazo se extingue por tres causales:

- a) **Por su cumplimiento que se llama vencimiento.** Es la forma normal de extinguirse.
- b) **Por la renuncia.** Puede renunciar el plazo únicamente aquel en cuyo beneficio está establecido conforme al artículo 12 del CC. Lo normal será que lo sea a favor del deudor, y por esta razón el artículo 1497 del CC dice que el deudor puede renunciar al plazo, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario o que la anticipación del pago acarree al acreedor un perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar. En el caso del mutuo se observará lo dispuesto en el artículo 2204 del CC que señala que si el mutuo es con interés el mutuario no puede pagar antes, es decir, no puede renunciar al plazo porque no está establecido en su exclusivo beneficio sino que en beneficio de ambas partes. La norma tiene una excepción en el artículo 10 de la Ley No. 18.010 porque aun habiéndose convenido intereses en una operación de crédito de dinero el deudor puede pagar antes, siempre que pague los intereses hasta la fecha del vencimiento pactado.
- c) **Caducidad del plazo.** Caduca el plazo en los siguientes casos:

- i. Respecto del deudor constituido en quiebra o que se halle en notoria insolvencia, conforme al artículo 1496 del CC.
- ii. Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido considerablemente de valor. En este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo renovando o mejorando las cauciones.

Caducidad convencional.

Se produce cuando las partes en forma expresa acuerdan que el acreedor pueda exigir el cumplimiento inmediato y total de la obligación si el deudor incumple. Es muy corriente esta cláusula en los contratos en que el pago se debe ir haciendo en forma escalonada. La Corte Suprema la define diciendo que es el pacto en que las partes convienen anticipar el cumplimiento de una obligación que se ha diferido en el tiempo cuando el deudor incurre en alguna de las situaciones fácticas previamente acordadas, generando la caducidad del plazo que el deudor tenía para satisfacer la deuda, lo que implica que la obligación en ese momento se hace exigible y el acreedor queda facultado para ejercer las acciones que el ordenamiento jurídico le confiere para obtener el pago de su acreencia.

La caducidad convencional es lo que se llama hoy cláusula de aceleración, que ha creado numerosos problemas relativos al momento en que debe empezar a correr el plazo de prescripción cuando se ha estipulado dicha cláusula. La jurisprudencia se ha orientado en dos sentidos:

- i. **En primer lugar**, reiterados fallos han sostenido que debe distinguirse según sea la forma cómo se ha redactado la cláusula de aceleración. Si se ha convenido que ella opere ipso facto, la prescripción comenzará a correr desde que se produjo el incumplimiento, porque en ese momento se hizo exigible la totalidad de lo adeudado, la obligación a plazo se transformó en una obligación pura y simple. En cambio, si es facultativa, la situación es distinta porque la fecha en que se produce el incumplimiento determinará el momento desde el cual cada cuota es exigible y por lo mismo respecto de cada cuota la prescripción empezará a correr desde el respectivo incumplimiento.
- ii. **En segundo lugar**, también hay fallos que han sostenido que la cláusula de aceleración está establecida en beneficio del acreedor, y por consiguiente, aunque se trate de una cláusula ipso facto, es necesario para que la deuda se haga exigible que exista una manifestación expresa del acreedor, y por consiguiente, mientras ello no ocurra cada cuota será exigible desde la respectiva fecha de su vencimiento y desde allí se contará el plazo de prescripción de esa cuota. La cláusula de aceleración, conforme a una sentencia de la Corte Suprema, si bien se estableció en beneficio del acreedor, ella no contiene requisito de ejercicio alguno, por lo que debe entenderse que basta con cualquier declaración de voluntad del acreedor, por la que manifieste su intención de cobrar el total de la deuda como si fuere de plazo vencido. Debe entenderse que la caducidad

del plazo se produjo cuando se presentó la demanda de autos, sin que sea menester la notificación de ésta, por cuanto se trata de un acto unilateral y la cláusula no contempla tal requisito para que produzca sus efectos.

- **Forma de liquidar las operaciones de crédito de dinero que tengan vencimiento en dos o más cuotas y contengan cláusula de aceleración.**

El artículo 30 de la Ley No. 18.010 dispone: “Las operaciones de crédito de dinero o aquellas operaciones de dinero a que se refiere el artículo 26 que tengan vencimiento en dos o más cuotas y contengan cláusula de aceleración deberán liquidarse al momento del pago voluntario o forzado o de su reprogramación con o sin efecto novatorio, conforme a las siguientes reglas:

i. Las obligaciones no reajustables considerarán el capital inicial o el remanente al cual se añadirán los intereses corrientes o convencionales según sea el caso y las costas hasta el instante del pago o de la reprogramación.

Las obligaciones reajustables considerarán el capital al momento de contraer la obligación y éste o su remanente se pagará debidamente actualizado según la reajustabilidad pactada en su equivalente en moneda corriente al instante del pago o reprogramación, más los intereses y costas a que se refiere el número anterior”.

Unidad 4: Obligaciones Condicionales.

Tema 1: Concepto.

Conforme al artículo 1473 del CC son **obligaciones condicionales las que dependen de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no.** Por su parte, el artículo 1070 del CC define a la asignación condicional como aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. La doctrina, tomando en consideración las dos disposiciones citadas, define a la condición como un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho y su correlativa obligación.



Las condiciones están tratadas en el CC en tres partes:

- a) A propósito de las asignaciones testamentarias condicionales, artículos 1070 y siguientes del CC.
- b) las obligaciones condicionales, artículos 1473 y siguientes del CC.
- c) A propósito del fideicomiso, artículos 733 y siguientes del CC.

Tema 2: Elementos de la condición.

Son dos los elementos que debe cumplir la condición: primero, que sea un **hecho futuro**; y, segundo, que sea un **hecho incierto**.

1. Hecho futuro.

Esto quiere decir que el acontecimiento que la constituye debe ocurrir con posterioridad a la celebración del acto conforme a lo señalado en el segundo inciso del artículo 1071 del CC que dispone: “La condición que consiste en un hecho presente o pasado, no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o ha existido se mira como no escrita, si no existe o no ha existido, no vale la disposición”. El artículo 1072 del CC se pone en el caso de que la condición que se imponga para un tiempo futuro consista en un hecho que se ha realizado en vida del testador. Si el testador al tiempo de testar lo supo y el hecho es de los que pueden repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición. Si el hecho es de los que no pueden repetirse, se mirará la condición como cumplida. Si el testador no supo de la ocurrencia del hecho, se mirará la condición como cumplida cualquiera sea la naturaleza del hecho.

2. Hecho incierto.

Que el hecho sea incierto quiere decir que puede acontecer o no. Este elemento es el que permite diferencia la condición del plazo, pues, en este último, el hecho necesariamente va a ocurrir aunque no se sepa cuándo. La incertidumbre debe ser objetiva, o sea, no la pueden determinar las partes.

Tema 3: Clasificación de las condiciones.

La condición admite diversas clasificaciones:

a) Condiciones expresas y tácitas.

La condición es expresa cuando se establece en términos formales y explícitos; es tácita, en cambio, la que la ley da por establecida, como la condición resolutoria tácita del artículo 1489 del CC.

b) Condiciones suspensivas y resolutorias.

Es la clasificación más importante por la forma como incide en los efectos de los actos condicionales. El artículo 1479 del CC dispone: **“La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho; y, resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”**. La doctrina define a la condición suspensiva como el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho y su correlativa obligación. Asimismo, se señala que la condición resolutoria es el hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho y de la correlativa obligación. Un mismo hecho va a constituir una condición suspensiva o resolutoria, según el lugar que ocupen las partes. Lo importante en la distinción radica en que se la condición es suspensiva el derecho no nace, en cambio, cuando es resolutoria el derecho nace pero está expuesto a extinguirse si la condición se cumple.

c) Condiciones positivas y negativas.

El artículo 1474 del CC dispone: **“La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en acontecer una cosa, la negativa en que una cosa no acontezca”**. Esta distinción adquiere importancia para determinar cuando la condición debe entenderse cumplida o fallida. El artículo 1482 del CC dispone: *“Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado”*. También es importante para los efectos del artículo 1475 del CC que dispone: “La condición positiva debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o el orden público. Se mirarán

también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles”. Por su parte, el artículo 1476 del CC señala: *“Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple; si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho inmoral o prohibido, vicia la disposición”*.

d) Condiciones posibles e imposibles, lícitas e ilícitas.

Esta clasificación está contemplada en los artículos 1475, 1476 y 1480 del CC. La primera de dichas normas establece que la condición positiva debe ser física y moralmente **posible**, y en seguida señala que la físicamente **imposible** es la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, como tocar el sol con la mano. Por su parte, señala que la condición es moralmente imposible cuando el hecho que la constituye es prohibido por la ley, o es opuesto a las buenas costumbres o el orden público, por ejemplo, te doy mi auto si matas a mi amigo. También se mira como condición imposible la que está concebida en términos inteligibles. En cuanto a los efectos que producen estas condiciones, sus efectos los establecen los artículos 1476 y 1480 del CC.

Si la condición es **positiva imposible o ilícita**, sus efectos serán distintos según la condición sea suspensiva o resolutoria. Si es suspensiva se tiene por fallida lo que significa que el derecho no llegará a nacer. Si es resolutoria se tiene por no escrita, lo que significa que el derecho nace puro y simple.

Si la condición es **negativa de una cosa físicamente imposible**, la obligación es pura y simple; no se distingue entre condiciones suspensivas o resolutorias.

Si la condición es **negativa de un hecho ilícito vicia la disposición**, o sea, el acreedor condicional no va a poder exigirle pago. La sanción es curiosa y se explica porque se estima inmoral que se reciba un pago por no cometer un hecho ilícito.

e) Condiciones determinadas e indeterminadas.

Condición determinada es aquella en que el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada. **Condición indeterminada** es aquella en que no se fija una época para la ocurrencia del hecho. La condición indeterminada plantea el problema de saber cuánto tiempo habrá que esperar para saber si se cumple o no la condición. No merece dudas que el plazo de caducidad de las condiciones es de diez años, pues ese es el tiempo máximo establecido por el CC para dar estabilidad a todas las situaciones jurídicas.

f) Condiciones potestativas, casuales y mixtas.

El artículo 1477 del CC dispone: *“Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor; casual la que depende de la voluntad de un tercero o del acaso; mixta la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o*

de un acaso". Hay una omisión en el CC en cuanto a que también es condición mixta la que en parte depende de la voluntad del deudor y en parte de la voluntad de un tercero o del acaso.

Las condiciones potestativas, a su vez, pueden ser de dos clases: simplemente potestativas o meramente potestativas. Son condiciones simplemente potestativas las que dependen de un hecho voluntario, causado, del acreedor o del deudor. Por su parte, las condiciones meramente potestativas son aquellas que dependen del mero arbitrio de las partes. Se ha fallado que no constituye condición meramente potestativa de la voluntad del deudor la cláusula según la cual el deudor pagará un saldo de precio cuando tenga disponibilidad de dineros. Esta clasificación se desprende del artículo 1478 del CC que dispone: "Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consiste en la mera voluntad de la persona que se obliga". Es importante entender que lo que se anula es la obligación y no la condición. También es fundamental tener en consideración que las únicas condiciones que anulan la obligación son las meramente potestativas de la voluntad del deudor, porque en ellas no hay voluntad seria de obligarse; las meramente potestativas de la voluntad del acreedor son válidas. Además, las únicas condiciones meramente potestativas que producirían la nulidad de la obligación serían las meramente potestativas de la voluntad del deudor y suspensivas; las resolutorias serían válidas. Lo anterior porque en las condiciones resolutorias la obligación ha podido formarse y producir todos sus efectos, ya que la condición resolutoria no afecta a la existencia de la obligación sino únicamente su extinción. Además, el mismo CC las acepta, como ocurre en las donaciones revocables en que el donante se reserva la facultad de recobrar la cosa donada cuando quiera y en el pacto de retroventa. En contra de esta opinión está la de Abeliuk, para quien no valen las meramente potestativas de la voluntad del deudor, ni las suspensivas ni las resolutorias, porque nada autoriza para hacer esta distinción en circunstancias que el artículo 1478 del CC no la establece, y porque dicha disposición está ubicada antes del artículo 1479 del CC, que es la que hace la distinción entre condiciones suspensivas y resolutorias, lo que demuestra que es aplicable a ambas. Además sostiene que el fundamento de la nulidad de la obligación es el mismo en ambas condiciones.

Tema 4: Reglas comunes a las condiciones.

Estas reglas comunes dicen relación con los siguientes aspectos:

4.1 Estados en que puede encontrarse la condición.

Toda condición puede encontrarse en tres estados: pendiente, fallida y cumplida, como a continuación se detalla:

Condición pendiente	Que esté pendiente la condición significa que aún no ocurre, pero puede ocurrir el hecho que la constituye. Los efectos van a ser diferentes según se trate de una condición suspensiva o resolutoria, como se verá después.
Condición fallida	El artículo 1482 del CC dispone: “Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado”. Luego, las reglas serán distintas según la condición sea positiva o negativa. Si es positiva, falla la condición cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella o, cuando ha expirado el tiempo dentro del cual ha debido verificarse y no se ha verificado. Si la condición es negativa, falla cuando el hecho se verifica.
Condición cumplida	Para saber cuando se cumple la condición habrá que distinguir según sea positiva o negativa. Si la condición es positiva se cumple cuando se verifica el hecho que la constituye. Si la condición es negativa, para saber cuando se cumple la condición habrá que ver si es determinada o indeterminada. Si es determinada, la condición se cumple cuando expira el plazo dentro del cual debía realizarse el hecho, si que se realizara. Si es indeterminada, habría que esperar los diez años según hemos visto, y si en este plazo no pasa nada, se tiene por cumplida la condición.

4.2 Forma como deben cumplirse.

El artículo 1483 del CC dispone: “La condición debe cumplirse del modo que las partes han probablemente entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido las partes. Cuando, por ejemplo, la condición consiste en pagar una suma de dinero a una persona que está bajo tutela o curaduría, no se tendrá por cumplida la condición si se entrega a la misma persona y ésta lo disipa”. La norma está en perfecta armonía con el artículo 1560 del CC que dispone: “Conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Preciado lo anterior, el artículo 1484 del CC dispone: “Las condiciones deben cumplirse literalmente, en la forma convenida”. O sea, determinada la forma como las partes querían que se cumpliera, debe cumplirse de esa manera y no se otra. No puede cumplirse por equivalencia. Excepciones a esta regla se encuentran en el segundo número del artículo 250 y en el artículo 1093 del CC en materia de asignaciones modales.

El cumplimiento ficto de la condición está contemplado en el segundo inciso del artículo 1481 del CC. Se trata de que la persona que debe dar la prestación si se cumple la condición, deudor condicional, se vale de medios ilícitos para que ésta no se cumpla. La ley lo sanciona teniendo por cumplida la condición. El artículo 1481 del CC dispone: “La regla del precedente inciso primero se aplica aun a las disposiciones testamentarias. Así, cuando la condición es un hecho que depende la voluntad del asignatario, y de la voluntad de otra persona, y deja de cumplirse por algún accidente que la hace imposible, o porque la otra persona de cuya voluntad depende no puede o no quiere cumplirla, se tendrá por fallida, sin embargo de que el asignatario haya estado por su parte dispuesto a cumplirla. Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento no coopere a él, se tendrá por cumplida”. Es aplicación del principio de que nadie se puede favorecer con su propio dolo. Algunos autores estiman que no cabe el cumplimiento ficto si la obligación es potestativa de la voluntad del deudor, pues en tal caso él es dueño de la condición, como dicen los comentaristas franceses y, en tal carácter, puede impedir el cumplimiento de la condición que depende de su sola voluntad, sin hacerse acreedor a ninguna sanción. Frente a esta afirmación Peñailillo es de opinión que la norma debe aplicarse aunque se trate de una condición simplemente potestativa de la voluntad del deudor, si el deudor impidió el cumplimiento para sustraerse del cumplimiento de la obligación, porque al ser ilícito el fin, el medio también lo es. El mismo profesor plantea en el artículo recién citado varios otros problemas en relación con el cumplimiento ficto de la condición, como a continuación se señalan:

- **Los términos en que está consagrada esta institución en el inciso segundo del artículo 1481 del CC** son más propios de las asignaciones condicionales, lo que puede hacer dudar que tenga aplicación en las obligaciones condicionales. La mayoría de la doctrina sostiene que es de aplicación general por la historia fidedigna de la disposición ya que los proyectos la contemplaban dentro de las obligaciones condicionales; y porque la norma se justifica plenamente tanto para las asignaciones condicionales como para las obligaciones condicionales. Sin embargo se refuta sobre la base del texto del artículo 1481 del CC y sobre la base de que es una sanción y que además constituye una excepción, pues la regla es que las condiciones deben cumplirse en forma efectiva y, por lo mismo, debe dársele una interpretación restringida.
- En cuanto al fundamento de la institución se han dado dos soluciones. **Primero**, estimar que lo que se pretende es sancionar la mala fe del deudor, aplicándole el principio de que nadie se puede aprovechar de su propio dolo, o bien, **segundo**, que es una forma especial de indemnizar a la víctima de un hecho ilícito. Si se estima que es una sanción, la condición debe tenerse por cumplida pues de todas formas el deudor actuó de mala fe. En cambio, si se considera como una forma de indemnización, la conclusión debe ser la contraria, porque la actitud del deudor no es la que produjo el daño que sólo vino a resultad de un hecho extraño.
- Otro problema que plantea el artículo 1481 del CC es resolver **qué se entiende por medio ilícitos**. Nos parece que debe considerarse como ilícito cualquier hecho que en abstracto

pudiera no ser reprobable, pero que dada la finalidad con que se realiza, evitar el cumplimiento de la condición, debe estimarse ilícito. Ello pues no merece duda que lo que pretende la ley es sancionar el fraude, y la realización de un hecho aparentemente inofensivo para obtener un resultado indebido constituye, en nuestro entendimiento, una forma de fraude civil.

- Otro problema consiste **en determinar si es necesaria la existencia de dolo en el deudor condicional o basta una actitud culpable o negligente**. Creemos que si solamente hubo culpa del deudor, no rige la norma puesto que lo que se persigue con ella es frustrar la pretensión maliciosa del deudor que actúa con el propósito o finalidad de impedir el cumplimiento de la condición.
- **Se discute si se aplica el cumplimiento ficto en el caso en que la condición establecida por las partes constituya al mismo tiempo un requisito establecido por la ley para que se pueda cumplir la obligación o ejecutar el negocio**. Algunos afirman que no, porque una parte no puede llevar a la otra a la contravención de la ley, además de que en la práctica la autoridad correspondiente no autorizaría esa operación. Otros estiman que cuando la obligación, por imposibilidad legal o administrativa, no pueda cumplirse, el acreedor no podrá exigir el cumplimiento de la obligación en especie pero sí el cumplimiento por equivalencia, demandando la correspondiente indemnización.
- Otra duda **es si cabe el cumplimiento ficto cuando el deudor condicional ha adoptado una actitud pasiva, es decir, no despliega ninguna actividad**. Aparentemente la respuesta debería ser negativa toda vez que la disposición al hablar de medios ilícitos pareciera exigir un actuar en el deudor. Sin embargo, si esta inactividad tiene por objeto justamente que la condición no se cumpla, no vemos inconvenientes en la aplicación de la institución.
- Finalmente, **cabe preguntarse qué ocurre en el caso en que sea el acreedor quien despliegue medios para que la condición se cumpla, con el objeto que nazca su derecho y demandarlo**. Algunos sostienen que por tratarse de un vacío legal, no tratado por el legislador, deberá aplicarse la norma del artículo 1481 del CC, o sea, por haber adoptado el acreedor una conducta tendiente a que la condición se cumpla, si se cumplió realmente, y fue debido a esa conducta del acreedor, aplicar la regla significaría que la condición se tendrá por fallida.

Por otra parte, cabe consignar que el principio de la indivisibilidad de la condición se encuentra establecido en el primer inciso del artículo 1485 del CC que dispone: “No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional, sino verificada la condición totalmente”.

4.3 Caducidad de las condiciones.

Para saber cuando falla la condición será necesario distinguir entre condiciones positivas y negativas. El efecto de la caducidad, si la condición es suspensiva y falla, es que el acreedor condicional no va a llegar a adquirir el derecho condicional; y, si es resolutoria, se consolida el derecho en poder del deudor condicional, que ya nada deberá restituir.

4.4 Retroactividad de las condiciones cumplidas.

Que el cumplimiento de la condición opere retroactivamente significa que una vez cumplida, los efectos del acto o contrato se retrotraerán al momento en que dicho acto se celebró. Si la condición es suspensiva, se considera que el acto jurídico ha tenido siempre el carácter de puro y simple. Si la condición es resolutoria y se cumple, se extingue o se resuelve el derecho. Las partes quedan., al operar la retroactividad, como si jamás hubieran estado vinculadas entre sí. Luego el deudor condicional debe restituir todo lo que recibió al momento de celebrarse el acto o contrato. La retroactividad es una ficción destinada a proteger al acreedor condicional de los actos o gravámenes que pudiera haber realizado el deudor condicional mientras la condición estuvo pendiente.

En Chile falta una norma expresa, como ocurre en el derecho francés, que reconozca el efecto retroactivo, lo que genera problemas pues hay casos en que se acepta y otros en que se rechaza el efecto retroactivo de la condición.

Los siguientes son los casos en que se acepta el efecto retroactivo de la condición:

- El artículo 1486 del CC por cuanto esta norma señala que el acreedor tiene derecho a los aumentos y mejoras de la cosa, ocurridos cuando estaba pendiente la condición.
- El artículo 2413 del CC pues da pleno valor a la hipoteca desde la fecha de su inscripción en el Registro del CBR una vez cumplida la condición suspensiva bajo la cual se otorgó.
- El artículo 1487 del CC porque cuando se cumple la condición resolutoria el deudor debe restituir todo lo que hubiere recibido con tal motivo.
- Los artículos 1490 y 1491 del CC en cuanto privan de valor a las enajenaciones hechas por el deudor en el tiempo intermedio, a menos que se cumplan determinados requisitos.

Los siguientes son los casos en que se rechaza el efecto retroactivo de la condición:

- El artículo 1488 del CC, pues de acuerdo a dicha disposición cumplida una condición resolutoria no se deben restituir los frutos producidos por la cosa mientras estuvo pendiente la condición; si se aceptare la retroactividad, el deudor condicional debería, al cumplirse la condición, restituir la cosa y los frutos.
- El tercer inciso del artículo 1078 del CC que contiene la misma idea anterior en las asignaciones testamentarias.
- El artículo 758 del CC en el fideicomiso, por cuanto autoriza al fiduciario para mudar la forma de la propiedad fiduciaria y si la condición operara con efecto retroactivo no podría existir esta norma. También se acepta que cumplida la condición y operada la restitución al fideicomisario, subsisten los arrendamientos hechos por el fiduciario.
- Los artículos 1490 y 1491 del CC pues de acuerdo a dichas disposiciones los actos de enajenación realizados por el deudor estando pendiente la condición generalmente valen, lo que no sería posible si la condición operara con efecto retroactivo.

Se discute si en los casos no reglamentados en la ley opera el **efecto retroactivo**. Hay quienes sostienen que el CC acoge en general la retroactividad y que aquellas disposiciones de excepción sin meras limitaciones al principio habitual, de manera que conforme a él deben resolverse las situaciones no previstas por la ley. Otros sostienen que la retroactividad constituye la excepción en nuestra legislación y, como ficción que es, no puede extenderse a otros casos que los previstos expresamente. En general no podemos decir en términos generales que la condición tiene efecto retroactivo o que la condición no tiene efecto retroactivo, sino que en cada caso en particular podremos pensar si este efecto proviene o no de la retroactividad.

4.5 Riesgos de la cosa debida bajo condición.

Se trata de resolver el problema de quien soporta la pérdida de la especie o cuerpo cierto debido que se destruye fortuitamente mientras pende la condición, y para el caso de que la obligación condicional incidiera en un contrato bilateral, determinar si subsiste la obligación de la contraparte.

El artículo 1486 del CC dispone: “Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación”. Se afirma que la norma es defectuosa porque la obligación no puede extinguirse porque no ha existido nunca. Lo que ocurre es que deja sin objeto una de las obligaciones que puede posteriormente nacer y que, por lo tanto, deja sin causa la otra obligación correlativa. Podríamos decir que más que se extinga la obligación se

extingue el contrato, o sea, no sólo se extingue esta obligación sino también la de la contraparte, porque carecería de causa.

En esta materia, como veremos en su oportunidad, se separó el CC de la regla general contemplada en el artículo 1550 del CC según el cual el riesgo es del acreedor. Y justo es que así sea pues pendiente la condición la cosa es del deudor y las cosas se pierden para su dueño. Lo que venimos diciendo rige para la destrucción total y fortuita de la especie o cuerpo cierto debida bajo condición. Si la destrucción es culpable el deudor es obligado al precio y a la indemnización de perjuicios conforme al artículo 1486 del CC. Si la destrucción es parcial y fortuita, rige la regla del segundo inciso del artículo 1486 del CC según el cual la cosa deberá recibirla el acreedor en el estado en que se encuentre, sin derecho a la rebaja en el precio. Ahora, si es parcial y culpable, la misma disposición señala que el acreedor tendrá un derecho alternativo a que se rescinda, debería decir resuelva, el contrato o que se le entregue la cosa en el estado en que se encuentra y además, en ambos casos, tendrá derecho a indemnización de perjuicios. Finalmente, el inciso final del artículo 1486 del CC dispone: “Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o según la convención se destina, se entiende destruir la cosa”. El ejemplo típico es el caballo que se rompe una pata.

Tema 5: Efectos de las condiciones.

Para estudiar los efectos de las condiciones debemos distinguir entre condiciones suspensivas y resolutorias, y, además, ver los efectos de cada una de ellas en los tres estados en que puede encontrarse: pendiente, cumplida y fallida.

5.1. Efecto de la condición suspensiva pendiente.

i. No nace el derecho ni la obligación correspondiente.

Por definición la condición suspensiva obsta el nacimiento del derecho. No ha derecho ni obligación. Consecuencias que derivan de este efecto son las siguientes:

- a) El acreedor no puede exigir su cumplimiento, conforme al primer inciso del artículo 1485 del CC que dispone: “No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente”.
- b) Si el deudor paga antes del cumplimiento paga lo no debido y puede pedir restitución, conforme al segundo inciso del artículo 1485 del CC que dispone: “Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido”.
- c) El acreedor condicional no puede ejercer la acción pauliana que consagra el artículo 2468 del CC pues tal acción corresponde a los acreedores, calidad que todavía no tiene porque no se ha cumplido la condición.

- d) No hay obligación actualmente exigible, y por ello: primero, la prescripción no está corriendo; segundo, no se puede novar esa obligación; tercero, no puede operar la compensación; y, cuarto, el deudor no está en mora.

ii. El vínculo jurídico existe.

El acto o contrato se generó, si bien el derecho y la correlativa obligación no han nacido. Como consecuencias de ello tenemos las siguientes:

- a) Al contratarse la obligación deben reunirse todos los requisitos de existencia y validez del contrato.
- b) El deudor no puede retractarse pues no puede desvincularse de su propia voluntad, en caso contrario, vulneraría el artículo 1545 del CC.
- c) La obligación condicional se rige por la ley vigente al momento de otorgarse el contrato, de conformidad al artículo 22 de la LER.

iii. El acreedor tiene una simple expectativa.

El derecho no nace mientras no se cumpla la condición; pero existe una expectativa de derecho en el acreedor condicional, que la ley respeta. Algunos dicen que hay un germen de derecho o derecho en potencia o latente. Las consecuencias de ello son las siguientes:

- a) El acreedor condicional puede impetrar providencias conservativas mientras esté pendiente la condición, conforme a los artículos 1492, 1078 y 761 del CC.
- b) Este germen de derecho lo transmite el acreedor condicional a sus herederos, conforme a lo señalado en el primer inciso del artículo 1492 del CC. Ello no rige en dos casos: primero, en las asignaciones testamentarias condicionales porque el asignatario tiene que existir al momento en que fallece el causante conforme a los artículos 1078 y 962 del CC; y, segundo, respecto del donatario condicional por ser la donación un contrato intuitu personae de donde se sigue que tiene que estar vivo para adquirir lo donado.

5.2 Efectos de la condición suspensiva fallida



Si la condición falla, quiere decir que **el derecho y la correlativa obligación no van a nacer, desapareciendo, de esa manera, la expectativa del acreedor condicional.** Por esta razón, si había

medidas conservativas, éstas quedan sin efecto. Todos los actos de administración o de disposición celebrados por el deudor condicional en el tiempo intermedio quedan firmes.

5.3 Efectos de la condición suspensiva cumplida.

Los efectos son exactamente los contrarios a los señalados para la condición suspensiva pendiente, y son los siguientes:

- i. Nace el derecho y la obligación correspondiente.
- ii. El acreedor puede exigir su cumplimiento.
- iii. Si el deudor paga, el pago es válido y no puede repetir, conforme al segundo inciso del artículo 1485 del CC.
- iv. Según algunos se produce el efecto retroactivo, lo que es a lo menos discutible
- v. Debe el deudor entregar la cosa debida condicionalmente en el estado en que se halle, favoreciendo al acreedor los aumentos y soportando las pérdidas siempre que éstas últimas sean fortuitas, conforme al artículo 1486 del CC.
- vi. Por regla general no se entregan los frutos que la cosa produjo en el tiempo intermedio, mientras la condición estuvo pendiente, conforme a los artículos 1078 y 1488 del CC.
- vii. Los actos de administración, arrendamiento por ejemplo, celebrados por el deudor se mantienen, sin perjuicio de que el cumplimiento de la condición importe una causal de extinción del contrato conforme al tercer número del artículo 1950 del CC. Este principio se desprende del artículo 758 del CC que otorga al propietario fiduciario, que es un deudor condicional, la facultad de administrar.

Tema 6: Efectos de la condición resolutoria.

La condición resolutoria es un hecho futuro e incierto del cual depende la extinción de un derecho. Para estudiar los efectos de la condición resolutoria tenemos que señalar que esta condición en nuestro derecho positivo puede revestir tres modalidades: primero, condición resolutoria ordinaria; segundo, condición resolutoria tácita; y, tercero, pacto comisorio.



Tema 7: Condición Resolutoria Ordinaria.

7.1 Concepto.

Es el hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación contraída, verificado el cual se extingue un derecho y la correlativa obligación. También se dice que es aquella condición estipulada por los contratantes o expresada por el testador, que consiste en un hecho cualquiera que no sea la infracción o inejecución de obligaciones contraídas.

7.2 Efectos de la condición resolutoria ordinaria.

Estos efectos se deben estudiar en los tres estados en que se puede encontrar la condición: pendiente, cumplida o fallida.

7.3 Condición resolutoria ordinaria pendiente.

Mientras está pendiente la condición el acto o contrato produce todos sus efectos igual que si fuera puro y simple. Por consiguiente, las partes pueden exigir el cumplimiento de las obligaciones. El que tiene el dominio de una cosa sujeta a condición resolutoria puede ejercer los derechos que le otorga ese título, igual que si fuere propietario puro y simple. Naturalmente que su derecho está expuesto a extinguirse si se cumple la condición. Puede realizar actos de administración, enajenación y gravamen sujetos a resolverse si se cumple la condición. Si se trata de un asignatario condicional resolutorio, se produce la inmediata delación de la herencia conforme al artículo 956 del CC y puede incluso pedir la partición. El deudor condicional tiene la obligación de cuidar la cosa y conservarla como buen padre de familia, para restituirla al acreedor si se cumple la condición, conforme a los artículos 1486 y 758 del CC. Por su parte, el acreedor condicional podrá impetrar providencia conservativas conforme a los artículos 1492 y 761 del CC.

7.4 Condición resolutoria ordinaria fallida.

Si la condición resolutoria falla el derecho del deudor condicional se consolida. Pasa a ser dueño puro y simple y los actos realizados mientras estuvo pendiente la condición quedan firmes. Si se habían solicitado medidas conservativas por el acreedor condicional éstas se extinguen.

7.5 Condición resolutoria ordinaria cumplida.

Cumplida la condición resolutoria quien adquirió derechos sujetos a ella se extinguen, conforme al artículo 1487 del CC que dispone: **“Cumplida la condición resolutoria deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta hay sido puesta a favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere”**, norma que concuerda con el artículo 1479 y el noveno número del artículo 1567 del CC.

Por consiguiente, el deudor condicional debe restituir lo que recibió sujeto a esa condición. Por regla general no se aplican a estas restituciones las normas sobre prestaciones mutuas porque el CC da reglas propias. El artículo 1488 del CC establece que no se restituyen los frutos salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario. En materias de expensas o deterioros rige el artículo 1486 del CC que señala que el acreedor se aprovecha de las mejoras y sufre los deterioros producidos por caso fortuito.

Respecto de los actos de administración que pueda haber ejecutado el deudor condicional, ellos caducan y se extinguen. En cuanto a las enajenaciones y gravámenes, esta materia está tratada en los artículos 1490 y 1491 que veremos después.

7.6 Forma de operar la condición resolutoria ordinaria.

La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho, no requiere de declaración judicial, conforme al texto expreso de los artículos 1487 y 1479 del CC. Si las partes van a pleito el tribunal sólo se limitará a constatar que la condición operó y los efectos se producen a partir del momento en que se cumple. Es importante que opere de pleno derecho porque produce efectos universales, pudiendo oponerse la resolución a cualquier persona que pretenda hacer valer derechos emanados del contrato respectivo. Del mismo modo, el tercero favorecido puede invocar la resolución.

Tema 8: Condición Resolutoria Tácita.

8.1 Concepto.

Es la que deriva del artículo 1489 del CC y se define como la que va envuelta en todo contrato bilateral para el caso de no cumplirse por la otra parte lo pactado. El artículo 1489 del CC dispone: “En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado”.

8.2 Efectos de la condición resolutoria tácita.

Está establecida en el artículo 1489 del CC y es aquella que va envuelta en todo contrato bilateral, y en que el hecho futuro e incierto que puede provocar la extinción del derecho de una de las partes es el incumplimiento de sus obligaciones. Se funda en la falta de cumplimiento del deudor. Se ha fallado que para encontrarse frente a una condición resolutoria tácita es menester que el evento futuro e incierto que constituye la obligación sea necesariamente, la falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones que una de las partes contrajo en virtud del contrato bilateral. En consecuencia, cualquier otro evento futuro e incierto, aun cuando él constituya la falta de cumplimiento de un hecho que se atribuya a un tercero, debe ser calificado como constitutivo de una condición resolutoria ordinaria. El incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral da a la otra parte un derecho alternativo para solicitar o el cumplimiento o la resolución, y, en ambos casos, con indemnización de perjuicios.

8.3 Fundamento de la condición resolutoria tácita.

Se dan diversas explicaciones: **equidad, voluntad presunta de las partes, falta de causa, interdependencia de las prestaciones de un contrato bilateral, forma de indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento**, etc.

Una sentencia de la Corte Suprema, **apoyándose en la equidad**, resolvió que los fundamentos que inspiran la disposición del artículo 1489 del CC son de equidad y justicia, y no son otros que subentender o presumir que en los contratos bilaterales cada una de las partes consiente en obligarse a condición de que la otra se obligue a su vez con ella, o sea, la reciprocidad de la obligaciones acarrea necesariamente la de las prestaciones.

Otros estiman que el fundamento de la condición resolutoria se encuentra en la **voluntad presunta de las partes** porque vista en la condición resolutoria tácita una presunción legal de voluntad de los contratantes, la buena lógica forense nos enseñará a incluirla entre las instituciones jurídicas fundadas en consideraciones de conveniencias más que sobre principio de equidad natural, por poder alguna vez expresar una afirmación contraria a la verdad del hecho no tiene su justificación en la equidad, sino en las necesidades de la vida social.

Según algunos el fundamento de la condición resolutoria tácita estaría en el hecho de que si en un contrato bilateral **una de las partes no cumple con sus obligaciones**, la obligación del otro contratante carecería de causa. Sin embargo, se argumenta en contra de esta opinión señalándose que de faltar a causa el contrato sería nulo, por lo que el contratante diligente no podría pedir su cumplimiento.

También se ha dicho que la resolución. Sin embargo, esta explicación carece de precisión y no da cuenta de las diferencias **sería una consecuencia de la interdependencia de las obligaciones nacidas del contrato sinalagmático** que separan la resolución y la teoría de los riesgos.

Algunos concluyen que, en realidad, la **resolución judicial es un modo de reparación del perjuicio que causa al acreedor el incumplimiento de la obligación del deudor**, al dispensarle al acreedor de cumplir con su propia obligación o al permitirle recuperar la prestación por él efectuada, a resolución se presenta como un modo de reparación de mayor eficacia.

Finalmente, para otros el fundamento del artículo 1489 del CC **está en que cada parte ha contratado bajo una presunción real, efectiva, de que su contraparte habrá de cumplir con su obligación y así, aquella podrá obtener la ventaja que se propuso y en consideración de la cual consintió en obligarse**. Ahora bien, si la contraparte no cumple, esta presunción, que es supuesto del contrato, falla, y es por esto que la ley autoriza para pedir la resolución.

8.4 Características de la condición resolutoria tácita.

- i. Es un tipo de condición resolutoria.
- ii. Es tácita, puesto que el legislador la subentiende en todo contrato bilateral, por ello, es un elemento de la naturaleza y, por lo mismo, renunciable.
- iii. Es negativa, consiste en que no ocurra un hecho, que una de las partes no cumpla su obligación.
- iv. Es simplemente potestativa, pues depende de un hecho voluntario del deudor.
- v. No opera de pleno derecho, sino que requiere de declaración judicial.

8.5 Requisitos de la condición resolutoria tácita.

a) Que se trate de un contrato bilateral.

En este sentido se inclina la mayor parte de la doctrina. Claro Solar, por su parte, cree que opera aún en los contratos unilaterales por las siguientes razones:

- El artículo 1489 del CC sólo dice que la condición resolutoria tácita va envuelta en los contratos bilaterales, pero no excluye la posibilidad de que también pueda darse en los unilaterales.
- Varias disposiciones demuestran que el CC no ha entendido restringida la condición resolutoria tácita exclusivamente a los contratos bilaterales, por ejemplo, el artículo 2177 del CC, en materia de comodato, no obstante ser un contrato unilateral, otorga al comodante la facultad de solicitar la restitución de la cosa prestada aun antes del vencimiento del plazo cuando el comodatario no la destina al uso convenido.

Sin embargo, la tesis de Claro Solar no ha encontrado acogida en nuestra doctrina por las siguientes razones:

- El propio tenor literal del artículo 1489 del CC que habla de contratos bilaterales.
- Tratándose de los contratos unilaterales, el CC ha ido resolviendo en cada caso particular, lo que ocurre cuando el deudor no cumple.
- El fundamento de la condición resolutoria tácita radicaría según algunos en la interdependencia de las prestaciones, lo que sólo puede ocurrir en los contratos bilaterales.

La jurisprudencia se ha inclinado definitivamente por la tesis de que sólo procede la acción resolutoria en los contratos bilaterales. Se ha fallado que no procede la resolución si el subastador no consigna el precio en la oportunidad establecida en las bases.

La resolución también opera en los contratos de tracto sucesivo, pero pasa a llamarse terminación porque sus efectos no operan retroactivamente sino sólo para el futuro en razón de que las prestaciones de una de las partes no se pueden devolver, por ejemplo, en el arrendamiento, el arrendatario no podría devolver el goce de la cosa. Por tal razón, la resolución del contrato va a afectar solamente a la etapa no cumplida produciendo más bien el término del contrato en el estado de cumplimiento en que se encuentra.

La resolución no tiene lugar en la partición. Es corriente que en una partición se produzcan alcances en contra de alguno de los comuneros pero si no se pagan esos alcances no habrá lugar a la resolución de la partición, como unánimemente lo señala la doctrina. Las razones que se dan es que no se trata de un contrato bilateral, y porque ello se opone al efecto declarativo de la partición, contemplado en el artículo 1344 del CC, que supone que lo adjudicado a cada comunero deriva directamente del causante y no del acto de partición. El artículo 1489 del CC es doblemente excepcional: primero, porque da al acto el carácter de condicional; y, segundo, porque presume la condición; luego debe darse a la norma una interpretación restringida aplicable únicamente al caso regulado, que es el de los contratos bilaterales. Asimismo, el artículo 1348 del CC hace aplicables a la partición acciones propias de los contratos, como la nulidad y la rescisión, pero nada dice de la resolución, lo que demuestra claramente su intención de excluir esta acción. Por último, el artículo 662 del CPC estableció una hipoteca legal cuando en las particiones se adjudica un inmueble a un comunero y se producen alcances en su contra que superan el exceso a que se refiere el artículo 660 del CC. Se afirma por algunos que esta hipoteca la estableció el legislador justamente porque los comuneros carecían de acción resolutoria para el caso de que el comunero adjudicatario no pagare la diferencia adeudada.

b) Incumplimiento imputable de una de las partes.

El incumplimiento de una de las partes constituye justamente el hecho condicional. Nótese que el incumplimiento tiene que ser imputable al deudor, esto es, debido a su dolo o culpa. Este requisito se desprende del mismo artículo 1489 del CC que establece que producido el incumplimiento la otra parte puede pedir el cumplimiento o la resolución, en ambos casos, con indemnización de perjuicios, y precisamente uno de los requisitos para que opere la indemnización de perjuicios es que el deudor esté en mora conforme al artículo 1557 del CC, y uno de los requisitos de la mora es el dolo o la culpa. Se da también como argumento que el artículo 1546 del CC según el cual los contratos deben cumplirse de buena fe, de donde se sigue que si el deudor no puede cumplir por un hecho ajeno a su voluntad, sería contrario a la equidad sancionarlo con la resolución del contrato.

Se discute si cualquier incumplimiento es suficiente para demandar la resolución, o sea, si procede la resolución por incumplimientos de poca monta o incluso de una obligación secundaria. Tradicionalmente se ha enseñado que al no distinguir la ley, cualquier incumplimiento sería suficiente. Claro Solar discrepa y piensa que el incumplimiento de una obligación secundaria no es

suficiente para pedir la resolución, fundando su opinión en la equidad. Otros fundan el mismo argumento en que no hay interés en obrar si la acción de resolución se funda en un incumplimiento insignificante, habiendo fallos que lo sustentan.

En cuanto a la procedencia de la resolución en caso de ser parcial el incumplimiento, no hay dudas de que ello corresponde, tanto es así, que el CC lo permite expresamente en el segundo inciso del artículo 1875 del CC al disponer: **“El comprador a su vez tendrá derecho para que se le restituya la parte que hubiere pagado del precio”**. En esta parte hay unanimidad de la doctrina y de la jurisprudencia.

Con respecto al incumplimiento recíproco de los contratantes, o sea, cuando ambas partes incumplen, en rigor, no cabe la resolución. Así, en general lo ha resuelto la jurisprudencia. Sin embargo, en algunos casos, se ha dado lugar a la resolución pero sin indemnización de perjuicios, por faltar el requisito de la mora, con el objeto de no dejar amarradas a las partes a un contrato que ninguno ha demostrado interés en cumplir.

c) Que quien la invoca haya a su vez cumplido o esté llano a cumplir su propia obligación.

Este requisito no aparece del artículo 1489 del CC sino que derivaría del artículo 1552 del CC que dispone: **“En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”**. Por consiguiente, si quien demanda la resolución no ha cumplido con su propia obligación, se le opondrá por el demandado la excepción de contrato no cumplido; en ese sentido la doctrina.

Algunos autores sostienen que no es necesario para que opere la resolución la mora del deudor porque estiman que no se puede aplicar el artículo 1552 del CC pues ella no consagra la excepción de contrato no cumplido, entendiendo que ésta excepción sólo se da al demandado como medio de defensa cuando se le exige el cumplimiento, más no es defensa apta para enervar la acción resolutoria, ya que no es congruente con ésta.

d) Que sea declarada judicialmente.

Es el último requisito para que proceda la acción resolutoria tácita. Vemos de inmediato una diferencia notable con la condición resolutoria ordinaria, en que, como lo hemos explicado, opera de pleno derecho. Nuestro CC no lo dice en forma expresa, sin embargo, fluye con absoluta claridad del propio tenor literal del artículo 1489 del CC. Se suele dar como argumento que de operar la resolución de pleno derecho no se ve cómo podría el acreedor usar la opción que le otorga la disposición para pedir el cumplimiento. No parece lógico que pueda pedirse el cumplimiento de una obligación ya extinguida. Abeliuk estima que este razonamiento no es convincente desde que el artículo 1487, norma aplicable tanto a la condición resolutoria ordinaria

como a la tácita, permite al acreedor renunciar a la resolución. De tal suerte, que aun cuando ella operara de pleno derecho al acreedor le bastaría con manifestar su renuncia, para poder exigir el cumplimiento. En todo caso, como el acreedor tiene que ejercer su opción, solicitando el cumplimiento o la resolución, tendrá para ello que entablar la acción correspondiente, de cumplimiento o de resolución, que tendrá que ser resuelta en una sentencia judicial. Nos parece entonces que no admite dudas que la condición resolutoria tácita no opera de pleno derecho y en ese sentido toda la doctrina.

Consecuencia de que la resolución requiera de sentencia judicial es que el deudor podría enervar la acción de resolución, pagando hasta antes de la citación para sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Ello ha sido defendido por la mayoría de la doctrina nacional. Claro Solar, en ese sentido, afirma que mientras la resolución del contrato no ha sido declarada por la sentencia que ha de poner término al juicio, el contrato subsiste, y, por lo mismo, hallándose requerido judicialmente el demandado con la notificación de la demanda, puede evitar la resolución ejecutando la obligación, efectuando la prestación de lo debido durante toda la secuela del juicio. Estas opiniones se fundan en el artículo 310 del CPC que permiten oponer la excepción de pago e cualquier estado de la causa hasta el cítese para sentencia en primera instancia y la vista de la causa en segunda. No compartimos estas opiniones por las siguientes razones:

- i. De aceptarse que el deudor pueda cumplir con su obligación durante la secuela del juicio se vulnera artículo 1489 del CC que otorga la opción exclusivamente al contratante cumplidor y al aceptarse que el deudor pudiese pagar durante el juicio se le está entregando a él la elección, pues por el hecho de pagar está optando por el cumplimiento del contrato.
- ii. El argumento del artículo 310 del CPC no tiene el alcance que quienes están por la opinión contraria le dan. Cierto es que autoriza para oponer la excepción de pago cuando se funde en un antecedente escrito, en cualquier estado de la causa, pero una cosa es oponer la excepción de pago y otra muy distinta es que pueda pagar en cualquier estado de la causa.
- iii. Todo contrato es ley para los contratantes conforme al artículo 1545 del CC, por ello, las partes deben cumplir sus obligaciones en la forma y oportunidad convenidas.
- iv. Hay un solo flanco que nos preocupa de esta tesis y es el artículo 1879 del CC, porque dicha disposición, referida al pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio, permite al comprador enervar la acción de resolución pagando el precio a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la demanda. Puede sostenerse, entonces, que si en el pacto comisorio calificado, es decir, aquel en que las partes convinieron expresamente que si no se pagaba el precio el contrato se resolvía por ese sólo hecho, la ley todavía da al deudor la oportunidad de pagar dentro de las veinticuatro horas siguientes desde que se le notifique la demanda, con buena lógica debería entenderse que en el caso de la simple condición resolutoria tácita también pueden pagar fuera del plazo. El reparo no nos parece decisivo ya que la norma del artículo 1879 es una norma muy especial que sólo debe operar para

el caso en que fue establecida, no siendo lícito fundarse en ella para sacar conclusiones de carácter general que pongan en peligro todo el sistema establecido en el artículo 1489 del CC.

8.6 Derechos que confiere la condición resolutoria tácita.

El artículo 1489 del CC confiere al contratante diligente una opción para demandar o el cumplimiento del contrato o su resolución, en ambos casos con indemnización de perjuicios.

Si demanda el cumplimiento podrá hacerlo por la vía ordinaria o por la vía ejecutiva, según la naturaleza del título que se invoque. En todo caso, si lo que se demanda es el cumplimiento de un contrato bilateral para que pueda prosperar la acción es necesario que el ejecutante compruebe, al iniciar la demanda, haber cumplido las obligaciones por él contraídas. Del artículo 1552 del CC se desprende que si no acredita la mencionada circunstancia procede acoger la excepción, consistente en que el título no reúne los requisitos o condiciones exigidos por la ley para que tenga fuerza ejecutiva. Otro fallo expresa que resulta especialmente claro del tenor del artículo 1552 del CC que para poder exigir ejecutivamente el cumplimiento de una de las obligaciones recíprocas o correspondientes que se estipulan en un contrato bilateral, es menester que previamente se establezca que el ejecutante ha cumplido las que a él le incumbían, según ese mismo contrato. Y esa prueba, naturalmente, debe preceder a la demanda ejecutiva, porque, como es sabido, el carácter ejecutivo de un título debe encontrarse en el título mismo a la fecha en que se pide el mandamiento de embargo, y no en las probanzas posteriores que dentro de la ejecución se produzcan.

Para el caso que se demande la resolución, la vía tendrá que ser necesariamente la ordinaria, ya que del solo título no consta el incumplimiento del contrato.



Las acciones de cumplimiento y de resolución son incompatibles, pero pueden interponerse sucesivamente.

Por ello, no pueden demandarse conjuntamente, a menos que lo sea en forma subsidiaria, pero nada obsta a que ejercida una se pueda ejercer posteriormente la otra si no se obtuvo, conforme al artículo 17 del CPC. Si el contratante diligente demanda el cumplimiento y no lo obtiene, mantiene su opción para demandar la resolución. En ese sentido la doctrina.

La acción de indemnización de perjuicios es accesoria a la de resolución o cumplimiento. Con ello queremos señalar que no se puede demandar directamente indemnización de perjuicios sino que sólo como consecuencia de demandar el cumplimiento o la resolución del contrato; la claridad del artículo 1489 no admite dudas y así también la jurisprudencia reiterada de nuestros tribunales. Se

ha fallado que demandado el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios es inconsecuente el fallo que rechace, por una parte, dicho cumplimiento y, por otra, acoja la indemnización, porque según el tenor literal del artículo 1489 del CC la indemnización tiene como antecedente jurídico la resolución o el cumplimiento forzado del contrato, todavía incumplido.

No se puede pues, pedir la indemnización de perjuicios si no se ha demandado el cumplimiento o la resolución. Sin embargo, esta regla tiene una excepción importante en el caso que la obligación incumplida sea de hacer, pues respecto de ellas, si el deudor se constituye en mora el acreedor puede demandar cualquiera de estas tres cosas a elección suya: primero, que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido; segundo, que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor; y, tercero, que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato, conforme al artículo 1553 del CC.

Los perjuicios tendrán que probarse de acuerdo a las reglas generales. Lo anterior sin perjuicio de haberse convenido una cláusula penal que releve de esta obligación al deudor. La regulación de los perjuicios podrá hacerse en el mismo juicio, si se hubiere litigado sobre su especie y monto, o, en caso contrario, el tribunal reservará a las partes el derecho para discutir esta cuestión en la ejecución del fallo o en otro juicio diverso, conforme al artículo 173 del CPC.

8.7 Diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita.

La doctrina señala las siguientes diferencias:

- a) En la condición resolutoria tácita el hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral; en la condición resolutoria ordinaria cualquier hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de una obligación en un contrato bilateral.
- b) La condición resolutoria ordinaria opera de pleno derecho; la tácita requiere de declaración judicial.
- c) La condición resolutoria ordinaria requiere de una manifestación expresa de voluntad; la tácita es subentendida por la ley en todo contrato bilateral.
- d) La condición resolutoria tácita sólo opera en los contratos bilaterales según la opinión mayoritaria; la ordinaria puede establecerse en cualquier negocio jurídico.
- e) Cumplida la condición resolutoria ordinaria se produce necesariamente la resolución; en cambio, en la condición resolutoria tácita el acreedor condicional tiene un derecho optativo para demandar el cumplimiento o la resolución del contrato.
- f) Como la condición resolutoria tácita requiere de sentencia judicial que la declare, sus efectos son relativos, en virtud a lo dispuesto en el artículo 3 del CC; la situación es totalmente diferente en la condición resolutoria ordinaria, ya que al operar por el solo ministerio de la ley, aprovecha a cualquier interesado.
- g) En la condición resolutoria tácita el acreedor tiene derecho a indemnización de perjuicios; aquello no ocurre en la ordinaria.

Tema 9: Pacto Comisorio.

9.1 Concepto.

Es la **condición resolutoria tácita expresada**. En el mismo contrato de compraventa las partes dejan constancia que si el comprador no paga el precio la otra parte podrá pedir la resolución del contrato. El artículo 1877 del CC dispone: **“Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de compraventa. Entiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio, y produce los efectos que van a indicarse”**. Se desprende que el pacto comisorio viene a ser la estipulación de la condición resolutoria tácita, por el no pago del precio en el contrato de compraventa, en efecto, si nada hubieren dicho las partes y el comprador no pagare el precio, el efecto sería el mismo.

9.2 El pacto comisorio procede en cualquier contrato y por el incumplimiento de cualquiera obligación.

La ubicación de esta norma dentro del contrato de compraventa y a propósito del no pago del precio, ha hecho surgir dudas sobre si puede también convenirse en otros contratos y en la misma compraventa por obligaciones distintas a las del pago del precio. Hoy día está absolutamente claro que pese a estar el pacto comisorio tratado en el contrato de compraventa por el incumplimiento de la obligación de pagar el precio, su alcance es general, pudiendo establecerse en cualquier contrato, incluso en los contratos unilaterales, y por el incumplimiento de cualquier obligación, por los siguientes argumentos:

- i. El pacto comisorio no es otra cosa que la condición resolutoria tácita expresada, convenida.
- ii. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad las partes pueden celebrar cualquiera estipulación con tal que no se atente contra la ley, la moral o el orden público, y, por la misma razón, no se ve por qué no podrían acordar un pacto como éste.
- iii. Únicamente por una razón histórica el pacto comisorio se ha ubicado dentro de los pactos accesorios al contrato de compraventa, y tiene su origen en el derecho romano.

Un problema distinto, que analizaremos más adelante, es saber qué normas vamos a aplicar al pacto comisorio establecido en los demás contratos, si las de los artículo 1877 y siguientes del CC o las que las partes puedan haber convenido.

9.3 Pacto comisorio simple y pacto comisorio calificado.

La doctrina ha establecido esta clasificación del pacto comisorio, que se extrae del artículo 1879 del CC que dispone: “Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelva ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”. De esta norma se infiere que existen dos modalidades del pacto comisorio, que son las siguientes:

- a) El pacto comisorio simple, que no viene a ser más que la condición resolutoria tácita expresada.
- b) El pacto comisorio calificado o con cláusula ipso facto, que se define como el acuerdo de las partes en orden a dejar sin efecto el contrato, de inmediato, ipso facto, si el deudor incumple sus obligaciones. No es necesario emplear palabras sacramentales; estaremos frente a un pacto comisorio calificado, cualquiera que sean los términos empleados, si aparece clara la intención de los contratantes de que se produzca la resolución de inmediato, por el solo hecho del incumplimiento, sin necesidad de resolución judicial.

9.4 Efectos del pacto comisorio.

Para estudiar el punto, es preciso hacer la correspondiente distinción entre:

- i. Efectos del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio.
- ii. Efectos del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por obligaciones distintas a la de pagar el precio, o en los demás contratos por incumplimiento de cualquiera obligación.
- iii. Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio.
- iv. Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por una obligación distinta a la de pagar el precio o, en los demás casos, por incumplimiento de cualquiera obligación.

9.5 Efectos del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por no pago del precio.

El artículo 1878 del CC dispone que por el pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el artículo 1873 del CC, esto es, el derecho a exigir el pago, cumplimiento del contrato, o la resolución de la venta, con resarcimiento de perjuicios. Como se puede observar, estos efectos son idénticos a los de la condición resolutoria tácita, es decir, el comprador puede pedir el cumplimiento o la resolución del contrato con indemnización de

perjuicios. Y por la misma razón, para que opere se requiere de una resolución judicial, al igual que lo que ocurre en la condición resolutoria tácita.

9.6 Efectos del pacto comisorio simple en el contrato de compraventa por obligaciones distintas a la de pagar el precio, o en los demás contratos por incumplimiento de cualquiera obligación.

Siendo el pacto comisorio simple sólo la condición resolutoria tácita expresada, sus efectos son los mismos de aquella, es decir, se otorga al contratante cumplidor la opción para pedir el cumplimiento o la resolución más indemnización de perjuicios. Luego, se requiere también de sentencia judicial que declare la resolución.

9.7 Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio.

El artículo 1879 del CC dispone: **“Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido, se resuelva ipso facto el contrato de compraventa, el comprador podrá, sin embargo, hacerlo subsistir, pagando el precio, lo más tarde, en las veinticuatro horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda”**. Como puede observarse, pese a que las partes convinieron que la compraventa se resolviera por el sólo hecho del incumplimiento, no ocurre de esa forma, puesto que se otorga al comprador un plazo de veinticuatro horas que se cuenta desde la notificación de la demanda, para enervar la acción de resolución, pagando el precio adeudado. De manera que está claro que la resolución no opera de pleno derecho, sino que se requiere de una sentencia judicial que la declare. La razón de ello es que hay un interés social en la estabilidad de las transferencias de dominio que sigue a los títulos translativos de propiedad, como lo es la compraventa.

Luego si el comprador no paga el precio en la oportunidad convenida y existe este pacto comisorio calificado, de todas formas el vendedor deberá demandar judicialmente la resolución del contrato, con indemnización de perjuicios y, en su oportunidad, el tribunal deberá dictar la correspondiente sentencia dando lugar a la resolución y al pago de los perjuicios. Se demanda la resolución en juicio ordinario, porque no hay un procedimiento especial, conforme lo dispuesto en el artículo 3 del CPC. Notificada la demanda el comprador cuenta con un plazo de veinticuatro horas para enervar la acción de resolución pagando. Si el vendedor no quiere aceptar el pago, podrá pagar por consignación, lo que hará depositando la suma adeudada con los intereses vencidos, si los hay, y los demás cargos líquidos, en la cuenta corriente del tribunal que conoce del juicio de resolución en conformidad con el inciso final del artículo 1600 del CC. Respecto del plazo para pagar llama la atención que son veinticuatro horas, que no es lo mismo que un día, por cuanto por tratarse de un plazo de horas, se empieza a contar a partir del momento mismo en que se notifica la demanda. Además es un plazo fatal, por lo que cumplido caduca el derecho del comprador para pagar, sin necesidad de acusar rebeldía, conforme lo dispuesto en el artículo 49 del CC.

No hay duda que en presente caso la resolución requiere de sentencia judicial, conforme a los siguientes argumentos que así lo demuestran:

- i. Un argumento histórico basado en los proyectos del CC.
- ii. El artículo 1878 del CC, aplicable al pacto comisorio simple y al calificado, no priva al vendedor de la elección de acciones, pudiendo éste pedir el cumplimiento o la resolución. Si el contrato se resolviera ipso facto no se ve cómo podría solicitarse el cumplimiento, pues el contrato ya está terminado.
- iii. El artículo 1879 del CC señala que el vendedor podrá sin embargo hacerlo subsistir, frase que demuestra que el contrato no se extinguió por el solo incumplimiento.
- iv. Si el comprador puede enervar la acción pagando dentro de las veinticuatro horas desde que se le notifica la demanda es porque la resolución no opera por el solo hecho del incumplimiento.
- v. El argumento más categórico es que el artículo 1879 del CC exige demanda judicial, lo que implica juicio y sentencia.

Lo que se viene diciendo es de la mayor importancia, pues el hecho de que se exija sentencia judicial significa que puede así el comprador, e incluso los terceros interesados, pagar oportunamente para dejar firmes sus derechos, y porque, si bien el comprador no puede enervar la acción por medio del pago, sino cuando lo efectúa dentro del término señalado, puede oponer otras excepciones y enervar de esta manera la resolución, pues el juez debe pronunciarse sobre todas las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio, conforme a los artículos 170, 309 y 768 del CPC.

Aclarando que en el caso que se viene tratando la resolución opera por sentencia judicial, es necesario dilucidar en qué momento se produce la resolución, para lo cual hay dos opiniones:

- i. Según algunos la resolución se produce al momento en que se acoge la demanda.
- ii. Para otros la resolución se produce al momento en que se extingue el plazo de veinticuatro horas para enervar la acción pagando.

No es esta una discusión ociosa porque si se sigue la primera tesis, el vendedor podría recibir el pago después de las veinticuatro horas, pues aún no está resuelto el contrato; en cambio, si se sigue la segunda postura, ello no podría ocurrir pues aunque la resolución se produce con la sentencia, sus efectos operan retroactivamente al vencimiento de las veinticuatro horas.

Con respecto a las **condiciones que debe reunir el pago para enervar la acción resolutoria**, éste debe reunir los siguientes requisitos:

- i. Debe pagarse dentro de las veinticuatro horas desde que se notifica la demanda.

- ii. El pago debe ser íntegro, esto es, pagarse todo lo que al momento de la notificación de la demanda sea actualmente exigible.
- iii. Debe cumplirlos requisitos generales del pago.

9.8 Efectos del pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por una obligación distinta a la de pagar el precio o, en los demás casos, por incumplimiento de cualquiera obligación.

En relación a los efectos del pacto comisorio calificado en estos casos, hubo en un tiempo una extensa discusión doctrinaria que estimamos hoy prácticamente agotada. El problema consiste en *resolver si la resolución opera de pleno derecho o si requiere también, igual que en la compraventa por no pago del precio, de una sentencia judicial que la declare*. Nos parece absolutamente claro que el pacto comisorio calificado, en este caso, opera de pleno derecho porque eso es lo que pretendieron las partes al estipularlo. No estamos frente al pacto comisorio del artículo 1879 del CC por lo que no hay razón para aplicar sus reglas, sino ante un pacto creado por las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1545 del CC. La norma del artículo 1879 del CC es excepcional, porque rige para la compraventa y sólo para el no pago del precio, por ello su aplicación debe ser restringida. Además, para interpretar las cláusulas de un contrato en que no hayan reglas especiales, debe recurrirse a las disposiciones generales de los artículos 1560 y siguientes del CC, que atienden principalmente a la intención de los contratantes, que al estipular en esta forma el pacto comisorio en un contrato pretenden, sin lugar a dudas, que se resuelva de pleno derecho en caso de incumplimiento. Además, debe recordarse que el pacto comisorio constituye una condición resolutoria, por lo que cabe aplicarse lo dispuesto en el artículo 1484 del CC según el cual las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma convenida; y exigir sentencia judicial no es lo que las partes convinieron.

Existe controversia en relación con este pacto en el contrato de arrendamiento. Al operar el pacto comisorio calificado en el contrato de arrendamiento, si en éste se estipuló que el contrato terminaba ipso facto por el no pago de las rentas en la oportunidad fijada, y se produce el incumplimiento, el arrendador deberá demandar solicitando restitución del inmueble y no la terminación, porque el contrato se extinguió al cumplirse la condición, y no se puede pedir que se extinga lo que ya está extinguido. Sin embargo, el artículo 1977 del CC dispone: “La mora de un periodo entero de pago de la renta, dará derecho al arrendador, después de dos reconvenciones entre las cuales medien a lo menos cuatro días, para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad competente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable que no bajará de treinta días”. Si hay pacto comisorio esta regla no rige, porque no se trata de hacer cesar inmediatamente el arriendo porque, lo repetimos, el contrato de arriendo se extinguió al cumplirse la condición fijada en el pacto. Así lo ha dicho la jurisprudencia al sostener que el pacto comisorio calificado que las partes introdujeron en el contrato de arrendamiento comparte la naturaleza jurídica de la condición resolutoria ordinaria y, por consiguiente, su cumplimiento, en la

especie, la falta de pago de las rentas, produce ipso iure la extinción del arrendamiento, sin que sea menester una declaración judicial, razón por la cual el arrendatario carece de la facultad para hacer subsistir el contrato consignando las rentas que en su oportunidad dejó de pagar.

9.9 Prescripción del pacto comisorio.



El artículo 1880 del CC dispone: **“El pacto comisorio calificado prescribe al plazo prefijado por las partes, si no pasare de cuatro años, contados desde la fecha del contrato. Transcurridos estos cuatro años, prescribe necesariamente, sea que se haya estipulado un plazo más largo o ninguno”**. Respecto de esta norma es importante precisar lo siguiente:

- i. El plazo de prescripción que ella establece rige únicamente para el pacto comisorio, simple o calificado, que reglamenta el CC, es decir, para el contrato de compraventa por el no pago del precio. En el caso del pacto comisorio establecido en otros contratos o en la compraventa por una obligación diferente a la de pagar el precio, no se aplica la norma del artículo 1880 del CC, sino que la prescripción en esos casos se regula por los artículos 2514 y 2515 del CC, o sea, prescriben en cinco años contados desde que la obligación se hizo exigible.
- ii. El artículo 1880 del CC no dice que el pacto comisorio prescriba en cuatro años, sino que en el plazo que las partes acordaren si no pasare de cuatro años, luego, puede prescribir en un plazo menor de cuatro años.
- iii. Por último, debe destacarse que el plazo de prescripción del artículo 1880 del CC no empieza a correr desde que la obligación se hace exigible, como debería ocurrir si se aplicaran las reglas generales en conformidad al artículo 2514 del CC, sino desde la fecha del contrato. Lo anterior significa que al momento de establecerse el pacto, no podrá ser por obligaciones que demoren más de cuatro años en cumplirse, pues de ocurrir así, cuando se demandare la resolución, el pacto ya se encontraría prescrito.

9.10 Prescrita la acción del pacto comisorio, ¿podría demandarse la resolución fundada en el artículo 1489 del CC?

Se trata de determinar que ocurre cuando en un contrato de compraventa existe un pacto comisorio por no pago del precio y el vendedor deja transcurrir más de cuatro años para demandar. Se pregunta si, en este caso, puede demandar la resolución del contrato fundándose, no en el pacto comisorio, sino en la condición resolutoria tácita del artículo 1489 del CC. Se estima que si se estipuló el pacto comisorio, es porque las partes quisieron someterse a estas reglas y no a las de la condición resolutoria del artículo 1489 del CC, por lo que su renuncia a la acción que concede esta condición se presume tácitamente. En este sentido la mayoría de la doctrina, sin embargo, la jurisprudencia admite la tesis contraria.

Tema 10: La Acción Resolutoria.

10.1 Concepto.

Se la define como la **que emana de la condición resolutoria en los casos que ella requiere sentencia judicial, y en cuya virtud el contratante diligente solicita que se deje sin efecto el contrato por no haber cumplido la contraparte algunas de las obligaciones emanadas de él.** Dice la definición que emana de la condición resolutoria en los casos en que ella requiere sentencia judicial, lo que ocurre en las siguientes situaciones:



- i. En la condición resolutoria tácita.
- ii. En el pacto comisorio simple.
- iii. En el pacto comisorio calificado en el contrato de compraventa por no pago del precio.

En la condición resolutoria ordinaria o en los otros pactos comisórios no hay acción resolutoria, porque la resolución opera de pleno derecho, no se demanda judicialmente y por ello no se requiere de acción. Por lo tanto, como observan algunos autores, es erróneo afirmar que la acción resolutoria proviene de la condición resolutoria, pues, como se viene demostrando, hay casos de condición resolutoria que no dan acción.

10.2 Características de la acción resolutoria.

La doctrina señala las siguientes:

1. Es una acción personal:

Es personal porque la acción deriva del contrato, y éstos generan derechos personales. Por ser personal sólo se puede entablar en contra de quien celebró el contrato, no en contra de terceros. Por ello, por ejemplo, si el comprador enajena la cosa a un tercero, no podrá intentarse la acción en contra de este tercero, porque no fue parte del contrato. Ello sin perjuicio de que exista otra acción en contra de ese tercero, reivindicatoria o restitutoria, como lo veremos. Por esta razón, la Corte Suprema ha fallado que no se puede dirigir la acción resolutoria contra una persona que actuó como mandatario. En el caso en que los deudores incumplidores se hubieren obligado solidariamente la acción puede intentarse en contra de cualquiera de ellos.

2. **Es una acción patrimonial.** Ello es así desde que su objetivo es dejar sin efecto un contrato patrimonial. No cabe la resolución en el derecho de familia. Del hecho de ser patrimonial derivan importantes consecuencias:
 - **Es renunciable** conforme al artículo 1487 del CC y es lógico que así sea, pues sólo mira al interés personal del renunciante y no se encuentra prohibida su renuncia conforme al artículo 12 del CC. Se puede renunciar en el mismo contrato o posteriormente antes del cumplimiento. La renuncia puede ser expresa o tácita. El solo hecho de demandar el cumplimiento no supone, según ya lo hemos visto, la renuncia a la acción resolutoria.
 - **Es transferible y transmisible.** En cuanto a su transferencia, algunos autores estiman que si se cede un crédito, esta cesión no importa la transferencia de la acción resolutoria. Esta opinión se funda en que la resolución sería una acción personal, que no queda comprendida en la cesión conforme al artículo 1906 del CC. La doctrina se encuentra dividida. Por ello y para evitar problemas, cuando se cede un crédito parece importante ceder también la acción resolutoria, pues de no hacerse así podría sostenerse que el cesionario no puede demandar la resolución del contrato, pues la cesión traspasa únicamente el crédito, no la calidad de parte contratante. Una situación parecida a la anterior se presenta en el caso de que en una compraventa el pago del precio lo haga un tercero con el consentimiento del deudor y que en virtud del quinto número del artículo 1610 del CC se subrogue en los derechos del acreedor pagado. De admitir que la subrogación comprende las referidas acciones de nulidad, simulación o resolución del contrato, se desnaturalizaría la institución, pues se autorizaría al solvens subrogado, no ya para lograr la satisfacción de su crédito, sino para destituirlo y para obtener en cambio y sin causa alguna otros derechos.
 - **Es prescriptible;** y su plazo de prescripción será normalmente de cinco años que se cuentan desde que la obligación se hace exigible conforme a los artículos 2514 y 2515 del CC. Sin embargo, la acción resolutoria que emana del pacto comisorio establecido en un contrato de compraventa por no pago del precio, se rige por la regla especial del artículo 1880 del CC, esto es, que prescribe en el plazo que fijaron las partes si no excede de cuatro años, plazo que se cuenta desde la celebración del contrato. El plazo de prescripción en el caso del artículo 1880 del CC tiene además la particularidad de que, en conformidad al artículo 2524 del CC, no se suspende.
3. **Es una acción mueble o inmueble,** según el objeto de que se trate. Es aplicación lisa y llana del artículo 580 del CC.
4. **Es una acción indivisible.**

Esta indivisibilidad es subjetiva y objetiva. Subjetiva porque si son varios los acreedores, deben ejercer la acción conjuntamente, y si hay pluralidad de deudores, debe demandarse a todos ellos, conforme al sexto número del artículo 1526 del CC. Objetiva porque no se puede demandar en parte el cumplimiento y en parte la resolución, conforme al artículo 1489 del CC

que da la alternativa para demandar el cumplimiento o la resolución, pero no en parte el cumplimiento y en parte la resolución.

10.3 Resolución y Nulidad de un Contrato.

Son muy diferentes la acción de nulidad y la acción de resolución. **Hay nulidad cuando existe un vicio originario en el contrato, como podría ser objeto ilícito, causa ilícita, vicios del consentimiento, etc.** En cambio, la resolución deriva del hecho de que en un contrato bilateral una parte no cumple lo pactado. En cuanto a los efectos que produce la resolución y la nulidad, son también diversos. La nulidad y rescisión borran totalmente el acto o contrato, por lo que sus efectos son más radicales y, por lo mismo, la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros, sin distinción de ninguna especie de acuerdo al artículo 1689 del CC. En cambio, la acción resolutoria sólo da acción contra terceros de mala fe, como lo veremos luego al estudiar los artículos 1490 y 1491 del CC. Hay diferencias importantes también en relación con las prestaciones mutuas, cuando se acoge la nulidad o la resolución. Una cosa es importante: sólo cabe la resolución respecto de un contrato válido, pues la acción de resolución deriva del incumplimiento del contrato, y si en virtud del efecto propio de la nulidad se determina que no hay contrato, mal podrá haber acción resolutoria. Por ello, se ha resuelto que no puede demandarse la resolución de un contrato de promesa nulo.

10.4 Resolución y resciliación de un contrato.

Corresponden a dos instituciones absolutamente diferentes. La resolución, ya lo sabemos, procede cuando en un contrato bilateral una de las partes no cumple sus obligaciones. La resciliación, en cambio, es un modo de extinguir las obligaciones que se produce cuando las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, y en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, acuerdan dejar sin efecto el contrato de donde emana la obligación, conforme al artículo 1567 del CC. Por su propia naturaleza, la resciliación no puede afectar en modo alguno a los terceros, pues el acuerdo que ella supone les es inoponible.

10.5 Efectos de la Resolución.

Para estudiar esta materia debemos distinguir entre: primero, los efectos entre las partes; y, segundo, los efectos respecto de terceros.

10.5.1 Efectos de la resolución entre las partes.

Los efectos entre las partes son los propios de toda condición resolutoria, es decir, volver a las partes al estado anterior a la celebración del contrato como si nunca hubieren contratado. En virtud del efecto retroactivo, cumplida la condición el deudor condicional debe restituir lo que había adquirido bajo esa condición conforme al artículo 1487 del CC que dispone: *“Cumplida la*

condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiere recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta a favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación, si el deudor lo exigiere”.

Recordemos que el deudor condicional, por regla general, no restituye los frutos percibidos en el tiempo intermedio, conforme al artículo 1488 del CC; que entrega la cosa en el estado en que se encuentre, con sus aumentos y mejoras, y sufriendo el acreedor los deterioros fortuitos que haya experimentado la especie, no así los culpables, de los que responde el deudor, conforme al artículo 1486 del CC; los actos de administración realizados por el deudor, arriendos por ejemplo, quedan firmes, sin perjuicio de que se produzca la resolución ésta opere como modo de extinguir esos contratos conforme al tercer número del artículo 1950 y al artículo 1958 del CC.

Conviene precisar que si el deudor había cumplido en parte sus obligaciones, debe restituírsele lo que él hubiere pagado, pues en caso contrario, habría enriquecimiento sin causa, conforme al artículo 1875 del CC.

10.5.2 Efectos de la resolución respecto de terceros.

Va a afectar a terceros cuando el deudor condicional resolutorio, pendiente la condición resolutoria haya enajenado o gravado la cosa poseída bajo esa condición. En virtud del efecto retroactivo de la condición, cumplida ésta, cabe entender que el deudor condicional no ha sido nunca dueño, por lo que tales enajenaciones y gravámenes los realizó sobre cosa ajena, siendo, por lo mismo, inoponibles a su verdadero dueño. Sin embargo, si esta regla se aplicara en forma absoluta se causaría perjuicios a los terceros que pueden haber contratado con el deudor condicional de buena fe, ignorando la existencia de la condición. Por ello, para conciliar los intereses del acreedor con los de los terceros, el CC ha dado reglas especiales en los artículos 1490 y 1491, en cuya virtud, y hablando en términos muy generales, la resolución no afecta a los terceros de buena fe. El artículo 1490 del CC rige para los bienes muebles y el artículo 1491 del CC rige para los bienes inmuebles.

• Estudio del artículo 1490 del CC.

La disposición señala: “Si el que debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria la enajena, no habrá derecho a reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe”. En primer término debe entenderse que cuando la norma habla de cosa mueble ellas comprenden a las cosas corporales y a las incorporeales o derechos. Cuando dice que el que debe una cosa mueble debemos entender que lo que se quiere expresar es si se posee una cosa mueble, pues pendiente la condición no se puede decir que deba la cosa, pues ello sólo vendrá a ser cierto si la condición se cumple.

La disposición se pone en tres supuestos:

- i. Que se tenga una cosa debida a plazo.
- ii. Que se tenga una cosa debida bajo condición suspensiva.
- iii. Que se tenga una cosa debida bajo condición resolutoria.

La primera situación nada tiene que ver con la resolución pues quien debe una cosa a plazo no es propietario sino usufructuario de la misma conforme al artículo 1087 del CC y, por consiguiente, sólo le está permitido ceder y gravar su derecho de usufructo conforme al artículo 793 del CC. Si va más allá, enajena o grava la cosa, no se aplica el artículo 1490 del CC sino que las disposiciones generales sobre enajenación o gravamen de cosa ajena, en virtud de las cuales tales enajenaciones son inoponibles al verdadero dueño, sea que el tercero esté de buena o mala fe.

El segundo supuesto también es imposible porque nadie puede poseer una cosa sujeta a condición suspensiva. Si tiene la cosa y su posesión es condicional será deudor condicional resolutorio, no suspensivo.

De manera que en definitiva la norma sólo va a operar cuando se posea **una cosa sujeta a condición resolutoria**. Es el único caso en que el poseedor puede enajenar y gravar la cosa, enajenaciones y gravámenes que deberán extinguirse de cumplirse la condición.

Los requisitos para que la enajenación o gravamen de una cosa mueble debida bajo condición resolutoria afecte a terceros son los siguientes;

- i. Que el deudor condicional la haya enajenado o gravado.
- ii. Que el tercero esté de mala fe, es decir, que al momento de contratar con el deudor condicional supiera que el derecho de éste estaba sujeto a extinguirse de cumplirse la condición.

De acuerdo a las reglas generales y al artículo 707 del CC, la buena fe se presume, por lo que será el acreedor condicional quien deberá probar la mala fe del tercero. Agreguemos que los artículos 1490 y 1491 del CC rigen aunque el tercero adquiera la cosa en pública subasta decretada por la justicia.

- **Estudio del artículo 1491 del CC.**

La norma establece: “**Si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, o lo grava con hipoteca, censo o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública**”. La expresión inmueble comprende tanto las cosas corporales como las incorporales. No se comprende a los inmuebles por adherencia porque ellos son considerados muebles por anticipación para los efectos de su enajenación conforme al artículo 571 del CC.

En cuanto a los requisitos para que los terceros se vean afectados por la condición, el artículo 1491 del CC establece que sólo un requisito es necesario: **que la condición conste en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública.**

En cuanto a cuando debe entenderse que la condición consta en el título respectivo, es indudable que en el caso de la condición resolutoria ordinaria o del pacto comisorio ellas constan en el título. La duda puede presentarse respecto de la condición resolutoria tácita, ya que ésta justamente por no estar expresada no puede constar en el título. Se ha entendido casi invariablemente que cuando se exige que la condición conste en el título no quiere significar que debe estar expresada, de modo que debe entenderse que consta también la condición si el título aparece que existe una obligación incumplida, pues con ello quien va a contratar sabe que si tal obligación no se cumple operará la condición resolutoria tácita, pues, se dice que una cosa consta cuando es cierta y si hay una obligación incumplida en un contrato bilateral se sabe, es un hecho cierto, que podrá resolverse si no se cumple esa condición. Por lo demás, el artículo 1491 del CC no distingue entre condición resolutoria expresa o tácita. Hay doctrina en contrario que estima que sólo constaría la condición resolutoria expresa. Lo que venimos diciendo es del mayor interés pues al examinarse títulos de inmuebles deberá estudiarse si existen obligaciones pendientes, pues de haberlas, el adquirente de la cosa quedará expuesto a que su derecho se resuelva, si el deudor no cumple esa obligación, por aplicación del artículo 1489 del CC.

En cuanto a lo que debe entenderse por que la condición conste en el título respectivo, se dice que título respectivo es aquel en cuya virtud adquirió la cosa la persona que ahora pretende enajenar o gravar.

En cuanto a la razón de por qué la ley dice que el título debe constar en el respectivo título inscrito u otorgado por escritura pública, nótese en primer lugar, que la ley no dice que para que opere la resolución la condición tenga que encontrarse inscrita; lo que se inscribe es el título, no la condición. Si la ley habla de título inscrito u otorgado por escritura pública es porque hay ciertos títulos que no requieren de inscripción, como ocurre con las servidumbres, cuya tradición se hace mediante escritura pública, conforme al artículo 698 del CC. En el caso de actos que deben inscribirse para que opere el artículo 1491 del CC tiene que encontrarse el título inscrito, no basta la simple escritura pública.

En cuanto a si la condición que consta en el título inscrito u otorgado por escritura pública impide al tercero adquirente ser poseedor de buena fe, el problema ha sido ampliamente discutido y se ha concluido que ese hecho no lo transforma en poseedor de mala fe, y tendrá esa calidad si tiene conciencia de haber adquirido la cosa por medio legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio como lo señala el primer inciso del artículo 706 del CC. La jurisprudencia ha dicho que como la buena fe se presume será el reivindicante quien deberá probar que adquirió la cosa de mala fe. Lo que se viene diciendo es importante porque si es poseedor de buena fe y cumple

los demás requisitos de posesión regular, justo título y buena fe, puede llegar a adquirir la cosa por prescripción ordinaria.

En cuanto a los gravámenes que caducan el artículo 1491 del CC plantea aún otro problema, pues al hacer referencia únicamente a tres gravámenes, hipoteca, censo y servidumbre, se plantea la duda de lo que ocurre si el gravamen es otro, por ejemplo, fideicomiso, usufructo, uso, habitación, etc. Algunos autores sostienen que la norma es taxativa y otros que es ejemplificador. Los que defienden la primera tesis estiman que la norma, por ser excepcional, debe interpretarse en forma restringida. Además sostienen que los artículos 763, 806, 812, 885 y 2406 del CC establecen que los derechos de usufructo, uso, habitación, servidumbres y prendas se extinguen por la resolución del derecho de su autor, sin distinguir si los terceros adquirentes de estos derechos estaban de buena o mala fe.

No se aplica el artículo 1491 del CC a los arrendamientos celebrados por el deudor condicional. Pendiente la condición el deudor condicional puede haber arrendado el inmueble. Pues bien, cumplida la condición los arrendamientos celebrados no quedan regidos por el artículo 1491 del CC por varias razones. Primero, porque no constituyen actos de enajenación o gravamen, que es a lo que se refiere el artículo 1491 del CC. Segundo, porque ya hemos dicho que el deudor condicional tiene facultades para dar en arrendamiento las cosas debidas bajo condición, pues se aplica, por extensión, la regla que para el propietario fiduciario establece el artículo 758 del CC. Finalmente, porque el CC ha reglamentado expresamente esta situación al establecer que el arrendamiento termina en este caso, en conformidad al tercer número del artículo 1950 del CC, y los efectos de esa terminación quedan regulados por el artículo 1961 del CC, que obliga al arrendador, deudor condicional, a pagar al arrendatario una indemnización por la extinción del arriendo.

• **Acción reivindicatoria de los acreedores condicionales.**

Cumplíéndose los requisitos de los artículos 1490 y 1491 del CC los acreedores condicionales tienen acción reivindicatoria contra los terceros poseedores. Se trata de una verdadera acción reivindicatoria que ejercita el acreedor, porque habiéndose resuelto el contrato, el dominio vuelve automáticamente a su patrimonio y puede, en consecuencia, reclamar la posesión de la cosa. La única salvedad es que no procede la acción reivindicatoria contra los terceros de buena fe, en el caso de los muebles, o respecto de los cuales la condición no constaba en el título inscrito u otorgado por escritura pública, en el caso de los inmuebles. Como acción reivindicatoria, por ser real se va a dirigir en contra del actual poseedor de la cosa. Las prestaciones mutuas que se generen en este caso se van a regir por las reglas de los artículos 904 y siguientes del CC. Finalmente, agreguemos que el acreedor condicional al momento de demandar puede intentar en la misma demanda la acción resolutoria en contra del tercer poseedor por emanar ambas acciones de un mismo hecho, conforme al artículo 18 del CPC.

- **Ámbito de aplicación de los artículos 1490 y 1491 del CC.**

No tienen estas normas un ámbito de aplicación tan extenso como pudiera suponerse. Se señala que, fuera de los contratos innominados en que pudieran aplicarse, únicamente rigen los siguientes casos:

- i. A la resolución del contrato de compraventa cuando el deudor no ha cumplido con la obligación de pagar el precio o cualesquiera otra que se le impongan por la ley o por la voluntad de las partes.
- ii. A la resolución del contrato de permuta, conforme al artículo 1900 del CC.
- iii. Al pacto de retroventa, conforme al artículo 1882 del CC.

Se agrega que debe tenerse presente que los artículos 1490 y 1491 del CC no se aplican al que sujeta su dominio al evento de una condición, pues el acreedor en tal caso no ha adquirido ningún derecho real en la cosa y sólo tiene acción personal contra el deudor.

- **Efectos de la cláusula de encontrarse pagado el precio.**

El artículo 1876 del CC dispone: *“La resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores, sino en conformidad a los artículos 1490 y 1491 del CC. Si en la escritura de venta se expresa haberse pagado el precio no se admitirá prueba alguna en contrario sino la de la nulidad o falsificación de la escritura, y sólo en virtud de esta prueba habrá acción contra terceros poseedores”.*



Se discute si la norma se aplica sólo en relación con los terceros adquirentes o si también afectaría al vendedor. Una sentencia estableció que se aplica, no sólo cuando la cuestión controvertida es entre terceros, sino que también cuando lo es entre las partes, opinión que nos merece reparos. Creemos que el artículo está dado exclusivamente en beneficio de los terceros adquirentes, porque si en la escritura se dice que el precio se pagó, sin que ello sea cierto, existe simulación, y en este caso no hay raspón alguna para impedir al vendedor que pruebe la simulación, pues nuestro CC, en principio, acepta la posibilidad de simulación y lo único que hace es proteger a los terceros como lo prueban los artículos 1707 y 1876 del CC. Asimismo, porque conforme al artículo 1700 del CC lo declarado por las partes en una escritura pública sólo constituye una presunción de verdad, que admite prueba en contrario.

Los artículos 1490 y 1491 del CC se aplican tanto a las enajenaciones voluntarias como a las forzadas. Una sentencia estableció que si el tercero adquiere el bien en pública subasta de todas maneras se aplica el artículo 1491 del CC si la condición constaba en el título, porque la disposición no distingue entre enajenaciones voluntarias y forzadas, sentencia que nos parece absolutamente ajustada a derecho.

Unidad 5: Efectos de las Obligaciones.

Tema 1: Introducción

Tradicionalmente se ha enseñado que los efectos de las obligaciones son los derechos que la ley confiere al acreedor, para exigir del deudor el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación, cuando éste no la cumpla en todo o en parte o está en mora de cumplirla. Claro Solar expresa que el efecto de las obligaciones es colocar al deudor en la necesidad jurídica de donar, hacer o no hacer alguna cosa dando al acreedor los medios de obtener la ejecución de esta prestación. Desde hace algunos años se viene diciendo que lo anterior es inexacto porque constituye sólo una parte de los efectos de las obligaciones, los que se producen cuando el deudor incumple, pero no la situación normal que se da cuando el deudor cumple lo convenido. Se omite el efecto primero y principal de la obligación, que justamente se denomina normal, a la vez razón fundamental tenida en cuenta particularmente por el acreedor al vincularse jurídicamente. Se trata del efecto de cumplimiento, realizado espontáneamente y en conformidad al contenido efectivo de la obligación, es la razón fundamental por la cual ha contratado el acreedor y aún el propio deudor. Según lo anterior, el primer efecto de una obligación será el pago voluntario, pero si no hay pago voluntario la ley confiere ciertos derechos al acreedor para obtener el cumplimiento forzado de la obligación.

1.1 Efectos del contrato y efectos de la obligación.

El CC trata esta materia en el Título XII del Libro Cuarto, artículos 1545 y siguientes. Trata promiscuamente los efectos de los contratos y los efectos de las obligaciones, que son cosas diferentes. Los motivos de esta confusión se deben a que siendo las obligaciones el efecto del contrato, y habiéndose propuesto tratar de las obligaciones convencionales, contractuales, y no, en general, de las obligaciones, estimaron que en el efecto de las obligaciones se comprendía también el efecto de los contratos.

En todo caso, **tengamos claro que los efectos del contrato son los derechos y obligaciones que genera.** El contrato es una **fuentes de obligaciones.** En cambio, el efecto de las obligaciones, mirado desde el punto de vista del deudor, **viene a ser la necesidad jurídica en que se encuentra de tener que dar, hacer o no hacer algo a favor del acreedor.** Y mirado desde el punto de vista del acreedor, son los medios que la ley le otorga para obtener del deudor el pago íntegro y oportuno de la prestación debida.

1.2 Efecto de las obligaciones para el caso de incumplimiento del deudor.

Si el deudor no cumple con oportunidad, en forma espontánea y normal con la obligación contraída, la ley otorga al acreedor diversos medios para obtener, en primer lugar, el cumplimiento forzado, **derecho principal**; y, cuando ello no es posible, el pago de una suma de dinero que le compense de lo que le habría significado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación, **derecho secundario**, una indemnización de perjuicios. Pero además la ley, en su afán de proteger al acreedor, le otorga ciertos derechos destinados a la conservación del patrimonio del deudor, en razón de que será en ese patrimonio donde se hará exigible el cumplimiento en virtud del derecho de prenda general establecido en el artículo 2465 del CC.

De acuerdo con lo señalado, cuando el deudor incumple, la ley otorga al acreedor tres derechos:

- a) Derecho principal, a la ejecución forzada de la obligación.
- b) Derecho subsidiario, para obtener el pago de una indemnización de perjuicios, que es una forma de cumplir por equivalencia.
- c) Finalmente, derechos auxiliares, destinados a mantener la integridad patrimonial del deudor.

Tema 2: Cumplimiento Forzado de la Obligación.

El artículo 2465 del CC dispone: “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo 1618”. **Es lo que la ley denomina derecho de prenda general del acreedor.**

2.1 Cumplimiento forzado en los distintos tipos de obligación.

Lo que se va a exigir forzosamente no es de una misma naturaleza, pues va a depender del tipo de obligación, debiendo distinguirse entre:

- a) **Si la obligación es de pagar** una suma de dinero; que será lo más corriente, el acreedor se dirigirá directamente sobre el dinero para hacerse pago con él, o bien sobre los bienes del deudor, para realizarlos y pagarse con el producto de la venta.
- b) **Si la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto** y ésta se encuentra en del deudor, la ejecución forzada se dirigirá a obtener la entrega de esa especie, o al pago de la indemnización si ello no es posible.
- c) **Si es una obligación de hacer**, la ejecución tendrá por objeto que se realice el hecho debido, personalmente por el obligado, o por un tercero, si ello fuere posible y, en caso contrario, que

la obligación se convierta en obligación de dinero, para cobrar la correspondiente indemnización.

- d) **Si la obligación es de no hacer**, la ejecución tendrá por objeto deshacer lo hecho, si ello es posible y necesario para los fines que se tuvo en vista al contratar o, en caso contrario, que se transforme en obligación de dinero para cobrar la indemnización.

2.2 Cumplimiento forzado de la obligación de dar.

Obligación de dar es aquella en que el deudor se obligó a transferir el dominio o constituir un derecho real sobre la cosa. El artículo 1548 del CC señala que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa, por lo que ambas se rigen por las mismas reglas.

Para que proceda la ejecución forzada se requiere:

- a) **Que la obligación conste en un título ejecutivo**, que es aquel instrumento que por sí solo es capaz de dar constancia de la obligación.
- b) **Que la obligación sea actualmente exigible**, o sea, que no esté sujeta a plazo o condición o que emane de un contrato bilateral en que el acreedor no ha cumplido con su propia obligación.
- c) **Que la obligación sea líquida o que pueda liquidarse** mediante simples operaciones aritméticas, sólo con los datos que el mismo título ejecutivo suministre.
- d) **Que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita**, o sea, que no hayan pasado más de tres años desde que la obligación se hizo exigible.

Si no se reúnen estos requisitos se deberá demandar en juicio declarativo y obtener una sentencia que una vez firme servirá de título ejecutivo conforme al primer número del artículo 434 del CPC.

2.3 Cumplimiento forzado de la obligación de hacer.

Presenta más dificultades, pues es difícil obligar a un deudor a que realice satisfactoriamente el hecho debido. Sólo será posible tratándose de hechos que puedan ser ejecutados por otra persona. Por ello es que el artículo 1553 del CC autoriza al acreedor para demandar directamente el pago de la indemnización de perjuicios.

De conformidad al artículo 1553 del CC, si la obligación de hacer y el deudor se constituyen en mora, el acreedor podrá pedir, junto con la indemnización de perjuicios por la mora, cualquiera de estas tres cosas a elección suya:

- a) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido.
- b) Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor.
- c) Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato.

El apremio se hace en conformidad con el artículo 543 del CPC que dispone: **“Podrá el tribunal imponer arresto hasta por quince días o multa proporcional y repetir estas medidas para obtenerle cumplimiento de la obligación”**.

El procedimiento ejecutivo está establecido en el CPC. Para que proceda es necesario que exista un título ejecutivo, que la obligación esté determinada, que sea actualmente exigible y que la acción ejecutiva no se encuentre prescrita. Será distinto el procedimiento ejecutivo según:

- a) Si el hecho debido consiste en la suscripción de un instrumento o en la constitución de una obligación por parte del deudor, caso ñeque podrá proceder el juez que conozca del litigio si requerido el deudor no lo hace dentro del plazo que le señale el tribunal.
- b) Si la obligación consiste en la ejecución de una obra material, pues en este caso el mandamiento contendrá la orden de requerir al deudor para que cumpla la obligación; y se le dará un plazo prudente para que dé principio al trabajo.

Si el acreedor demanda indemnización de perjuicios tendrá que hacerlo en juicio declarativo porque el valor de lo demandado no puede constar en el título ejecutivo. Se requiere una sentencia firme que resuelva previamente la existencia y el monto de los perjuicios.

2.4 Cumplimiento forzado de la obligación de no hacer.

Se resuelve indemnizar perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho conforme al artículo 1555 del CC. Si se puede destruir la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor. Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el deudor que se allane a prestarlo. El acreedor quedará de todos modos indemne.

El procedimiento ejecutivo está establecido en el CPC, que en su artículo 544 dispone: **“Las disposiciones que preceden se aplicarán también a la obligación de no hacer cuando se convierta en la de destruir la obra hecha, con tal que el título en que se apoye consigne de un modo expreso todas las circunstancias requeridas por el segundo inciso del artículo 1555 del CC,**

y no pueda tener aplicación el tercer inciso de dicho artículo. En el caso en que tenga aplicación este último inciso, se procederá en forma de incidente”.

2.5 Cuadro resumen de casos en que es posible la ejecución forzada de la obligación.

La ejecución forzada procede en los siguientes casos:

- a) **En las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto** que se encuentre en poder del deudor.
- b) **En las obligaciones de dar un género**, porque como el género no perece, siempre el deudor puede encontrar una cosa con que pagar.
- c) **En las obligaciones de hacer que puedan ser ejecutadas por terceros a expensas** del deudor.
- d) **En las obligaciones de no hacer**, si puede destruirse lo hecho y siempre que dicha destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo a la vista al contratar.

En las obligaciones de dar el acreedor debe exigir el cumplimiento por naturaleza de la obligación; sólo en forma subsidiaria puede demandar la indemnización de perjuicios. En las obligaciones de hacer y de no hacer, puede demandar directamente el pago de la indemnización de perjuicios, todo ello conforme a los artículos 1553 y 1555 del CC.

Tema 3: Cumplimiento por Equivalencia: Indemnización de Perjuicios.

3.1 Cumplimiento por equivalencia. Indemnización de perjuicios.

Consiste en el derecho que la ley otorga al acreedor para obtener del deudor el pago de una cantidad de dinero equivalente al beneficio pecuniario que le habría reportado el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación. Sus características fundamentales son que tiende a reparar el perjuicio sufrido por el acreedor por el incumplimiento imputable del deudor, y que no implica un cumplimiento igual al que debió prestarse. La indemnización de perjuicios cumple una doble función: es una sanción para el deudor que incumple con dolo o culpa; y, a la vez, es un medio dado al acreedor para que pueda obtener el cumplimiento de la obligación por equivalencia. Cabe observar que la indemnización de perjuicios no es la única forma de resarcir al acreedor en caso de incumplimiento pues también sirven a esa función la resolución del contrato y la nulidad.

3.2 La indemnización de perjuicios es un derecho subsidiario.

En principio el deudor debe cumplir en la forma convenida, no pudiendo por la misma razón el acreedor solicitar la indemnización sino subsidiariamente, demandando como prestación principal

el cumplimiento de la prestación estipulada. La regla anterior es cierta tratándose de las obligaciones de dar, pero no en las de hacer o en las de no hacer.

3.3 ¿El acreedor tiene un derecho optativo para exigir el cumplimiento de la obligación o la indemnización de perjuicios compensatoria?

Se ha dicho que en las obligaciones de dar el acreedor debe demandar primeramente el cumplimiento de la obligación en la forma convenida. Sin embargo, se ha sostenido que en las obligaciones dar, lo mismo que en las de hacer, producido el incumplimiento, el acreedor tendría el derecho a demandar, a su elección, o el cumplimiento de la obligación o la indemnización de perjuicios. Ello porque si bien los artículos 1553 y 1555 del CC establecen esta opción únicamente para las obligaciones de hacer y no hacer, contiene un principio que es general y que, por lo mismo, se debe extender a las obligaciones de dar. Se agrega que, por lo demás, esta es la solución que da el CC cuando existe una cláusula penal, que es una forma e indemnización de perjuicios, y el deudor está constituido en mora.



Alessandri es de opinión que se debe solicitar el cumplimiento forzado de la obligación y sólo cuando esto no fuere posible puede reclamar la indemnización de perjuicios compensatoria. Señala que los artículos 1553 y 1555 del CC son normas de excepción y que de aceptarse la tesis contraria la obligación se transformaría en alternativa, cuya elección correspondería al acreedor, situación que por ser excepcional, tendría que consignarla expresamente la ley.

Stitchkin está por la segunda tesis por estimar que es la que mejor se ajusta al espíritu de la legislación y a la equidad. No se ve por qué el hecho de que el deudor incumpla justificaría modificar el objeto de la prestación. El artículo 1672 del CC autoriza a cobrar el precio de la cosa cuando la especie o cuerpo cierto perece por culpa del deudor; luego, si la cosa no perece, el deudor sólo es obligado a ella. Asimismo, el primer número del artículo 438 del CC ordena que la ejecución recaiga sobre la especie o cuerpo cierto debida cuando existe en poder del deudor. Concluye que no cabe duda que tratándose de una obligación de dar el acreedor debe exigir previamente el cumplimiento de la obligación, si no opta por la resolución del contrato, cuando procede, y sólo en caso de no ser posible el cumplimiento puede exigir la indemnización de perjuicios moratoria. Se señala que ha quedado de manifiesto que cada vez que la ley dio facultad de elegir indistintamente al acreedor, lo dijo especialmente.

3.4 Clases de indemnización.

La indemnización de perjuicios puede ser compensatoria o moratoria.

Indemnización de perjuicios compensatoria es la cantidad de dinero a que tiene derecho el acreedor para repararle el perjuicio que le reportó el incumplimiento total o parcial de

la obligación. Es la evaluación en dinero del interés que el acreedor tenía en que la obligación fuera ejecutada. **La indemnización de perjuicios moratoria** es aquella que tiene por objeto reparar al acreedor el perjuicio sufrido por el incumplimiento tardío de la obligación. No es otra cosa que la evaluación en dinero del interés que tenía el acreedor en que la obligación fuera ejecutada en la época en que debía serlo. En ambos casos la indemnización se paga en dinero por ser una común medida de valores.

No se puede acumular el cumplimiento y la indemnización de perjuicios compensatoria, pero sí el cumplimiento y la indemnización de perjuicios moratoria.

Como la indemnización compensatoria equivale al cumplimiento de la obligación, no se puede demandar conjuntamente el cumplimiento más indemnización compensatoria, porque importaría un doble pago. Pero sí se puede pedir cumplimiento e indemnización moratoria porque esta última sólo resarce los perjuicios provenientes del atraso, y ello está expresamente permitido en el artículo 1553 del CC. Por excepción en la cláusula penal, veremos que se puede acumular el cumplimiento de la obligación y la pena, conforme al artículo 1537 del CC. Y también se pueden demandar ambas indemnizaciones, compensatoria y moratoria, porque se refieren a perjuicios diferentes.

3.5 Requisitos de la indemnización de perjuicios.

Los requisitos de la indemnización de perjuicios, que rigen tanto para la compensatoria como para la moratoria, son los siguientes:

- a) Incumplimiento del deudor.
- b) Perjuicio del acreedor.
- c) Relación de causalidad entre el incumplimiento y los perjuicios.
- d) Imputabilidad del deudor, por dolo o culpa.
- e) Que no concurra una causal de exención de responsabilidad.
- f) Mora del deudor.

Tema 4: Incumplimiento del Deudor.

4.1 Generalidades.

El deudor debe incumplir una obligación derivada de un contrato. **Si no existe un contrato previo entre las partes no puede existir responsabilidad contractual.** Es necesario que se trate de un contrato válido, pues en caso contrario, y en virtud del efecto retroactivo de la nulidad, declarada ésta las partes vuelven al estado anterior.

4.2 Ámbito de aplicación de estas normas.

Constituyen el derecho común en materia de indemnización de perjuicios, aplicándose cualquiera sea el origen de la obligación incumplida, contractual, cuasicontractual, legal, etc. No se aplican, en cambio, a los siguientes casos:

- a) Cuando la ley ha dado reglas distintas, como ocurre en la responsabilidad extracontractual, proveniente de los delitos o cuasidelitos civiles que trata especialmente esa materia.
- b) Cuando las partes se han dado reglas especiales haciendo uso del principio de la autonomía de la voluntad.

Tema 5: Perjuicio del Acreedor.

5.1 Generalidades.



El perjuicio o daño, puede definirse como **el detrimento, menoscabo o lesión que sufre una persona, tanto en su persona como en sus bienes.** Si se produce el incumplimiento de un contrato pero éste no genera perjuicios al acreedor, no hay lugar a la indemnización de perjuicios, por ejemplo, hipoteca que no se inscribe pero que igualmente no se habría alcanzado a cubrir debido al bajo precio en que se remató el inmueble.

5.2 Prueba de los perjuicios.

Corresponde al actor conforme a lo dispuesto en el artículo 1698 del CC. Por excepción, en algunos casos no es necesario probarlos:

- i. Cuando existe una cláusula penal, conforme al artículo 1542 del CC.

ii. Tratándose de la indemnización moratoria en el incumplimiento de una obligación de dinero, conforme al segundo número del artículo 1559 del CC.

De conformidad al artículo 173 del CPC, el acreedor que ha sufrido un perjuicio proveniente del incumplimiento de un contrato, puede adoptar dos caminos:

- i. Demandar su pago, litigando inmediatamente sobre su especie y monto.
- ii. Solicitar únicamente que se declare su derecho a cobrar perjuicios y se le reserve el derecho para discutir la especie y monto de ellos en juicio aparte o en la ejecución del fallo.

Se ha fallado que no es necesario señalar en la demanda una suma determinada como indemnización, basta con solicitar que se paguen los perjuicios experimentados, cuyo monto queda entregado a la apreciación del tribunal. Conviene precisar que en materia de responsabilidad contractual las facultades del tribunal para regular los perjuicios son más restringidas que en el caso de la responsabilidad extracontractual.

5.3 Clases de perjuicios.

Los perjuicios admiten diversas clasificaciones:

1. Daño moral y daño material.
2. Daños directos y daños indirectos, pudiendo los primeros ser previstos e imprevistos.
3. Daño emergente y lucro cesante.

Daño material es el menoscabo que directa o indirectamente experimenta el patrimonio del acreedor como consecuencia del incumplimiento del contrato. **Daño moral** es aquel que produce una perturbación injusta en el espíritu del acreedor, sin afectar su patrimonio. Se ha dicho que es aquel que, sin recaer en un bien material susceptible de ser avaluado en dinero, causa un perjuicio en la psiquis del individuo, ya sea dañando sus afecciones íntimas, ya bienes morales que a éste le pertenecen, ya impidiendo al perjudicado la adquisición de bienes no materiales, siempre que unos y otros sean lícitos o esencialmente internos. Es preferible hablar de daños extrapatrimoniales con el objeto de permitir que las personas jurídicas puedan demandar este tipo de perjuicios, como lo han declarado algunas sentencias extranjeras. Conviene precisar que hay distintas posiciones sobre lo que se debe entender por daño moral. Tradicionalmente se ha enseñado que consiste y encuentra su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que causa a una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos o afectos. Según otro criterio, el daño moral importa la lesión a un derecho extrapatrimonial de la víctima. Y todavía, según una

tercera posición, para que se produzca daño moral es suficiente que la lesión de un interés extrapatrimonial de la víctima. Cabe destacar que no es irrelevante el concepto de daño moral que se siga, pues, en efecto, si está constituido por el dolor de la víctima, no procedería respecto de las personas jurídicas por ser incapaces de sufrir. Finalmente, si se estima que el daño moral se produce por la sola lesión de un derecho o de un interés extrapatrimonial, la reparación debe hacerse preferentemente en forma no pecuniaria.

Las otras clasificaciones de daño se verán al estudiarse la evaluación de los perjuicios.

Tema 6: Relación de Causalidad Entre el Incumplimiento y los Perjuicios.

6.1 Generalidades.

Los perjuicios que se indemnizan son los que provienen del incumplimiento.

De existir un nexo o relación inmediata, de causa a efecto, entre el acto o hecho del hombre, acción u omisión, y el evento o daño, de manera que se pueda inferir de ese nexo que el daño no se habría verificado si aquel acto, el cual acto, pues, debe ser premisa necesaria para la verificación del daño. En el CC se desprende esta exigencia del artículo 1556 que dispone: *“La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”* y, con más claridad todavía, del artículo 1558 que establece que en caso de incumplimiento con dolo, el deudor: *“Es responsable de todos los perjuicios que fueron una consecuencia inmediata y directa de no haberse cumplido la obligación o de haber demorado su cumplimiento”*. Consecuencia importante de lo anterior es que no se indemnizan los perjuicios indirectos ni aún en el caso de haberse incumplido con dolo. El requisito del nexo causal no sólo se exige en la responsabilidad contractual, sino también en la extracontractual, por cuanto, sólo se indemniza el daño proveniente del hecho ilícito.

6.2 Pluralidad de causas. Problema de las concausas.

Precisar el nexo causal es fácil cuando el daño proviene de una sola causa, pero la realidad demuestra que no siempre las cosas ocurren de esa manera. Para resolver los problemas que esta situación plantea se han desarrollado diversas teorías, siendo la más conocida **la de las equivalencia de las condiciones, la de la causa próxima y la de la causa eficiente**. Para la primera, que es la que ha tenido mayor acogida en las sentencias de nuestros tribunales, todo efecto es el resultado de la conjugación de todas las condiciones, que deben ser consideradas equivalentes en lo causal y en lo jurídico, de manera que constituyen *condictio sine qua non* del resultado final. En cambio, según la doctrina de la causa próxima, sólo constituyen causa aquellas condiciones necesarias de un resultado que se halla temporalmente más próxima a éste, las otras son simplemente condiciones. Por último, los que sustentan la teoría de la causa eficiente afirman que

todas las condiciones no tienen la misma eficacia en la producción del resultado, por lo que no son equivalentes, y debe estarse entonces a la más activa o eficaz.

Tema 7: Imputabilidad del Deudor. Dolo o Culpa del Deudor.

7.1 Generalidades.

Para que se genere la obligación de indemnizar perjuicios el incumplimiento debe ser imputable al deudor, es decir, debe provenir de su dolo o culpa.

7.2 Dolo contractual.

El artículo 44 del CC define al dolo como: “La intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. De atenernos a esta definición el dolo sólo existiría cuando la acción u omisión del deudor se realiza con la intención premeditada de causar un daño a la persona o propiedad de otro. De esta forma, quedaría descartado que pueda estimarse como dolosa la conducta del sujeto que si bien no tuvo la intención de causar daño, pudo representarse que su actuar sí podía producirlo, lo que constituye dolo eventual. Rodríguez Grez sostiene que d entender que sólo hay dolo cuando existe una intención maliciosa, hace punto menos que imposible su prueba. No se debe creer pues, sostiene, que hay dolo sólo porque existe un propósito deliberado de perjudicar al acreedor, animus nocendi, lo cual fuera de ser poco común puede ser hasta enfermizo, sino también, y en la práctica así ocurre, por la negativa consciente al cumplimiento, pensándose más que en el perjuicio a otro, en la ventaja pecuniaria que ello puede reportar.

7.3 Campos en que incide en dolo civil.

Como es sabido, el dolo, en materia civil, incide en tres campos distintos:

1. **En la fase formación del consentimiento**, como vicio del mismo, en los artículo 1458 y 1459 del CC.
2. **En la fase de cumplimiento de los contratos**, cuando el deudor deja de cumplir una obligación contractual con la intención positiva de causar un perjuicio al acreedor.
3. Finalmente, **en la responsabilidad extracontractual**, como una elemento de esa responsabilidad, alternativo a la culpa, conforme a los artículo 2314 y siguientes del CC.

Ahora nos corresponde estudiar el dolo en la fase de cumplimiento de los contratos como un elemento de la responsabilidad contractual, alternativo también a la culpa.

7.4 Teoría unitaria del dolo.

El dolo opera en los tres campos que hemos señalado. El concepto en todos ellos es el mismo. Por eso se habla de un concepto unitario del dolo. Ello se colige de los siguientes antecedentes:

- a) Está definido en el título preliminar, de donde se sigue que su aplicación es de alcance general.
- b) Siempre importa una intención dirigida a perjudicar a otro.
- c) El efecto del dolo en cualquiera de los campos tiende a restablecer la situación anterior a él, nulidad cuando es vicio del consentimiento, obligación de indemnizar en los otros casos.
- d) Las reglas que gobiernan al dolo son las mismas, por ejemplo, no se presume.

7.5 Prueba del dolo.

El artículo 1459 del CC señala **que el dolo no se presume**, sino en los casos especialmente previstos por la ley. Esta norma es de aplicación general, a pesar de estar contemplada para el dolo como vicio del consentimiento. Ello resulta absolutamente concordante con el principio de que la buena fe no se presume, que si bien está establecido en materia posesoria, hay unanimidad para considerarlo como principio general. El dolo se puede probar por cualquier medio probatorio, sin que rijan las limitaciones que para la prueba de testigos establecen los artículos 1708 y siguientes del CC. Por excepción hay casos en que presume, como el artículo 1301 del CC en materia de albaceas que llevan a cabo disposiciones del testador contrarias a la ley, o la regla quinta del artículo 968 del CC sobre ocultamiento de testamento.

7.6 Efectos de dolo en el incumplimiento de las obligaciones.

Su efecto es el de agravar la responsabilidad del deudor de conformidad al artículo 1558 del CC. De acuerdo a dicha disposición lo normal es que el deudor responda sólo de los perjuicios directos previstos, o que pudieron preverse, al tiempo del contrato. Mas, si hay dolo, se responderá además de los perjuicios directos imprevistos. Además, si la especie debida se destruye en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de ésta en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo, conforme lo dispuesto en el artículo 1680 del CC. Se ha entendido también que si son varios los deudores que incumplen con dolo, su responsabilidad sería solidaria conforme al segundo inciso del artículo 2317 del CC, que si bien se encuentra ubicada en la responsabilidad extracontractual, se entiende que su alcance es general.

7.7 El dolo no se puede renunciar anticipadamente.

Así lo establece el artículo 1465 del CC. Puede, no obstante, renunciarse el dolo pasado siempre que se haga en forma expresa, de acuerdo al mismo artículo.

7.8 El dolo se aprecia en concreto, no en abstracto, como la culpa.

Significa que en cada caso deberá el tribunal resolver si la conducta del hechor resulta o no dolosa. En cambio, en la culpa se aprecia en abstracto, esto es, comparándola con un modelo ideal definido en la ley.

7.9 De la culpa contractual.

Se entiende por culpa la omisión de la diligencia que se debe emplear en el cumplimiento de una obligación o en la ejecución de un hecho, y por culpa contractual la falta del cuidado debido en el cumplimiento de un contrato.

Se ha discutido en doctrina si la culpa es una sola, teoría unitaria de la culpa, o si es diferente la culpa contractual de la extracontractual. Los que piensan que es una sola argumentan que cualquiera que sea el campo en que juegue, implica una actitud descuidada, negligente, falta de cuidado, que conduce a un mismo resultado, indemnización de perjuicios. Es cierto, dicen, que hay algunas diferencias, como que en la culpa contractual hay una graduación de la culpa, grave, leve, levísima; lo que no ocurre en materia extracontractual que es una sola. Pero, agregan, ello se explica porque al existir en la responsabilidad contractual un vínculo jurídico entre las partes, ello hace que el deber de cuidado pueda ser diferente atendida la naturaleza de cada contrato.

7.10 Diferencias entre la culpa contractual y extracontractual.

- i. La culpa contractual supone un vínculo previo entre las partes; la extracontractual no.
- ii. La culpa en la responsabilidad contractual admite grados, grave, leve y levísima; en materia de responsabilidad extracontractual la culpa es una sola.
- iii. La culpa contractual se presume, como lo veremos; la extracontractual debe probarse.
- iv. Para que la culpa extracontractual de origen a la indemnización de perjuicios, es menester que el deudor se haya constituido en mora, condición previa para que el acreedor pueda exigir indemnización al deudor que viola su obligación. Tratándose de la culpa delictual, no es necesario constituir en mora al deudor, basta la ejecución del simple hecho ilícito para que el acreedor tenga acción por los perjuicios en contra del deudor.

7.11 Gradación de la culpa.

El artículo 44 del CC contempla una clasificación tripartita de la culpa en grave, leve y levísima al dispone: “La ley distingue tres especies de culpa o descuido. **Culpa grave, negligencia grave, culpa lata**, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias

civiles equivale al dolo. **Culpa leve**, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado”. Como puede observarse, la culpa contractual se aprecia en abstracto, pues la ley compara la conducta del sujeto con un modelo ideal. El juez debe ubicar el arquetipo establecido en la ley en la misma situación en que se encuentra el sujeto cuyos actos trata de juzgar.

7.12 La culpa grave equivale al dolo.

Así lo dice el artículo 44 del CC. Se ha fallado que ello no significa que ésta deba probarse igual que aquel, aunque dicha situación se critica porque:

- i. Porque el artículo 44 del CC no hace excepciones sino que equipara en forma absoluta ambos conceptos.
- ii. Porque la norma viene de Pothier que le daba al principio un alcance amplio.
- iii. Porque no parece lógico presumir la culpa grave contractual en circunstancias que ni el dolo ni la mala fe se presumen por expresa disposición del legislador.

Si la culpa grave en materia civil se asimila o equivale al dolo, ello implica que la culpa grave debe probarse al igual que el dolo. Si la culpa grave se presumiera, como consecuencia de que deba probarse la diligencia debida por quien está obligado a prestarla, y los efectos de la misma fueran los que corresponden al dolo, ello implicaría que sería más grave y perjudicial incumplir una obligación con culpa grave que incumplirla con dolo. Sin embargo, según la mayor parte de la doctrina, la equivalencia no tiene alcances probatorios. Por consiguiente, tratándose de culpa, cualquiera que ella sea, incluso grave, se presume siempre, por lo que corresponde al deudor probar el descargo, acreditando que ha empleado la diligencia debida; en cambio en el dolo, la prueba corresponde al acreedor. El alcance de la asimilación, según la doctrina mayoritaria, es simplemente que cuando el deudor incumple con culpa grave, su responsabilidad se agrava, igual que en el dolo, respondiendo de todos los perjuicios directos, previstos o imprevistos. Además, no podría renunciarse anticipadamente la culpa grave, conforme al artículo 1465 del CC; y si hay culpa grave de varios deudores, su responsabilidad sería solidaria conforme al segundo inciso del artículo 2317 del CC.

7.13 De qué culpa responde el deudor.

La primera regla que debe aplicarse es que el deudor responde de la culpa a que se haya obligado. Ello porque esta es una materia en que las partes, en virtud del

principio de la autonomía de la voluntad, pueden alterar las reglas de responsabilidad establecidas por la ley, con algunas limitaciones que luego veremos. Así lo señala el artículo 1547 del CC: “Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes y de las estipulaciones expresas de las partes”. Si las partes nada han acordado, entra a operar lo dispuesto en el artículo 1547 del CC según el cual para saber de qué culpa responde el deudor debe distinguirse según el contrato de que se trate, siendo la responsabilidad del deudor mayor en aquellos casos en que él es el único beneficiado y menor, cuando el principal beneficiado es el acreedor. Dicha disposición señala: “El deudor no es responsable sino de la culpa lata en aquellos contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor; es responsable de la leve en los contratos que se hacen en beneficio recíproco de las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio”. Lo normal es que responda hasta de la culpa leve.

7.14 Cláusula para alterar la responsabilidad de las partes.

El inciso final del artículo 1547 del CC permite a las partes alterar el grado de responsabilidad, idea que repite el inciso final del artículo 1558 del CC. Luego, las partes pueden celebrar distintos pactos para modificar su responsabilidad:

- a) Pueden convenir que el deudor responda de un grado mayor o menor de culpa del que le corresponde en virtud del artículo 1558 del CC.
- b) Puede establecerse que el deudor responda del caso fortuito.
- c) Pueden acordar que el deudor responda en todo caso de los perjuicios imprevistos.
- d) Puede limitarse el monto de la indemnización a pagar. Este pacto se asemeja a la cláusula penal pero es diferente porque se debe probar el perjuicio.
- e) Pueden limitarse los plazos de prescripción. Se estima que ello es factible pues no sería contrario al orden público ya que el propio CC lo permite en casos especiales, como el artículo 1880 en el pacto comisorio y el artículo 1885 en el pacto de retroventa.
- f) Pueden las partes alterar las reglas del onus probandi. Este punto es discutible y, de hecho, en una oportunidad la Corte Suprema estimó nulo por objeto ilícito un pacto que tenía este propósito. Se defiende su validez pues el inciso final del artículo 1547 del CC permite a las partes modificar lo dicho en los incisos anteriores y justamente, en el inciso inmediatamente anterior, se consigna la regla de que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y la prueba del caso fortuito al que lo alega.

7.15 Límites de estas cláusulas modificatorias de responsabilidad.

No pueden las partes:

- a) Renunciar al dolo futuro o a la culpa grave porque ésta equivale al dolo.
- b) Contravenirle orden público o la ley, porque habría objeto ilícito. Así ocurriría, por ejemplo, si las partes ampliaran los plazos de prescripción.

7.16 La culpa contractual se presume.

Este principio se desprende del inciso tercero del artículo 1547 del CC que señala: “La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”. La ley está presumiendo que si incumple es porque no empleó el cuidado a que estaba obligado, a que actuó con culpa. En el artículo 2158 del CC, relativo al mandato, contiene una excepción a esta regla en cuanto permite que el mandante se pueda liberar de sus obligaciones alegando que el negocio encomendado al mandatario no ha tenido buen éxito o que pudo desempeñarse a menos costo, salvo que le pruebe culpa.

7.17 Culpa del deudor por el hecho de personas que dependen de él.

Los artículos 1679 y los incisos primero y tercero del artículo 1590 del CC hacen responsable al deudor por el hecho de terceros que dependen de él. La primera de estas normas expresa que en el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. En el caso de hechos de terceros por quienes no responde el deudor, el acreedor sólo podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero autor del daño, conforme lo dispuesto en el artículo 1590.

Tema 8: Que no Concurra una Causal de Exención de Responsabilidad.

8.1 Generalidades.

Se pueden mencionar como causales de exención de responsabilidad las siguientes, no todas aceptadas, como lo iremos viendo:

- i. Fuerza mayor o caso fortuito.
- ii. Ausencia de culpa.
- iii. Estado de necesidad.
- iv. El hecho o culpa del acreedor, o la mora del acreedor.
- v. La teoría de la imprevisión, cuando por hechos posteriores al contrato se ha producido una alteración grave del equilibrio patrimonial de las prestaciones.

8.2 Fuerza mayor o caso fortuito.

El artículo 45 del CC dispone: “**Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.**”. Se ha señalado que la definición es incompleta por faltarle el requisito de la inimputabilidad, que es indispensable si se considera que nuestro CC sigue el sistema de la responsabilidad subjetiva. Pero se agrega que esta omisión aparece suplida por el artículo 1547 del CC que dispone: “El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que haya sobrevenido por su culpa”. Generalmente se afirma que en la fuerza mayor el hecho imprevisto, imposible de resistir, proviene de un hecho de la naturaleza, como un terremoto o una inundación, en cambio en el caso fortuito proviene de un hecho del hombre, como sería un acto de autoridad.



8.2.1 Elementos del caso fortuito.

➡ Los elementos del caso fortuito son:

- **Hecho inimputable.** Debe ser ajeno al deudor, no debe provenir de su hecho o culpa o del hecho o culpa de las personas por las que él responde.
- **Hecho imprevisto.** Significa que dentro de los cálculos ordinarios de un hombre normal no era dable esperar su ocurrencia. Aquellos poco frecuentes, que por excepción suelen sobrevenir, y que no han sido tomados en cuenta por las partes al momento de contratar. La Corte Suprema ha dicho que el caso fortuito es imprevisto cuando no hay ninguna razón esencial para creer en su realización.
- **Hecho irresistible.** Impide al deudor, bajo todo respecto o circunstancia, poder cumplir. Si puede hacerlo en forma más difícil u onerosa no estamos frente a un caso fortuito. La Corte Suprema ha dicho que es irresistible cuando no es posible evitar sus consecuencias, en términos que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias habría podido preverlo o evitarlo.

8.2.2 Efectos del caso fortuito.

El efecto propio del caso fortuito es liberar de responsabilidad al deudor conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1547 y el inciso segundo del artículo 1588 del CC.

8.2.3 Excepciones en el que el caso fortuito no libera de responsabilidad al deudor.

- a) Cuando el caso fortuito sobreviene por culpa del deudor conforme a los artículos 1547, 1590 y 1672 del CC.
- b) Cuando sobreviene durante la mora del deudor. Esta excepción no rige si el caso fortuito igualmente hubiere sobrevenido si el acreedor hubiere tenido en su poder la cosa debida, conforme a los artículos 1547, 1672 y 1590 del CC.
- c) Cuando se ha convenido que el deudor responda del caso fortuito conforme a los artículos 1547 y 1558 del CC.
- d) Cuando la ley pone el caso fortuito de cargo del deudor, conforme al artículo 1547 del CC, como por ejemplo, respecto del que ha hurtado o robado una cosa.

8.2.4 Prueba del caso fortuito.

El inciso tercero del artículo 1547 y el artículo 1674 del CC establecen que incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega. Constituye una aplicación de la regla general del onus probandi contemplada en el artículo 1698 del CC, según el cual corresponde la prueba de la extinción de una obligación al que alega esta circunstancia. **La prueba del caso fortuito debe comprender los siguientes aspectos:**

- I. Efectividad del suceso al cual se le atribuye esa calidad.
- II. Relación de causa a efecto entre el suceso y los resultados, o sea, nexo de causalidad.
- III. Concurrencia de los requisitos que caracterizan al suceso como caso fortuito.
- IV. La diligencia o cuidado que ha debido emplear el deudor, especialmente es de especie o cuerpo cierto.

Un antiguo fallo ha señalado que para eximirse de responsabilidad por caso fortuito no basta probar de un modo vago y general que se empleó toda la diligencia y cuidado en la conducción; es **necesario justificar el caso de exención de responsabilidad de una manera precisa y con relación al hecho en que se funda**, de suerte que no quede duda acerca del caso fortuito alegado. Constituye una excepción a la regla de que el caso fortuito debe probarse el artículo 539 del CCO en el contrato de seguro, que dice que el siniestro se presume ocurrido por caso fortuito.

8.3 Teoría de los riesgos.

Esta teoría trata de resolver quién debe, en los contratos bilaterales, soportar la pérdida de la especie o cuerpo cierto debido, si el deudor no puede cumplir con su obligación de entregar esta cosa, por haberse destruido por un caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose que el riesgo lo soporta el deudor si, en este supuesto, no puede exigir a la contraparte que cumpla con su propia

obligación; y, por el contrario, lo soporta el acreedor, si éste, aunque no va a lograr la entrega de la cosa, debe, de todas formas, cumplir su propia obligación.

8.3.1 Requisitos para que opere la teoría de los riesgos.

Para que entre a operar la teoría de los riesgos deben cumplirse los siguientes requisitos:

- I. Existencia de un contrato bilateral.
- II. Que la obligación del deudor sea de entregar una especie o cuerpo cierto.
- III. Que la cosa debida se pierda o destruya totalmente como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor.

8.3.2 Principio contenido en el CC en materia de riesgos.

La regla de esta materia está contenida en el artículo 1550 del CC que dispone: **“El riesgo del cuerpo cierto cuya entregase deba, es siempre a cargo del acreedor”**. Esta regla es manifiestamente injusta, pues contradice el principio de que las cosas perecen para su dueño. En efecto, celebrado el contrato y antes de la tradición de la cosa, el deudor continúa siendo dueño, por lo que si la cosa se destruye fortuitamente, debería ser él quien debiera soportar su pérdida, no pudiendo por ello exigir a su contraparte el cumplimiento de su propia obligación. La explicación a ello debe buscarse en que Bello habría copiado esta disposición del Código Francés, sin reparar que allí no se exige la dualidad título modo.

El problema del artículo 1550 del CC no es tan grave porque su ámbito de aplicación es bastante más reducido del que a primera vista aparece. En efecto, sólo viene a regir para las compraventas y las permutas no condicionales. En la compraventa, el artículo 1820 del CC dispone: “La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa, salvo que se venda bajo condición suspensiva y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la especie mientras pende la condición la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro pertenecerá al comprador”. Respecto a la venta condicional, el artículo 1820 del CC guarda perfecta armonía con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 1486 del CC que señala: “Si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación”. En cuanto a la permuta, el artículo 1900 dispone que se le aplican las mismas reglas que a la compraventa.

8.3.3 Casos de excepción en que el riesgo de la especie o cuerpo cierto debido es del deudor.

- i. Cuando el deudor se constituye en mora de entregar la especie o cuerpo cierto debido, conforme al artículo 1550 del CC.
- ii. Cuando el deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas conforme al artículo 1550 del CC.

- iii. Cuando las partes convienen en que el riesgo sea del deudor, cláusula lícita en virtud de los artículo 1547 y 1558 del CC.
- iv. Cuando la ley lo establece, como en el primer número del artículo 1950, el artículo 1486, el artículo 1820 y el artículo 1996 del CC.

8.3.4 Pérdida parcial.

El CC no da reglas especiales, por lo que aplicándose la regla del artículo 1550 del CC el riesgo es del acreedor.

8.4 Ausencia de culpa.

Es la segunda causal de exoneración de responsabilidad del deudor. El problema consiste en determinar si le basta al deudor probar que ha empleado la debida diligencia para liberarse de responsabilidad o deberá probar además la existencia del caso fortuito. La Corte Suprema ha dicho que le basta al deudor acreditar que ha empleado el cuidado a que lo obligaba el contrato, sin que sea necesario probar el caso fortuito. Antes se había estimado lo contrario. Abeliuk opina que es suficiente con que el deudor pruebe su ausencia de culpa. Claro Solar estima que la imputabilidad cesa cuando la inejecución de la obligación o la demora en su ejecución es el resultado de una causa extraña al deudor, o sea de fuerza mayor o caso fortuito.

8.5 Estado de necesidad.

Es la tercera causa de exoneración del deudor. Cabe preguntarse si el deudor queda liberado de responsabilidad en el caso en que pudiendo cumplir, no lo hace para evitar un mal mayor. Se diferencia del caso fortuito en que no hay un impedimento insuperable. La doctrina no es unánime. La tendencia moderna es que el estado de necesidad legitima el hecho y lo convierte en lícito, liberando de responsabilidad al deudor. El CC, en un caso, toca el punto desechando el estado de necesidad: la situación del comodatario que en un accidente, puesto en la alternativa de salvar la cosa prestada o la propia, opta por la última, conforme al tercer número del artículo 2178 del CC. Ello se explica porque el comodatario responde hasta de la culpa levísima.

8.6 Hecho o culpa del acreedor.

Es la cuarta causal de exoneración de responsabilidad del deudor. Nuestro CC no ha reglamentado en forma orgánica la mora del acreedor; la mora accipiendi, pero se refiere a ella en varias disposiciones para exonerar de responsabilidad al deudor, por ejemplo, el artículo 1548 en las obligaciones de dar, libera de responsabilidad al deudor por el cuidado de la especie o cuerpo cierto debido, cuando el acreedor se ha constituido en mora de recibir; el artículo 1680 que repite la misma idea haciendo responsable al deudor sólo de culpa grave o dolo; el artículo

1827 en que se exime al vendedor del cuidado ordinario de conservar la cosa si el comprador se constituye en mora de recibir.

8.7 Teoría de la Imprevisión.

Es la última causal de exoneración de responsabilidad del deudor. En aquellos contratos en que las obligaciones de las partes se van cumpliendo durante periodos prolongados, puede ocurrir que durante la vida del contrato sobrevengan hechos imprevistos y graves, que hagan para una de ellas excesivamente oneroso el cumplimiento de sus obligaciones y siempre que llegue a formarse la convicción de que siendo previsibles estas turbaciones las partes no se habrían obligado en las condiciones fijadas.

8.7.1 Elementos de la imprevisión.

Para que opere la teoría de la imprevisión se requiere de la concurrencia de los siguientes elementos:

- I. Que se trate de un contrato de tracto sucesivo o por lo menos de un contrato de ejecución diferida.
- II. Que por circunstancias sobrevinientes, ajenas a las partes y no previstas, se produzca un desequilibrio patrimonial en las prestaciones.
- II. Que los hechos que producen la alteración sean tan extraordinarios y graves, que si las partes los hubieran tenido a la vista al momento de contratar no habrían contratado o lo habrían hecho en condiciones diferentes.

8.7.2 Posiciones doctrinarias.

Para una primera todo contrato es ley para las partes, que ninguna de ellas puede desconocer aunque hayan variado las condiciones bajo las cuales lo celebraron. Para una segunda, que tuvo su origen en el Derecho Canónico y que cobró mucha fuerza después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia de los fenómenos económicos que de ella se derivaron, debe admitirse por razones de equidad, de moralidad, la revisión de los contratos, cuando varían gravemente y por causas imprevistas, las condiciones bajo las cuales el contrato fue acordado. Contraponen al principio **pacta sunt servanda** el principio **rebus sic stantibus**. Lo anterior porque cada parte al establecer las cláusulas del acto, sólo pensó y sólo pudo pensar en los riesgos normales que podrían ocurrir y de acuerdo con esto formuló sus condiciones. Los acontecimientos anormales, imprevistos, no han podido entrar en sus puntos de vista. Su voluntad se manifestó en relación con el medio existente y los riesgos normales.

8.7.3 Teoría de la imprevisión en Chile.

Se estima que ella no tiene cabida en nuestro derecho porque el artículo 2545 del CC se opone a ella. Un fallo estableció que los tribunales carecen de facultades para derogar o dejar sin cumplimiento la ley del contrato, ya sea por razón de equidad, o bien de costumbres o reglamentos administrativos. Cabe agregar, sin embargo, que hay casos puntuales en que la propia ley la acepta, y otros, por el contrario, en que en forma expresa la rechaza. La acepta, por ejemplo, en la regla segunda del artículo 2003 del CC en el contrato de construcción de edificios cuando aumentan los costos; el artículo 1469 del CC en que se acepta la caducidad del plazo por causas sobrevinientes; el artículo 2180 del CC en el comodato, etc. La rechaza, por ejemplo, en la regla primera del artículo 2003 del CC sobre la construcción de edificios; el artículo 1983 del CC sobre arrendamiento de predios rústicos, etc. El problema se va a presentar en aquellas situaciones en que no hay un pronunciamiento legal. La generalidad de la doctrina la rechaza fundada en el efecto obligatorio de los contratos consagrado en el artículo 1545 del CC.

8.7.4 Argumentos a favor de la teoría de la imprevisión.

No existe ninguna disposición que permita de un modo expreso y franco la aplicación de la teoría de la imprevisión. Para ello se recurre a interpretaciones poco aceptables, como las siguientes:

- I. El artículo 1560 del CC dispone: “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”.
- II. El artículo 1546 que obliga a las partes a cumplir el contrato de buena fe.
- III. Toda persona al contratar contrae un determinado deber de cuidado, y si cambian las condiciones pasaría a asumir un riesgo que va más allá del que el deudor aceptó al momento de contratar.
- IV. Por lo general, conforme al primer inciso del artículo 1558 del CC el deudor responde únicamente de los perjuicios previstos, y si las circunstancias cambian se estaría respondiendo de perjuicios indirectos.

Tema 9: Mora del Deudor.

9.1 Generalidades.

Es el último requisito de la indemnización de perjuicios. Es exigido en el artículo 1557 del CC que dispone: “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora”. Reitera esta misma idea el artículo 1538 del CC en materia de cláusula penal que señala: “Háyase o no estipulado un término dentro del cual deba cumplirse la obligación principal, el deudor no incurre en la pena sino cuando se ha constituido en mora”. Esa exigencia rige tanto para la indemnización compensatoria como para la moratoria. Se afirma que en las obligaciones de no hacer no se requiere el requisito de la mora del deudor, pues en conformidad al artículo 1557 del

CC en este tipo de obligaciones la indemnización se debe desde el momento de la contravención. Por nuestra parte, creemos que también en este caso se requiere mora, con la diferencia que ésta se produce por el sólo hecho de la contravención.

9.2 Concepto de la mora.

Se define a la mora como el retardo imputable en el cumplimiento de la obligación, unido al requerimiento o interpelación por parte del acreedor. Otros dicen que es el retardo culpable en el cumplimiento de la obligación, más allá de la interpelación del acreedor.

9.3 Requisitos de la mora.

Los requisitos son:

- Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación.
- Que el retardo sea imputable, con dolo o culpa.
- Interpelación del acreedor.
- Que el acreedor haya cumplido su obligación o se allane a cumplirla.

9.3.1 Que el deudor retarde el cumplimiento de la obligación.

El retardo es el antecedente necesario de la mora, pero sólo el antecedente, no la mora misma, pues el retardo puede deberse a caso fortuito o fuerza mayor, caso en que no habrá mora. Se debe distinguir, entonces, entre exigibilidad, retardo y mora:

- I. La obligación es exigible cuando no se halla sujeta a modalidades suspensivas.
- II. Se retarda el cumplimiento de la obligación cuando no se cumple en la oportunidad debida, pero el sólo retardo no implica mora, que exige otros requisitos: imputabilidad e interpelación.
- III. La mora supone el retardo imputable del deudor más allá de la interpelación hecha por el acreedor.

9.3.2 Que el retardo sea imputable del deudor.

Es necesario que el atraso en cumplir sea debido al dolo o culpa del deudor. El artículo 1558 del CC claramente exige el requisito de la imputabilidad al decir: “La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios”. Lo que quiere expresar la norma es que si hay caso fortuito o fuerza mayor no hay indemnización de perjuicios porque no hay mora.

9.3.3 Interpelación del acreedor.

Se define como el acto por el cual el acreedor hace saber al deudor que su retardo le causa perjuicios. Conforme al artículo 1551 del CC hay tres formas de interpelación: “El deudor está en mora: 1° Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en casos especiales exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora; 2° Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada dentro de cierto espacio de tiempo y el deudor la ha dejado pasar sin darla o ejecutarla; 3° En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor”. Atendido lo dispuesto en esta disposición, la interpelación se produce en cualquiera de estos tres casos, constituyendo la regla general el contemplado en el tercer número.

9.3.3.1 Interpelación contractual expresa.

Es la contemplada en el primer número del artículo 1551 del CC. **Opera cuando las partes han establecido un plazo en el contrato, para que el deudor cumpla su obligación.** Por el solo hecho de cumplirse el plazo, el deudor queda constituido en mora, salvo que la ley exija que se le requiera para constituirlo en mora, por ejemplo, el artículo 1949 del CC en materia de arrendamiento. Es preciso que se trate de un plazo convenido por las partes, pues la norma habla de no haberse cumplido la obligación dentro del término estipulado. Por ello, no rige, por ejemplo, en el caso en que haya sido establecido por el testador, para pagar un legado, caso éste en que será necesario constituir en mora al deudor, requerirlo judicialmente. Si se trata de obligaciones de cumplimiento fraccionado, la mora respecto de cada cuota se irá produciendo al vencimiento del plazo establecido para su pago. Ello, sin perjuicio de que pueda haberse convenido una cláusula de aceleración que pueda producir la caducidad del plazo y, por consiguiente, la mora respecto de todo el saldo insoluto.

9.3.3.2 Interpelación contractual tácita.



Se encuentra establecida en el segundo número del artículo 1551 del CC. Se le llama interpelación tácita **porque a pesar de que no se ha establecido en forma expresa un plazo dentro del cual debe cumplirse la obligación, ésta, por su propia naturaleza y por la forma en que fue convenida, tiene un plazo tácito para cumplirse**, por ejemplo, el traje de novia que tiene que estar terminado antes del matrimonio.

9.3.3.3 Interpelación judicial o extracontractual.

Está contemplada en el tercer número del artículo 1551 del CC. Constituye la regla general. **La regla es, entonces, que para que el deudor quede constituido en mora se le debe demandar.** Está claro que no es necesaria una gestión judicial en que específicamente se solicite que se constituya en mora al deudor. Se ha entendido que cualquier gestión judicial destinada a que el

acreedor haga efectivos sus derechos para el caso de que el deudor incumpla es suficiente requerimiento judicial. Así, satisfacen este objeto una demanda en que se pida el cumplimiento del contrato o su resolución, o si se demandan perjuicios, etc. Respecto al momento en que el deudor se entiende constituido en mora, entendemos que lo es cuando se le notifica válidamente la demanda, y así lo ha entendido en general la jurisprudencia. Se ha fallado que para que el deudor quede constituido en mora el requerimiento debe hacerse ante juez competente.

Que el acreedor haya cumplido su obligación o se allane a cumplirla (en la forma y tiempo debido). Este último requisito de la mora está contemplado en el artículo 1552 del CC que dispone: “En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debido”.

9.4 Efectos de la mora.

Los efectos de la mora son los siguientes:

I. El acreedor puede demandar indemnización de perjuicios.

Se discute desde cuando se deben pagar los perjuicios, si desde la fecha de la constitución en mora o desde que se produjo el incumplimiento. Algunos autores afirman que constituido el deudor en mora debe éste pagar los perjuicios producidos desde el retardo, pues no hay ninguna norma que descarte la zona intermedia entre el simple retardo y la interpelación judicial. Se trata de sancionar un acto ilícito e injusto. Otros autores, en cambio, distinguen entre los perjuicios compensatorios y los moratorios. Los primeros se producen por el solo incumplimiento conforme al artículo 1672 del CC; en cambio, los perjuicios moratorios sólo se van a general con la constitución en mora como dispone el primer número del artículo 1559 del CC.

II. El deudor se hace responsable del caso fortuito.

Ello lo establece el segundo inciso del artículo 1547 del CC. La regla tiene una excepción en que a pesar de la mora del deudor, éste no responde del caso fortuito. Ello ocurre si el caso fortuito hubiese sobrevenido a pesar de haberse cumplido oportunamente la obligación, hecho que deberá probar el deudor conforme al artículo 1674 del CC.

III. El riesgo de la especie o cuerpo cierto debido que normalmente es del acreedor pasa al deudor conforme al primer inciso del artículo 1550 del CC.

9.5 Mora del acreedor.

El CC no ha reglamentado en forma orgánica la mora del acreedor, pero varias disposiciones se refieren a ella, como los artículos 1548, 1552, 1599, 1680 y 1827 del CC.

9.5.1 Desde cuando está en mora el acreedor.

No cabe aplicar el artículo 1551 del CC, porque esta disposición se refiere a la mora del deudor. Según algunos, desde que el deudor haya debido recurrir a pagar por consignación. Según otros, debe aplicarse por analogía e tercer número del artículo 1551 del CC y concluir que estará en mora desde que sea judicialmente reconvenido. Finalmente, y ésta es la doctrina más aceptada, se estima que basta cualquier ofrecimiento del deudor, incluso extrajudicial, para constituir en mora al acreedor, como lo confirmaría el artículo 1680 del CC que no hace ninguna exigencia especial, bastando que la especie o cuerpo cierto sea ofrecida al acreedor.

9.5.2 Efectos de la mora del acreedor.

Los efectos que se producen con la mora del deudor son los siguientes:

1. **Disminuye la responsabilidad del deudor**, pues sólo va a responder de la culpa grave o dolo en el cuidado de la cosa, conforme a los artículos 1680 y 1827 del CC. Además queda revelado de los perjuicios moratorios.
2. **El acreedor debe indemnizar los perjuicios que se sigan de no recibir la cosa**, como lo prueba el artículo 1827 del CC, ubicado en la compraventa pero que tiene un alcance general, y que dispone: “Si el comprador se constituyere en mora de recibir abonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido”.
3. **Si el deudor tuvo que pagar por consignación**, debe pagar las expensas de la oferta y consignación válidas, conforme al artículo 1604 del CC.

Unidad 6: De la Evaluación de los Perjuicios.

Hay tres formas de evaluar los perjuicios:

- i. La evaluación judicial.
- ii. La evaluación legal.
- ii. La evaluación convencional o cláusula penal.

Lo normal viene a ser la evaluación judicial, pues la regla general sólo procede respecto de las obligaciones de dinero, y la convencional supone un acuerdo entre las partes que no siempre se da.

Tema 1: Evaluación Judicial.

Es la que hace el juez. Para ello debe pronunciarse sobre tres cuestiones:

- a) Primero, determinar si procede el pago de la indemnización, para lo cual el tribunal tendrá que ver si se cumplen los requisitos generales que hemos estudiado.
- b) Determinar los perjuicios que deben indemnizarse.
- c) Fijar el monto de los perjuicios.

Tema 2: Perjuicios que deben indemnizarse.

Para estos efectos, recordemos los diversos tipos de perjuicios:

- i. Compensatorios y moratorios.
- ii. Ciertos y eventuales.
- iii. Directos e indirectos.
- iv. Daños materiales y morales.
- v. Daño emergente y lucro cesante.
- vi. Perjuicios previstos e imprevistos.

2.1 Daño moral o extrapatrimonial.

Durante años se consideró que el daño moral no se indemnizaba en materia contractual. Sin embargo, se aceptaba su indemnización en la responsabilidad extracontractual, en virtud del existir la regla del artículo 2329 del CC que establece: **“Por regla general todo daño que**

pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta”. Se decía que faltaba en la responsabilidad contractual una norma que contemplara lo mismo. Esta solución resulta manifiestamente injusta. Desde hace varios años la doctrina venía señalando que hay en este trato discriminatorio una grave inconsecuencia. La tendencia actual de la doctrina es aceptar la indemnización del daño moral en la responsabilidad contractual. Pero en general, la jurisprudencia sostenía que no procedía indemnizar el daño moral en la responsabilidad contractual. Sólo recién en las últimas décadas empieza a cambiar, y ya encontramos varios fallos que lo aceptan. Las **razones que se han dado para no indemnizar el daño moral son las siguientes:**

- i. En primer lugar, la ya explicada que faltaba una norma como la del artículo 2329 del CC aplicable a la responsabilidad extracontractual.
- ii. En seguida, que el artículo 1556 del CC establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, conceptos éstos de claro contenido patrimonial y no menciona el daño moral.
- iii. Que es difícil su prueba y evaluación.

En realidad, ninguno de los argumentos es categórico. En efecto, si falta la norma nos encontramos frente a una laguna legal que el juez, en conformidad al artículo 24 del CC debe llenar recurriendo a los principios generales del derecho y a la equidad natural. En cuanto a que el artículo 1556 del CC no lo contempla, es verdad, pero tampoco lo prohíbe. Finalmente no es serio sostener que no debe indemnizarse por ser de difícil prueba y evaluación, desde que en materia extracontractual el problema es el mismo y se pagan. Sin embargo, el daño moral se funda hoy en Chile en el inciso primero del primer número y el cuarto número del artículo 19 de la Constitución Política de la República que asegura a todas las personas tanto el derecho a la integridad física y psíquica como el respeto a la intimidad y vida privada y no en el artículo 1556 del CC. Estamos porque se indemnice el daño moral, pero también creemos que debe existir una prueba clara y concluyente de su existencia. Pensamos que para su regulación el tribunal debe tener facultades amplias semejantes a las que la jurisprudencia ha reconocido para la responsabilidad extracontractual. Pero también debe tenerse claro que el incumplimiento de cualquier contrato no puede ser fuente de daño moral. Estamos de acuerdo con que en materia contractual el daño moral no se configura por cualquier molestia que resulte del incumplimiento, no debe confundirse con las inquietudes propias del mundo de los negocios o las que normalmente resultan de los pleitos, para que ello ocurra es menester que se haya turbado seriamente la moral, el honor, la libertad o los afectos del acreedor, o su integridad física, o que tal incumplimiento le haya producido una lesión en sus sentimientos a causa del sufrimiento o dolor que le ha provocado. De allí ha derivado el principio de que si bien los daños no económicos no son reparables necesariamente en materia contractual, ello es posible cuando se trata de contratos que, por su naturaleza, son aptos para causar daños emocionales u otros no patrimoniales, en caso de incumplimiento y que por lo mismo se acostumbra a calificar de personal contracts, como

opuestos a los contratos calificados de comercial que, por no envolver en la previsibilidad de las partes intereses afectivos, de comodidad u otros, no originan daños morales. Parece indudable que la reparación de los daños morales que no se traducen en quebranto material inmediato ha de ser sometida a un régimen jurídico distinto al de aquel que gobiernan los daños propiamente patrimoniales: los requisitos que afectan al nexo causal y a la prueba de los daños morales han de ser tratados con menos severidad que cuando se trata de daños materiales, y ha de ser concedido a los tribunales un amplio arbitrio para su apreciación.

2.2 Daño emergente y lucro cesante.

El artículo 1556 del CC dispone: “La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente u el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento. Exceptúense los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente”. La ley no define estos conceptos. Se estima que **el daño emergente es el empobrecimiento real y efectivo que sufre el patrimonio del deudor**; y **el lucro cesante la utilidad que deja de percibir el acreedor por el incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación**. No es fácil la prueba del lucro cesante, por lo mismo, la prueba que se rinda se debe apreciar con mayor liberalidad. El lucro, a diferencia del daño emergente, es difícil de establecer, por su carácter esencialmente eventual, que lo transforma en un principio jurídico lleno de vaguedades e incertidumbres. Para dar lugar al pago a la indemnización por lucro cesante, debe el tribunal adquirir la convicción de que había una probabilidad cierta del negocio en que se obtendrían la ganancia así como de las utilidades que de él provendrían.

2.3 Perjuicios previstos e imprevistos.

Perjuicios previstos son los que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato conforme al primer inciso del artículo 1558 del CC. Los que no cumplen con estos requisitos son imprevistos. Conforme al artículo 1558 del CC se indemnizan sólo los previstos salvo en los casos de dolo o culpa grave. La Corte Suprema que tiempo del contrato es el periodo durante el cual se desarrolla el contrato, desde su nacimiento hasta el momento en que se haya producido la restitución del inmueble arrendado.

¿Las partes pueden alterar las reglas sobre los perjuicios a indemnizar?



El inciso final del artículo 1558 del CC dispone: “Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”.

Tema 3: Evaluación Legal.

Está establecida en el artículo 1559 del CC que la limita exclusivamente a la indemnización moratoria que se genera por el incumplimiento de una obligación de dinero, al disponer: “Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes...”. La explicación de por qué se contempla la indemnización de perjuicios moratoria y no la compensatoria la encontramos en que en la indemnización compensatoria se paga una suma de dinero que equivale al cumplimiento íntegro de la obligación. Pero si la deuda es de dinero, la suma que se paga no equivale al cumplimiento íntegro sino que es el cumplimiento íntegro.

3.1 Características de la liquidación legal.

- a) El artículo 1559 del CC es una disposición supletoria y excepcional. Supletoria porque sólo rige a falta de pacto entre las partes; excepcional porque se refiere sólo al incumplimiento de las obligaciones de dinero y únicamente a la indemnización moratoria.
- b) Cuando sólo se cobran intereses los perjuicios se presumen, situación absolutamente excepcional ya que la regla es que deben probarse.
- c) Lo anterior se explica porque los intereses representan el perjuicio que el acreedor experimenta si no se le paga con oportunidad el dinero que se le debe.
- d) El acreedor, aparte de los intereses, puede cobrar otros perjuicios, pero para ello deberá probarlos de acuerdo a las reglas generales.

3.2 Reglas del artículo 1559 del CC.

Regla primera. “Se siguen debiendo los intereses convencionales si se ha pagado un interés superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en caso contrario, quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos”. Conforme a la disposición deben distinguirse diversos casos: primero, que las partes hayan pactado intereses convencionales y que éstos sean superiores al interés legal; segundo, que las partes no hayan pactado intereses o que pactándolos hayan sido inferiores al legal; y, tercero, si se está frente a una disposición que autorice el cobro de intereses corrientes en ciertos casos. En la primera situación, se siguen debiendo los intereses convencionales; en la segunda, se empiezan a generar ciertos intereses legales; y, finalmente, estas reglas no rigen en los casos en que la ley autoriza cobrar intereses corrientes.

Regla segunda. Ya la hemos explicado. Sólo resta agregar que se pueden cobrar otros perjuicios siempre que se acrediten.

Regla tercera. Los intereses atrasados no producen interés. No se acepta el anatocismo, o sea, la capitalización de intereses.

Regla cuarta. La regla de que los intereses no generan intereses se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas. Por esta razón si la partes no han convenido otra cosa, las rentas de arrendamiento atrasadas de bienes raíces urbanos no devengan interés. Ello no significa que se deban pagar en valor nominal, pues el artículo 21 de la Ley No. 18.101 establece la reajustabilidad.

Tema 4: Evaluación Convencional o Cláusula Penal.

La cláusula penal se puede tratar como una clase especial de obligaciones o como una manera de avaluar los perjuicios. Ambas posiciones son defendibles porque si bien en la cláusula penal hay una evaluación convencional y anticipada de los perjuicios, su ámbito de aplicación es bastante más extenso. La verdad es que la cláusula penal cumple funciones diversas que la transforman en una institución autónoma.



El artículo 1535 del CC la define al disponer: **“La cláusula penal es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”**. La definición presenta algunas incorrecciones. La primera es su propia denominación cláusula penal, pues ello será así únicamente si se pacta conjuntamente con el contrato principal. También resulta inadecuado decir que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, desde que por sí sola nada garantiza. Finalmente, cabe observar que al establecer que la pena consiste en dar o hacer algo, ha omitido las obligaciones de no hacer, situación perfectamente admisible.

4.1 Funciones que cumple la cláusula penal.

La cláusula penal cumple tres funciones:

1. Es una forma de avaluar convencional y anticipadamente los perjuicios.
2. Constituye una caución.
3. Importa una pena civil.

4.1.1. La cláusula penal constituye una forma de avaluar perjuicios.

No hay disposiciones especiales que le confieran este carácter, pero ello fluye con claridad de diversos artículos, por ejemplo, los artículos 1537 y 1538 del CC que exigen la constitución en mora del deudor; el artículo 1539 del CC que establece la rebaja de la pena estipulada en el caso de incumplimiento parcial; el artículo 1540 del CC que permite dividir la pena entre los distintos herederos del deudor a prorrata de sus cuotas hereditarias.

Como forma de avaluar perjuicios presenta dos características. Es convencional, porque proviene del acuerdo de las partes. Por ello no puede establecerse ni unilateralmente ni por la ley o por el juez. La cláusula penal no es la única forma de avaluar convencional y anticipadamente los perjuicios, porque el mismo carácter tienen las arras confirmatorias. La segunda característica de la cláusula penal como forma de avaluar perjuicios es que es anticipada, ello porque el monto de los perjuicios quedan irrevocablemente fijados antes del incumplimiento. Tanto es así, que producido éste, el deudor no puede discutir ni la existencia ni el monto de estos perjuicios conforme al artículo 1542 del CC.

➡ 4.1.1.1 La cláusula penal puede ser compensatoria o moratoria. Así se desprende de la propia definición legal y así lo ha dicho la jurisprudencia.

➡ 4.1. 1.2 Diferencias entre la cláusula penal con la indemnización de perjuicios ordinaria.

Como indemnización de perjuicios la cláusula penal presenta algunas particularidades:

- i. Desde luego, difiere de la indemnización de perjuicios ordinaria, en cuanto a la oportunidad en que se fija, pues, como ya lo hemos dicho, estamos frente a una indemnización establecida antes del incumplimiento.
- ii. Los perjuicios no se reparan necesariamente en dinero, como ocurre con la valuación legal o judicial, pues en este caso, la pena puede consistir en un dar o en un hacer o en un no hacer.
- iii. No es necesario probar perjuicios. Este caso y el de la valuación legal son las excepciones a la regla de que los perjuicios deben probarse. La cláusula penal no requiere declaración judicial previa acerca de indemnizar perjuicios, exime al acreedor de la carga de probar la existencia de éstos e impide al deudor alegar la inexistencia de los mismos.

4.1.2 La cláusula penal constituye una caución.

Tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, por lo que cae dentro del concepto de caución que señala el artículo 46 del CC. Por lo demás, es mencionada como tal en el artículo 1472 del CC, al lado de la fianza, la hipoteca y la prenda. Demuestra su condición de

caución el que se pueda acumular el cumplimiento de la obligación principal y la pena conforme al artículo 1537 del CC; la indemnización ordinaria y la pena, de acuerdo al artículo 1543 del CC; y, que pueda exigirse la pena aunque no se hubieren producido perjuicios, conforme al artículo 1542 del CC. Sin embargo, debe considerarse que la cláusula penal por sí sola no asegura el cumplimiento de la obligación principal. Sólo sirve de estímulo para que el deudor cumpla. Su condición de caución se robustece cuando se constituye para garantizar una obligación ajena, pues en ese supuesto hay dos patrimonios que van a estar respondiendo del cumplimiento de la obligación. Como caución es personal, porque no afecta bienes determinados al cumplimiento de la obligación que puedan perseguirse en poder de terceros, como ocurre con la prenda o la hipoteca.

4.1.3 La cláusula penal constituye una pena civil.

Así está dicho en su propia definición legal. Nació en el derecho romano con una finalidad estrictamente sancionadora, carácter que aún conserva.

4.2 Paralelo de la cláusula penal con otras instituciones.

Se asemeja a la fianza pero se diferencia de ésta en que el fiador sólo se obliga a pagar una suma de dinero, en tanto que la cláusula penal puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Tampoco el fiador puede obligarse en términos más gravosos que el deudor principal, limitación que no existe en la cláusula penal.

Se asemeja también con las arras. En éstas se da una cosa con el fin de constituir una seguridad de la celebración o ejecución de un contrato, o como parte del precio o señal de quedar convenidos. Sin embargo, las arras garantizan la celebración de un contrato y no el cumplimiento de una obligación. Además en las arras hay una entrega actual de dinero u otra cosa, lo que no ocurre en la cláusula penal en que la entrega sólo se va a producir cuando se manifieste el incumplimiento.

4.3 Características de la cláusula penal.

i. Es consensual.

La ley no ha sometido su establecimiento a ninguna formalidad. Aún más, la voluntad de las partes puede manifestarse en forma expresa o en forma tácita. De manera que existe cláusula penal no sólo cuando se la instituye literalmente sino también en todos aquellos casos en que se consigna el pago de una pena, de una multa, de una suma de dinero a título de indemnización, o de cualquiera otra cosa que se trate de dar, hacer o no hacer para el caso de no cumplirse o retardarse el pago de la obligación principal. Sin embargo, habrá casos en que indirectamente la cláusula penal debe sujetarse a solemnidades, por ejemplo, cuando la pena consiste en la entrega de un bien raíz, debe constar por escritura pública, aplicando el artículo 37 del Reglamento del CBR.

ii. Es condicional.

Porque el derecho del acreedor a cobrar la cláusula penal está sujeto al hecho futuro e incierto que se produzca el incumplimiento del deudor, y que éste se encuentre en mora conforme al artículo 1537 del CC.

iii. Es accesoria.

Esta característica proviene del hecho de ser una caución y de ello surgen varias importantes consecuencias. Primero, extinguida la obligación principal por cualquier medio se extingue la cláusula penal. Segundo, la acción para exigir el pago de la pena prescribe conjuntamente con la obligación principal de acuerdo al artículo 2516 del CC. Tercero, la nulidad de la obligación principal trae consigo la nulidad de la pena de acuerdo al inciso primero del artículo 1536 y al artículo 1701 del CC.

En relación con esta característica es necesario estudiar dos situaciones vinculadas directamente con la nulidad de la obligación principal. Primero, en el caso de la cláusula penal en la promesa de hecho ajeno, el artículo 1536 del CC, después de dejar consignado en su primer inciso que la nulidad de la obligación principal acarrea la de la cláusula penal, establece en el inciso siguiente: “Con todo, cuando uno promete por una persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena, aunque la obligación principal no tenga efecto por falta del consentimiento de dicha persona”. La verdad es que no es ninguna excepción porque lo que se garantiza es la obligación del promitente de que el tercero acepte la obligación. Segundo, en el caso de la cláusula penal en la estipulación a favor de otro, el inciso final del artículo 1536 del CC señala: “Lo mismo sucederá, valdrá la pena, cuando uno estipula con otro a favor de un tercero, y la persona con quien se estipula se sujeta a una pena para el caso de no cumplirse lo prometido”. Tampoco constituye una excepción a la regla general pues en este caso la cláusula penal presenta evidente utilidad.

iv. Puede garantizar una obligación civil o natural.

El artículo 1472 del CC dispone: “Las fianzas, hipotecas, prendas y cláusulas penales constituidas por terceros para seguridad de las obligaciones naturales valdrán”.

4.4 Extinción de la cláusula penal.

La cláusula penal puede extinguirse por vía principal y por vía accesoria. Por **vía principal** cuando se extingue no obstante mantenerse vigente la obligación principal, por ejemplo, cuando la cláusula penal es nula y la obligación principal es válida. Por **vía accesoria** cuando desaparece como consecuencia de haberse extinguido la obligación principal, en razón de su carácter accesorio.

4.5 Efectos de la cláusula penal.

El efecto propio de la cláusula penal es dar al acreedor el derecho de cobrarla cuando no se cumple la obligación principal.

4.6 Requisitos para que el acreedor pueda cobrar la pena.



Observación

Para que el acreedor pueda cobrar la pena deben cumplirse las condiciones ya estudiadas para la indemnización de perjuicios, con la salvedad que no es necesario probar la existencia de los perjuicios. Luego se requiere de:

- a) Incumplimiento de la obligación principal.
- b) Que este incumplimiento sea imputable al deudor.
- c) Mora del deudor.
- d) Cuando se pide en un contrato bilateral, es accesoria a la petición de cumplimiento o de resolución por tratarse de una forma de indemnización de perjuicios.

4.7 La pena y el caso fortuito.

Algunos dicen que se debe la pena aun cuando el incumplimiento se deba a caso fortuito, conforme al artículo 1542 del CC que dispone: “Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado”. Esta posición es equivocada porque si hay un caso fortuito la obligación principal se extingue por el modo pérdida de la cosa debida o imposibilidad de ejecución, según sea la naturaleza de la obligación, y, extinguida la obligación principal, se extingue, por vía consecuencial, la cláusula penal por su carácter accesorio.

4.8 La pena y la interpelación voluntaria.

Para que se pueda hacer efectiva la **pena el deudor tiene que estar constituido en mora**, conforme a lo señalado en el artículo 1538 del CC. Algunos han estimado, a partir del artículo 1558 del CC, que no procedería la interpelación voluntaria expresa del primer número del artículo 1551 del CC, sin embargo, la doctrina no participa de esta idea, entendiendo que el deudor puede quedar constituido en mora por cualquiera de las formas de interpelación contempladas en el artículo 1551 del CC. En otros términos, la constitución del deudor en mora para cumplir la obligación principal, no es suficiente constitución en mora de la cláusula penal.

4.9 Efectos de la cláusula penal cuando el incumplimiento es parcial.

Si el acreedor acepta del deudor un pago parcial, **el deudor tiene derecho a que se rebaje proporcionalmente la pena estipulada por la falta de cumplimiento de la obligación**, conforme a lo señalado en el artículo 1539 del CC.

4.10 Cobro de la obligación principal, de la indemnización ordinaria y de la pena.

El CC establece en los artículos 1537 y 1543 algunas reglas sobre lo que puede cobrar el acreedor cuando se incumple una obligación caucionada con cláusula penal. Estas reglas son las siguientes:

- i. Antes de constituirse en mora el deudor, el acreedor sólo puede demandar la obligación principal. Si así no fuera, las obligaciones pasarían a ser siempre alternativas, porque podría solicitarse una u otra cosa y la obligación alternativa es, como se ha señalado precedentemente, una excepción en nuestro derecho.
- ii. Constituido el deudor en mora, la ley da al acreedor la opción para pedir el cumplimiento de la obligación principal o la pena, pero no las dos cosas a la vez.
- iii. No rige la regla anterior, o sea, se pueden acumular el cumplimiento y la pena, cuando aparezca haberse convenido la pena por el simple retardo o cuando se hubiere estipulado que por el pago de la pena no se entiende extinguida la obligación principal.
- iv. Podría también, en conformidad con el artículo 1543 del CC, optarse por la pena o la indemnización ordinaria de perjuicios en conformidad a las reglas generales, pero no demandarse ambas, a menos que se hubiera convenido expresamente.

4.11 Cobro de la cláusula penal cuando la obligación principal es de cosa divisible y hay pluralidad de acreedores o de deudores.

El artículo 1540 del CC establece que cuando la obligación principal es de cosa divisible, la pena debe dividirse también entre los herederos del deudor, pero sólo respecto de los que contravinieron la obligación, a prorrata de sus cuotas hereditarias.

4.12 Cobro de la cláusula penal cuando la obligación principal es de cosa indivisible o cuando se ha puesto la cláusula penal con la intención expresa de que el pago no pueda fraccionarse.

En estos casos puede el acreedor cobrar al culpable el total de la pena o, cada uno de los deudores, incluidos los inocentes, su cuota en la pena, quedando a salvo el recurso de éstos contra el infractor, conforme a los incisos segundo y tercero del artículo 1540 del CC.

4.13 Situación en el caso que la pena sea indivisible.

Se podrá reclamar a cualquiera de los deudores, sin importar quién sea el infractor. Ello porque estamos frente a una obligación indivisible, y ser ese precisamente el efecto de la indivisibilidad.

4.14 Situación en el caso que la obligación principal sea solidaria.

La ley no da solución al problema. Cabe entender que la pena también se puede cobrar solidariamente por el carácter accesorio que tiene. Se estima que la solución es discutible porque la indemnización de perjuicios es conjunta aún entre los deudores solidarios y la solidaridad requiere de texto expreso.

4.15 Cláusula penal garantizada con hipoteca.

El artículo 1541 del CC dispone: **“Si a la pena estuviere afecto hipotecariamente un inmueble, podrá perseguirse toda la pena en él, salvo el recurso de indemnización contra quien hubiere lugar”**. Esta solución es consecuencia del carácter indivisible de la hipoteca.

4.16 Cobro de la cláusula penal cuando hay pluralidad de acreedores.

La situación no está resuelta en la ley. De acuerdo a las reglas generales cada acreedor sólo podrá demandar su cuota en la pena, salvo que la pena fuere de cosa indivisible o hubiere solidaridad activa.

4.17 Cláusula penal enorme.

Esta materia está regulada en el artículo 1544 del CC, que distingue varias situaciones:

a) Cláusula penal en los contratos conmutativos.

Cuando la cláusula penal garantice el cumplimiento de la obligación de pagar cantidades determinadas como equivalentes a lo que debe pagar la otra parte, y la pena consiste asimismo en el pago de cantidades determinadas se aplica la regla del artículo 1544 del CC que señala que podrá pedirse que se rebaje de la segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él. La última frase ha traído muchas complicaciones interpretativas. La mayoría de la doctrina estima que el alcance es que la pena no puede exceder el doble de la obligación principal. Otros concluyen que la pena no puede ser tres veces mayor que la obligación principal. La doctrina nacional está por la primera tesis.

b) Cláusula penal en el mutuo.

El inciso tercero del artículo 1544 del CC dispone que en el caso del mutuo se podrá rebajar la pena en lo que exceda al máximo del interés que es permitido estipular, o sea, la sanción es que los intereses se rebajan al interés corriente.

c) Cláusula penal enorme en las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado.

El inciso final del artículo 1544 del CC dispone que el juez la moderará prudencialmente, cuando atendidas las circunstancias parecieren enormes.

Unidad 7: Derechos Auxiliares del Acreedor.

Tema 1: Concepto.

Como en virtud del derecho de prenda general del artículo 2465 del CC es el patrimonio del deudor el que está respondiendo del cumplimiento de sus obligaciones, la ley otorga al acreedor ciertas acciones o medios destinados a mantener la integridad de ese patrimonio. Estas acciones o medios son denominados **derechos auxiliares del acreedor**.

Tema 2: Enumeración.

No hay uniformidad sobre cuáles serían esos derechos, pero hay un cierto consenso en atribuirle este carácter a los siguientes:

1. Las medidas conservativas, destinadas a evitar que determinados bienes salgan del patrimonio del deudor.
2. El derecho legal de retención.
3. La acción oblicua, indirecta o subrogatoria, destinada a obtener que ingresen ciertos bienes al patrimonio del deudor que éste negligentemente pretende dejar fuera.
4. La acción pauliana o revocatoria, cuyo objeto es reintegrar al patrimonio del deudor ciertos bienes que han salido de él en perjuicio de sus acreedores.
5. El beneficio de separación, destinado a impedir que los bienes del causante se confundan con los del heredero, en perjuicio de los acreedores testamentarios o hereditarios.

Tema 3: Acción Pauliana.

3.1 Concepto.

Está tratada en el artículo 2468 del CC. Se la define como la que la ley otorga a los acreedores para dejar sin efecto los actos del deudor ejecutados fraudulentamente y en perjuicio de sus derechos y siempre que concurren los demás requisitos legales.

3.2 Requisitos de la acción pauliana.

a) En relación con el acto.

La acción pauliana puede intentarse para dejar sin efecto cualquier acto o contrato voluntario del deudor, no los forzados pues en tal caso no se divisa el fraude. Pueden ser actos o contratos de distinto tipo: unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, actos de renuncia, etc. No obstante que la acción pauliana procede tanto respecto de los actos gratuitos como de los onerosos, los efectos

que se siguen en uno y otro caso son diferentes. Así si el contrato que produce la insolvencia del deudor es oneroso, para revocarlo es necesario probar la mala fe del deudor y la mala fe del adquirente, esto es, acreditar que ambos conocían el mal estado de los negocios del deudor. En cambio, si el contrato es gratuito, basta que el acreedor pruebe la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores.

b) En relación con el deudor.

No es necesario para la procedencia de la acción pauliana que el deudor esté en quiebra como podría desprenderse de la redacción del artículo 2468 del CC. Es lógico que así sea pues de exigirse la declaratoria de quiebra quedarían sin poder ser atacados por esta vía, por falta de declaratoria de quiebra, muchos actos fraudulentos y claramente lesivos para los acreedores. Si se produce la declaratoria de quiebra esta materia queda regida por los artículos 74 y 75 de la LDQ. En definitiva, respecto del deudor lo que el artículo 2468 del CC exige es que esté de mala fe. Es una mala fe específica, denominada mala fe pauliana, que consiste en que realice el acto conociendo el mal estado de sus negocios.

c) En relación con el acreedor.

El acreedor que entabla la acción debe tener interés y sólo va a tenerlo cuando se reúnan los siguientes requisitos: primero, que el deudor sea insolvente o que con el acto haga aumentar su insolvencia; y, segundo, que su crédito sea anterior al acto que produce la insolvencia. Se entiende que existe este perjuicio cuando a consecuencia del acto el deudor queda en insolvencia o se aumenta la ya producida.

d) En relación con el tercero adquirente.

Si el acto es gratuito no se requiere ningún requisito especial en el tercero adquirente, basta la mala fe del deudor y el perjuicio, conforme al segundo número del artículo 2468 del CC. Si el acto es oneroso, el tercero adquirente debe estar de mala fe, es decir, haber celebrado el acto sabiendo del mal estado de los negocios del deudor, conforme al primer número del artículo 2468 del CC.

Situación del subadquirente.

Claro Solar estima que se le deben aplicar las mismas reglas que a los adquirentes. Alessandri, partiendo de la base que la acción pauliana es una acción de nulidad relativa pues el artículo 2468 del CC emplea las expresiones rescindan y rescindibles, estima que basta con probar la mala fe del deudor y del tercero adquirente, no siendo necesario probar la mala fe del tercero subadquirente. Ello porque la nulidad judicialmente declarada produce efectos respecto de terceros independientemente de su buena o mal fe.

Somarriva, por su parte, hace algunas distinciones:

- i. Si no hay mala fe ni en el deudor ni en el adquirente no cabe la revocación aunque el subadquirente esté de mala fe.
- ii. Si los tres están de mala fe cabe la revocación.
- iii. Si deudor y el adquirente son fraudulentos y el subadquirente está de buena fe, no resulta lógico exigir a éste más requisitos que al adquirente, por lo que debe distinguirse respecto de éste entre los contratos gratuitos, que se revocan, y los onerosos, que sólo se revocan si están de mala fe.

3.3 Características de la acción pauliana.

- i. Es una acción directa del acreedor, que ejerce a su propio nombre y no por cuenta del deudor.
- ii. Es una acción personal porque deriva de un hecho ilícito. Luego, se debe demandar al deudor y al tercero.
- iii. Es una acción patrimonial y por lo tanto: renunciable, transmisible, transferible y prescriptible, siendo el plazo de prescripción de un año contado desde la fecha del acto o contrato.

3.4 Efectos de la acción pauliana.

El efecto propio de la acción pauliana es dejar sin efecto el acto o contrato impugnado, hasta el monto del crédito del acreedor que intenta la acción. Consecuencia de ello es que el deudor puede enervar la acción pagando al acreedor. Por aplicación del artículo 3 del CC, la revocación sólo afecta a las partes que litigaron.

3.5 Naturaleza jurídica de la acción pauliana.

Alessandri, tomando la expresión rescindible del artículo 2468 del CC entiende que es una acción de nulidad relativa, conclusión que tiene importancia para los efectos de saber si a los terceros subadquirentes se les va o no exigir mala fe. Otros estiman, que aunque el artículo 2468 del CC emplee dicho término, la acción pauliana no es una acción de nulidad, pues el acto que se pretende dejar sin efecto es un acto válido, pues en su formación no hubo vicios y para existir nulidad relativa debe existir un vicio originario. Somarriva piensa que se está frente a una típica acción de inoponibilidad por fraude, lo que implica que al acreedor no le afecta el acto y por ello puede pedir su revocación. El hecho de que el acto se revoque hasta el monto del crédito del acreedor es un buen argumento a favor de esta posición. Para otros se trata de una acción indemnizatoria por un hecho ilícito, y la reparación adoptaría una forma especial que es, precisamente, dejar sin efecto el acto ilícito.

Tema 4: Beneficio de Separación de Patrimonios.

Tiene por objeto evitar que se confundan los bienes del causante con los del heredero, para que, de esa forma, puedan pagarse en los primeros, los acreedores hereditarios y testamentarios, con preferencia a los acreedores propios del heredero.

Unidad 8: De Los Modos de Extinguir las Obligaciones.

Tema 1: Concepto.



Observación

El derecho personal o crédito y la obligación correlativa son de duración temporal, pues cumplido su objetivo, desaparecen. Pero el cumplimiento de la obligación no es la única forma como ésta se extingue. Sólo es la forma normal de extinción, pero además esta extinción puede ser la consecuencia de haber sobrevenido un hecho o un acto al que la ley le atribuye el valor de hacer cesar los efectos de la obligación. Por ello podemos

decir que los modos de extinguir las obligaciones son todos los hechos o actos a los cuales la ley les atribuye el valor de hacer cesar los efectos de la obligación.

Tema 2: Causales de extinción de las obligaciones.

El artículo 1567 del CC hace una enumeración de los modos de extinguir, que contiene diez numerandos. En relación con ella, queremos formular las siguientes observaciones:

1. Si bien tiene diez numerandos contiene once modos de extinguir, por cuanto su primer inciso establece uno más: la resciliación o mutuo disenso.
2. No es una enumeración taxativa pues hay otros modos de extinguir que no contempla como, por ejemplo, el término extintivo que el mismo legislador considera al tratar de la extinción de algunos contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento o la sociedad; tampoco contiene la dación en pago; tampoco la imposibilidad absoluta de cumplir una obligación de hacer; la voluntad de las partes como ocurre en el desahucio en el arrendamiento y con la revocación y renuncia en el mandato; la muerte del deudor en las obligaciones intransmisibles y en los contratos intuitu personae; etc.

Tema 3: De la Resciliación o Mutuo Disenso.

3.1 Concepto.

Está establecido en el primer inciso del artículo 1567 del CC que dispone: “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula”. Luego la resciliación es un acuerdo de voluntades, una convención. La resciliación sólo tiene cabida tratándose de obligaciones contractuales, es decir, emanadas de un acuerdo de voluntades pues, precisamente, se funda este modo en que

habiéndose generado la obligación por un acuerdo de voluntades, por un nuevo acuerdo pueden las partes dejarla sin efecto.

3.2 La resciliación es una convención, no es un contrato.

Porque es un acto jurídico bilateral destinado a extinguir una obligación. No es un contrato porque no genera obligaciones.

3.3 Requisitos de validez.

Constituyendo una convención, sus requisitos son los propios de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad de las partes, objeto y causa.

3.3.1 Consentimiento en la resciliación.

Las partes tienen que consentir, convenir, en dejar sin efecto en todo o en parte un acto jurídico anterior. Las partes son, por cierto, las mismas que celebraron el acto jurídico que por medio de la resciliación dejan sin efecto. Un fallo sentó la doctrina que la resciliación debe hacerse y por ende perfeccionarse con la misma solemnidad que las partes adoptaron al convenir el contrato, porque en derecho las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen. No estamos de acuerdo con la conclusión del fallo. Las solemnidades son de derecho estricto y la ley no ha establecido ninguna para la resciliación, de tal suerte que no parece adecuado exigir las.

3.3.2 Capacidad para resciliar.

El artículo 1567 del CC exige capacidad de disposición. Luego, no basta la simple capacidad para contratar de los artículos 1445, 1446 y 1447 del CC sino que se requiere una mayor, para disponer libremente de lo suyo. La explicación de por qué se exige esta capacidad debe encontrarse en que constituye para ambas partes una renuncia de los derechos provenientes del acto o contrato que se deja sin efecto, y justamente es esa una de las razones por las cuales no se pueden resciliar las obligaciones legales, porque respecto de ellas no cabe la renuncia.

3.3.3 Para que haya resciliación tiene que existir una obligación pendiente.

Este requisito no aparece en el artículo 1567 del CC pero todos los autores lo exigen pues no hay que olvidar que la resciliación es un modo de extinguir obligaciones, por lo que si no hay obligaciones que extinguir la resciliación no tendría objeto. Cabe preguntarse si las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad podrían dejar sin efecto un contrato que ya estuviera cumplido. Ciertamente que incluso después de consumado, cabe mediante un nuevo contrato inverso restablecer el estado de cosas anterior al primero. Pero tal cosa no es desligarse de este primer contrato por mutuo disenso sino simplemente celebrar un segundo contrato contrario.

3.4 La resciliación sólo opera en los contratos patrimoniales.

No cabe en el derecho de familia por cuanto no procede allí la renuncia de derechos, razón por la cual no puede resciliarse un matrimonio por ejemplo.

3.5 Efectos de la resciliación.



El artículo 1567 del CC al dar el concepto de resciliación dice que con ella las partes consienten en dar por nula una obligación, lo que es un error pues para la nulidad debe existir un vicio originario, es decir, existente al momento en que se formó el consentimiento. En definitiva, no es cierto que con la resciliación las partes puedan dar por nula una obligación. Lo que el artículo 1567 del CC ha querido decir es que con la resciliación las partes acuerdan dejar sin efecto el acto, lo que es diferente. Corrientemente se dice que la resciliación no opera retroactivamente sino hacia el futuro, y ello con el objeto de proteger a los terceros que pudieran haber celebrado algún contrato sobre la cosa objeto del contrato resciliado. Sin embargo, se argumenta que esto no es tan cierto, pues entre las partes la resciliación tendrá los efectos que las partes hayan querido darle, para el futuro o retroactivamente, aunque dicho acuerdo no pueda afectar a terceros.

3.5.1 Efectos de la resciliación entre las partes.

La resciliación produce los efectos que las partes quieran atribuirle, rigiendo en plenitud el principio de la autonomía de la voluntad, pudiendo atribuirle efecto retroactivo si lo desean.

3.5.2 Efectos de la resciliación respecto de terceros.

Respecto de los que derivan sus derechos a la cosa objeto del contrato antes de la resciliación, la resciliación no les va a afectar, es, a su respecto, inoponible.

Respecto de los que han adquirido algún derecho sobre la cosa después de la resciliación, deben respetar la resciliación, afectándoles como a todos los demás los actos jurídicos celebrados por su antecesor o antecesores.

Tema 4: De la Solución o Pago Efectivo.

4.1 Generalidades.

Previamente, debe señalarse que el CC reglamenta diversas modalidades del pago:

1. Solución o pago efectivo.
2. Pago por consignación.
3. Pago con subrogación.
4. Pago por cesión de bienes o por acción ejecutiva del acreedor o acreedores.
5. Pago con beneficio de competencia.

4.2 Concepto.

Es el más importante modo de extinguir las obligaciones. El artículo 1568 del CC lo define como **“La prestación de lo que se debe”**. De esta definición surge de inmediato una importante consecuencia: el pago es un modo de extinguir cualquier tipo de obligación, no sólo, como podría pensarse, aquellas de pagar una suma de dinero. Otra consecuencia que deriva de la definición es que todo pago supone una obligación preexistente, civil o a lo menos natural. Tanto es así que si por error se paga una obligación inexistente, quien paga tiene derecho a repetir conforme al primer inciso del artículo 2295 del CC. El artículo 2297 del CC agrega: “Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural”. El pago, se ha dicho, más que un modo de extinguir una obligación, es la forma natural de cumplirla.

No hay pago si por acuerdo de las partes, la obligación se satisface con una cosa distinta de lo debido. En tal caso estamos frente a una dación en pago, como más adelante se verá.

4.3 Naturaleza jurídica del pago.

El pago es una convención, esto es, un acto jurídico bilateral que extingue obligaciones, celebrado entre el solvens que paga y el accipiens, que recibe el pago. No es un contrato porque no genera obligaciones. Como acto jurídico que es, debe cumplir los requisitos generales de todo acto jurídico: consentimiento, capacidad, objeto y causa. Algunos discuten que sea una convención, porque si el deudor se resiste a recibir el pago, se le puede pagar aun en contra de su voluntad, mediante el pago por consignación. Esto se explica porque el deudor tiene el derecho a liberarse de la obligación, tiene el derecho a pagar, y el acreedor no puede impedirle que lo ejerza. Por ello se estima que es discutible que sea un acto jurídico.

El pago es un acto jurídico intuitu personae. Consecuencia de ello es que si por error se hace a una persona distinta del acreedor, no extingue la obligación. Esto es sin perjuicio que pueda repetirse lo pagado en conformidad al artículo 2295 del CC.

4.4 Características del pago.

El pago presenta algunas características especiales:

Debe ser específico. Ello significa que debe hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación sin que pueda ser obligado el acreedor a recibir otra cosa que lo que se le deban aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la cosa ofrecida, conforme al artículo 1569 del CC.

Debe ser completo. Debe comprender íntegramente lo debido, incluidos los accesorios. Ello significa que el pago de una deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban, conforme al segundo inciso del artículo 1591 del CC. Por la misma razón, salvo excepciones, como ocurre en el pago por consignación y en los gastos de transporte para la restitución del depósito, los gastos del pago son de cargo del deudor, conforme al artículo 1571 del CC.

El pago es indivisible. Lo que significa que el deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le deba, salvo el caso de convención contraria, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes en casos especiales, de acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 1591 del CC. Por excepción, **se puede dividir el pago en los siguientes casos:**

1. Si así lo acuerdan las partes; en este caso, se entenderá dividido el pago en partes iguales, a menos que en el contrato se haya determinado la parte o cuota que haya de pagarse a cada plazo, conforme al artículo 1593 del CC.
2. En las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, en que cada deudor sólo está obligado a pagar su cuota, conforme a los artículos 1511 y 1526 del CC.
3. En las deudas hereditarias se divide el pago entre los herederos a prorrata de sus cuotas hereditarias, conforme al artículo 1354 del CC.
4. Cuando existen varios fiadores, la deuda se entiende dividida entre ellos por partes iguales, lo que se denomina beneficio de división conforme al artículo 2367 del CC.
5. Cuando existe controversia sobre la cantidad de la deuda o sobre sus accesorios, podrá el juez ordenar, mientras se decide la cuestión, el pago de la cantidad no disputada, conforme al artículo 1592 del CC.
6. Cuando las partes son recíprocamente deudores y acreedores, puede operar el modo de extinguir compensación, en cuya virtud se extinguen las deudas hasta la de menor valor, lo que viene a importar una especie de pago parcial.
7. En los casos en que el deudor esté constituido en quiebra y sus bienes no alcancen para cubrir la totalidad del pasivo, el síndico hará pagos parciales a los distintos acreedores a prorrata de sus créditos, salvo que exista alguna causal legal de preferencia.

4.5 Por quién debe hacerse el pago.

Esta materia está tratada en los artículos 1572 a 1575 del CC. Pueden hacer el pago:

1. El deudor.
2. Un tercero interesado en extinguir la obligación.
3. Un tercero extraño a la obligación.

4.5.1 Pago hecho por el deudor.

El deudor es el principal interesado en pagar, porque es la forma de quedar desligado de la obligación. Ya hemos dicho que tiene el derecho a pagar. Cuando decimos que el pago lo hace el deudor, debemos aclarar que dentro de este caso comprendemos también lo siguiente:

- i. Pago hecho por el representante legal del deudor.
- ii. Pago hecho por un mandatario del deudor.
- iii. Pago hecho por un heredero del deudor.

En el caso en que el testador haya gravado a un legatario con el pago de una obligación, deberá comprenderse también el pago que en éste caso haga ese legatario. En todos estos casos, si el deudor paga se extingue definitivamente la obligación, sin que se genere ninguna consecuencia posterior.

4.5.2 Pago hecho por un tercero interesado.

Hay personas que no siendo los deudores tienen un directo interés en el pago de la deuda. Estos son:

- i. El codeudor solidario.
- ii. El fiador.
- iii. El tercer poseedor de la finca hipotecada.

Respecto del pago hecho por el codeudor solidario, éste tiene interés en que se extinga la obligación. Si paga se extingue la obligación respecto de él, pero por el hecho de pagar se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, pasando a ocupar su lugar frente a los otros codeudores solidarios, para cobrarles a cada uno su cuota. Si el codeudor solidario que paga no tenía interés en la obligación se le considera fiador y en tal caso se subroga en los derechos del acreedor, pudiendo dirigirse por el total en contra de cualquiera de los otros codeudores solidarios interesados en la obligación, conforme a los artículos 1552, 1610 y 2372 del CC.

Respecto del pago hecho por el fiador, también se subroga en los derechos del acreedor a quien paga conforme al tercer número del artículo 1610 del CC.

Respecto del pago efectuado por el tercer poseedor de la finca hipotecada, o sea, el poseedor del inmueble hipotecado que no está obligado personalmente al pago de la deuda, ello se da en dos casos: primero, cuando se hipoteca un bien propio para garantizar una obligación ajena; y, cuando se adquiere un inmueble hipotecado. En estos casos el tercer poseedor de la finca hipotecada tiene interés en pagar la obligación garantizada con la hipoteca, con el objeto de evitar la subasta de la finca hipotecada. Si paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, pudiendo dirigirse en contra del deudor, conforme al segundo número del artículo 1610 y al segundo inciso del artículo 2429 del CC.

Como se puede apreciar, en todos estos casos el pago no produce la extinción de la obligación, pues ésta subsiste entre el que hizo el pago, que pasa a ocupar el lugar del acreedor, y el deudor. El que desaparece del cuadro es el acreedor, pues su lugar pasa a ser ocupado por quien hizo el pago, lo subroga.

4.5.3 Pago hecho por un tercero extraño.

El artículo 1572 del CC dispone: “Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad y aun a pesar del acreedor”. La ley autoriza que un tercero no interesado pueda pagar por varias razones:

- i. Porque desde el punto de vista del acreedor lo que le interesa es que le paguen, no le importa que lo haga el deudor o un tercero.
- ii. Porque a la sociedad misma le interesa que las deudas se paguen, que exista el menor número de personas obligadas.

Se ha resuelto que el pago que hace un tercero por el deudor, aun a pesar del deudor, no está sujeto a formalidades especiales y puede hacerse en las mismas condiciones que lo haría el deudor. En principio, para nuestro CC, el contenido de la obligación es objetivo. Lo que importa es la prestación en sí. No interesa que sea realizada por un acto del deudor, porque el concepto subjetivo ha desaparecido. Ya no se pide que la prestación sea una actividad de carácter personal del deudor. Por eso puede pagar por el deudor un tercero, con tal que lo haga a nombre del deudor, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor, como lo dice el artículo 1572 del CC. Lo que importa, es que el acreedor obtenga la satisfacción de su derecho. Si pretende, no obstante, una actividad personal del deudor, el tercero puede recurrir al pago por consignación.

Excepcionalmente, si la obligación es de hacer, y si para la obra de que se trata se ha tomado en consideración la aptitud física o talento del deudor, no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor.

4.5.3.1 Efectos del pago hecho por un tercero extraño.

El tercero que paga puede encontrarse en tres situaciones, y los efectos de cada uno de dichos pagos son diferentes:

4.5.3.2 Pago hecho con el consentimiento expreso o tácito del deudor.

El que paga en este caso se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, conforme al quinto número del artículo 1610 del CC. En el fondo, esta persona viene a ser un verdadero mandatario del deudor, y por la misma razón va a tener dos acciones para poder resarcirse de lo que pagó: primero, la acción subrogatoria; y, segundo, la acción propia del mandato. La primera puede ser más efectiva si la deuda estaba caucionada, porque se subroga con todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas de acuerdo al artículo 1612 del CC. La segunda puede serle más conveniente pues le permite cobrar lo pagado más intereses corrientes conforme al cuarto número del artículo 2158 del CC.

4.5.3.3 Pago hecho sin el conocimiento del deudor.

El artículo 1573 del CC dispone: “El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y en los derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subrogue”. No hay, entonces, en este caso subrogación legal. Sólo podría haber subrogación convencional, si el acreedor a quien pagó, le subroga voluntariamente en sus derechos conforme al artículo 1611 del CC. Salva la posibilidad de esta subrogación convencional, el tercero que paga sólo va a tener acción de reembolso en contra del deudor, acción propia de la gestión de negocios ajenos, acción que no tiene ninguna de las ventajas y prerrogativas del crédito antiguo.

4.5.3.4 Pago hecho contra la voluntad del deudor.

El artículo 1574 del CC dispone: “El que paga contra la voluntad del deudor no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado, a no ser que el acreedor le ceda voluntariamente su acción”. Esta persona que paga por otra, sin poder, es un verdadero agente oficioso, y ello es importante porque el CC al tratar la agencia oficiosa establece una cosa distinta al artículo citado, al dispone en el artículo 2291 lo siguiente: “El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado, no tiene demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil y existiere la utilidad al momento de la demanda. La contradicción entre las dos normas es evidente pues de acuerdo al artículo 1574 del CC no hay acción de repetición y según el artículo 2291 del CC si el pago fue útil al deudor, es decir, si extinguió la obligación, hay acción de repetición. Se han dado distintas opiniones para compatibilizar ambas disposiciones:

i. Leopoldo Urrutia estima que el artículo 1574 del CC debe aplicarse cuando el pago no ha sido útil al deudor y el artículo 2291 del CC cuando le fue útil. La solución dada es justa pero presenta el inconveniente que hace una distinción que el artículo 1574 del CC no contempla.

ii. Claro Solar estima que se aplica el artículo 2291 del CC cuando hay utilidad para el deudor, caso en que el que paga puede repetir pero sólo hasta el monto de la utilidad; el artículo 1574 del CC se aplica si el pago no fue útil al deudor. Parece la tesis más razonable.

4.6 Pago en el caso de las obligaciones de dar.

Las obligaciones de dar son aquellas en que el deudor se obliga a transferir el dominio o a constituir un derecho real a favor del acreedor. De manera que la obligación del deudor es hacer la correspondiente tradición. En estas obligaciones de pago tiene algunas reglas especiales:

El tradente debe ser dueño del derecho que transfiere.	Así lo establece el artículo 1575 del CC que dispone: “El pago en que se debe transferir la propiedad no es válido, sino en cuanto el que paga es dueño de la cosa pagada, o la paga con el consentimiento del dueño”. Cuando esta norma dice que el pago no es válido no está significando que es nulo, sino que es ineficaz para extinguir la obligación. Ello porque la disposición hay que concordarla con el artículo 682 del CC que dispone: “Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada”. Hay una excepción contemplada en el inciso final del artículo 1575 del CC que señala: “Sin embargo, cuando la cosa pagada es fungible, y el acreedor la ha consumido de buena fe, se valida el pago, aunque haya sido hecho por el que no era dueño o no tuvo facultad de enajenar”.
Se requiere capacidad de disposición en el que paga.	La exige el segundo inciso del artículo 1575 del CC que dispone: “Tampoco es válido el pago en que se debe transferir la propiedad, sino en cuanto el que paga tiene la facultad de enajenar”. El pago efectuado por el que no tiene capacidad de enajenar adolece de nulidad relativa, pues se ha omitido un requisito exigido por la ley en consideración al estado o calidad de las personas que lo ejecutan, conforme al artículo 1682 del CC. Si el que hizo el pago es un incapaz absoluto, la nulidad será absoluta.
El pago debe hacerse con las formalidades legales.	El artículo 679 del CC dispone: “Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas”. Así ocurre si lo que se debe pagar es un derecho inmueble que exige inscripción en el Registro del CBR.

4.7 A quién debe hacerse el pago.

Esta materia está regulada en los artículos 1576 a 1586 del CC. Es muy importante pagar a quien corresponde porque si se paga mal el deudor no queda liberado de la obligación. El artículo 1576 del CC indica a quien debe hacerse el pago:

- i. Al acreedor mismo, lo que constituye la situación normal.
- ii. A sus representantes.
- iii. Al actual poseedor del crédito.

4.7.1 Pago hecho al acreedor.

El artículo 1576 del CC señala que para que el pago sea válido debe hacerse o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular. Luego, vale el pago que se hace al acreedor, al heredero del acreedor, al legatario del crédito o al cesionario del crédito.

➡ Excepciones en que el acreedor no puede recibir el pago.

El artículo 1578 del CC dispone que el pago hecho al acreedor sea nulo en los casos siguientes:

a) Si el acreedor no tiene la administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor y cuando este provecho se justifique con arreglo al artículo 1688 del CC.

Ello se explica porque el pago es un acto jurídico bilateral, que requiere que ambas partes sean capaces. La sanción, si se paga a un incapaz, va a ser la nulidad relativa, a menos que se haya pagado a un absolutamente incapaz, en que será la nulidad absoluta. Como es nulidad relativa, puede sanearse conforme a las reglas generales. Sin embargo, el pago va a ser válido si quien lo hizo prueba que fue útil al acreedor conforme al artículo 1688 del CC, o sea, probando que el acreedor se hizo más rico, entendiéndose que es así cuando las cosas pagadas le hubieren sido necesarias o, si no lo fueron, subsistan y se quisiera retenerlas.

b) Si por el juez se ha embargado la deuda o mandado retener su pago.

Embargado el crédito o retenido el pago, si el deudor paga, el pago adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito conforme al artículo 1682 en relación con el tercer número del artículo 1464 del CC. Se ha fallado que para que se produzca este efecto, tanto el embargo como la retención deben notificarse al deudor. DE no ocurrir así el pago sería válido.

c) Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso.

Es consecuencia de que el fallido pierde la administración de sus bienes, la que pasa al síndico, que es quien puede recibir válidamente el pago conforme al artículo 64 del la LDQ.

4.7.2 Pago hecho a los representantes del acreedor.

El pago es válido conforme a los artículos 1576, 1579, 1580 y 1581 del CC. Los representantes pueden ser de tres tipos:

a) Pago hecho al representante legal del acreedor.

El artículo 1579 del CC señala los distintos casos de pagos hechos a los representantes legales del acreedor, pero no es taxativo.

b) Pago hecho al representante judicial del acreedor.

Vale el pago que se hace a la persona designada por el juez para recibirlo. Puede ser el caso en que exista una medida precautoria de secuestro.

c) Pago hecho al representante convencional del acreedor.

Este mandatario puede ser incluso relativamente incapaz. El mandato para recibir el pago puede revestir tres modalidades: primero, mandato general de administración regulado en el artículo 2132 del CC, que confiere la facultad de cobrar los créditos que pertenezcan al giro ordinario; segundo, mandato especial para administrar el negocio o negocios en que incide el pago; y, tercero, mandato especial para cobrar un determinado crédito.

La ley ha establecido algunas precisiones: así, según el artículo 1582 del CC el poder para demandar en juicio no faculta al apoderado para recibir el pago de la deuda pues de acuerdo al artículo 7 del CPC el poder para percibir requiere de mención expresa.

Para que el pago hecho a un mandatario sea eficaz es necesario que el mandatario actúe dentro de la esfera de su mandato, conforme al primer inciso del artículo 2160 del CC, y que aparezca recibiendo en su carácter de tal para el mandante o ello aparezca del tenor o espíritu del acto.

El artículo 1586 del CC dispone: “La persona diputada para recibir el pago se hace inhábil por la demencia o la interdicción, por haber hecho cesión de bienes o haberse trabado ejecución en todos ellos; y, en general, por todas las causas que hacen expirar el mandato establecidas en el artículo 2163 del CC”.

4.7.3 Pago hecho al actual poseedor del crédito.

El segundo inciso del artículo 1576 del CC establece: “El pago hecho de buena fe a la persona que estaba entonces en posesión del crédito es válido, aunque después aparezca que el crédito no le pertenecía”. Los requisitos de la norma son dos: primero, que el que recibe el pago se encuentre en posesión del crédito; y, segundo, que el que paga lo haga de buena fe, entendiéndose que está pagando al dueño del crédito. La buena fe se presume. Este es un caso de aplicación de la teoría de la apariencia o del error común.

4.7.4 Pago hecho a otras personas no es eficaz, no extingue la obligación.

Se ha fallado que no es válido el pago hecho al cedente después de notificada la cesión al deudor. Pero un pago hecho a una persona inhábil se puede validar en los casos establecidos en el artículo 1577 del CC:

- i. Si el acreedor lo ratifica de un modo expreso o tácito, pudiendo legítimamente hacerlo, caso en que se entenderá como válido desde el principio.
- ii. Si el que recibe el pago sucede en el crédito, como heredero, legatario, etc.

4.8 Época en que debe hacerse el pago.

El pago debe hacerse en el lugar y tiempo convenidos conforme al artículo 1872 respecto del pago del precio en el contrato de compraventa. Si nada se ha convenido, si la obligación es pura y simple el pago debe hacerse de inmediato, celebrado que sea el contrato. Si está sujeta a un plazo o condición suspensivos, desde que venza el plazo o se cumpla la condición. En el caso de obligación sujeta a plazo, el deudor puede pagar antes del vencimiento, si el plazo está establecido en su sólo beneficio. En caso contrario no puede hacerlo.

4.9 Lugar donde debe hacerse el pago.

Los artículos 1587 a 1589 del CC tratan esta materia. Este aspecto del pago es importante porque el deudor cumplirá su obligación pagando en el lugar que corresponde, sin que se le pueda exigir que lo haga en otro lugar. Y, recíprocamente, el acreedor no puede ser obligado a recibir el pago en un lugar diferente. Las reglas sobre el lugar en que debe hacerse el pago son las siguientes:

- i. El pago debe hacerse en el lugar designado en la convención.
- ii. Si no se hubiere establecido el lugar en que debe realizarse, es necesario distinguir según el objeto de la obligación sea dar o entregar una especie o cuerpo cierto u otro diferente. En el primer caso, se debe pagar en el lugar en donde dicho cuerpo existía al tiempo de constituirse la obligación, conforme al primer inciso del artículo 1588 del CC. Si lo debido es otra cosa, género, hecho o abstención, el pago debe cumplirse en el domicilio del deudor, conforme al segundo inciso del artículo 1588 del CC.

Se ha discutido a qué domicilio del deudor se refiere esta norma, si al que tenía al momento de celebrar el contrato o al que tiene al momento en que debe hacerse el pago. Atendido lo que dispone el artículo 1589 del CC no nos cabe duda que debe estarse al primero, pues justamente esa disposición se pone en el caso en que entre ambas fechas el deudor hubiere mudado su domicilio, estableciendo que, en ese caso, el pago debe hacerse en el lugar que sin esa mudanza correspondería, salvo que las partes dispongan de común acuerdo otra cosa. Si el deudor tuviere pluralidad de domicilios deberá pagar en el correspondiente al lugar donde contrajo la obligación si éste dice relación con ese domicilio.

4.10 Contenido del pago.

El artículo 1569 del CC dispone: “El pago se hará bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligación, sin perjuicios de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no

podrá ser obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida”. Además recordemos que el pago debe ser total y que no se puede dividir, salvo las excepciones ya mencionadas del artículo 1591 del CC. Precizando lo anterior, para saber cómo se hace el pago deberá estarse a la naturaleza de la obligación de que se trate, y entonces podemos distinguir entre:

- i. **Si lo debido es un género**, se cumplirá entregando cualquier individuo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos mediana, conforme al artículo 1509 del CC.
- ii. **Si lo debido es una cantidad de dinero** se cumplirá entregando la suma numérica establecida, pues hemos visto que el sistema chileno es nominalista.
- iii. **Si es una obligación de hacer o no hacer**, se pagará realizando la prestación o la abstención convenida.
- iv. **Si la obligación es de dar o entregar una especie o cuerpo cierto**, el acreedor debe recibirlo en el estado en que se halle, soportando entonces los deterioros provenientes de fuerza mayor o caso fortuito. Pero si la cosa se hubiere deteriorado por el hecho o culpa del deudor, o de las personas por quienes éste es responsable, o si los deterioros se hubieren producido durante la mora del deudor, a menos que provengan de un caso fortuito a que la cosa hubiere estado igualmente expuesta en poder del acreedor, cabe hacer una distinción según los deterioros sean o no importantes. Si son importantes, puede pedirse o la resolución del contrato más indemnización de perjuicios; o aceptar la cosa en el estado en que se encuentra más indemnización de perjuicios conforme al artículo 1590 del CC. Si el deterioro no es importante, se deberá recibir la cosa en el estado que se encuentre pero se deberán indemnizar los perjuicios conforme lo dispuesto en segundo inciso del artículo 1590 del CC. En el caso en que el deterioro hubiere ocurrido antes de constituirse el deudor en mora, pero no por hecho o culpa suya, sino de otra persona por quien no es responsable, es válido el pago de la cosa en el estado en que se encuentre, pero el acreedor podrá exigir que se le ceda la acción que tenga su deudor contra el tercero, autor del daño, conforme al inciso final del artículo 1590 del CC.

4.11 Caso en que concurran varias obligaciones entre las mismas partes.

El artículo 1594 del CC dispone: “Cuando concurran entre unos mismos acreedor y deudor diferentes deudas, cada una de ellas podrá ser satisfecha separadamente; y por consiguiente el deudor de muchos años de una pensión, renta o canon podrá obligar al acreedor a recibir el pago de un año, aunque no le pague al mismo tiempo los otros”.

4.12 De la imputación del pago.

En el caso en que existan varias deudas entre acreedor y deudor, y el pago hecho no alcance a satisfacerlas todas, debe resolverse cuál es la que se debe entender solucionada. Es el problema

llamado de la imputación del pago. Debe aclararse que esta situación sólo se va a presentar si concurren los siguientes supuestos:

- i. Que existan varias deudas de una misma naturaleza.
- ii. Que estas deudas sean entre las mismas partes.
- iii. Que se haga un pago insuficiente para satisfacerlas a todas.

El CC, en los artículos 1595 a 1597, da diversas reglas sobre la materia, y que son las siguientes:

- i. Si se debe capital e intereses, el pago se imputará primero a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente en que se impute al capital en conformidad al artículo 1595 del CC.
- ii. Si hay diferentes deudas, el deudor puede imputar a la que elija, con las siguientes limitaciones: primero, no puede preferir la deuda no devengada a la que lo está, a menos que el acreedor lo consienta; y, segundo, debe imputar el pago a la deuda que se alcanza a pagar en su integridad, ya que de conformidad al artículo 1591 del CC el acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales.
- iii. Si el deudor no hace imputación, podrá hacerla el acreedor en la carta de pago o recibo, y si el deudor la acepta no le será lícito reclamar después.
- iv. Si ninguna de las partes hace la imputación, ésta la hace la ley, pues el artículo 1597 dispone: “Se preferirá la deuda que al tiempo del pago estaba devengada a la que no lo estaba, y no habiendo diferencia bajo este respecto, la deuda que el deudor eligiere”.

4.13 Prueba del pago.

De acuerdo al artículo 1698 del CC la prueba del pago corresponde al deudor. Podrá valerse de todos los medios de prueba legales para ello, con las limitaciones que para la prueba de testigos establecen los artículos 1708 y 1709 del CC.

4.13.1 Presunciones legales de pago.

Para facilitar la prueba el CC establece diversas presunciones:

- i. Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados, conforme al segundo inciso del artículo 1595 del CC y al artículo 17 de la Ley No. 18.010.
- ii. En los pagos periódicos, la carta de pago de tres periodos determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores periodos siempre que hayan debido efectuarse entre los mismos acreedor y deudor conforme al artículo 1570 del CC.

Estas presunciones son simplemente legales, por lo que se puede probar en contrario.

4.14 Gastos del pago.

El artículo 1571 del CC dispone: “Los gastos que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado, y de lo que el juez ordenare acerca de las costas”. Ya hemos

explicado que esta regla sufre una excepción importante en el caso del pago por consignación del artículo 1604 del CC y en la restitución del depósito del artículo 2232 del CC.

4.15 Efectos del pago.

El efecto propio del pago es extinguir la obligación. Este efecto no se produce en el caso en que el pago lo haga un tercero con el consentimiento expreso o tácito del deudor o un tercero interesado, codeudor solidario, fiador o tercer poseedor de la finca hipoteca, pues entonces la obligación subsiste, con todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas, entre ese tercero que paga y el deudor.

Tema 5: Pago con Subrogación.

5.1 Concepto de subrogación.

La voz subrogación evoca la idea de sustitución o reemplazo de una cosa por otra o de una persona por otra. De esa forma, la subrogación puede ser real o personal. En la real, una cosa toma el lugar de otra, que se le reputa de su misma naturaleza y cualidades. En la subrogación personal una persona toma el lugar de otra, ocupa su sitio, pudiendo por ello ejercitar sus acciones y derechos. En el pago por subrogación el tercero que paga una deuda ajena pasa a ocupar el lugar del acreedor a quien paga. De esta manera se produce la situación particular de que no obstante estar pagada la obligación, ese pago no extingue el derecho de crédito, el que se mantiene con sus derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas, a favor del tercero que paga, que pasa a ser su nuevo titular.



5.2 Definición de subrogación.

El artículo 1608 del CC dispone: **“La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que paga”**. Lo que el legislador ha querido decir con el término transmisión es que el tercero que paga queda, respecto del acreedor a quien paga, colocado en una situación análoga a la que se encuentra el heredero respecto del causante, pasa a ocupar su lugar. En todo caso, para formarse una idea más clara de la institución, pareciera ser mejor definirla como una ficción legal en cuya virtud una obligación que debía considerarse extinguida por el pago hecho por un tercero queda, sin embargo, vigente, en poder de éste, el cual obra como si fuere la misma persona del acreedor. También se la define señalando que es una ficción jurídica, en virtud de la cual cuando un tercero paga voluntariamente con dineros propios una obligación ajena, ésta se extingue entre el acreedor y el deudor, pero subsiste teniendo por nuevo acreedor al que efectuó el pago.

5.3 Paralelo entre la cesión de créditos y el pago con subrogación.

La verdad es que las dos figuras se asemejan, pues en ambas se produce un cambio en el titular del crédito. Sin embargo, hay entre ellas diferencias importantes, siendo la fundamental el que la cesión de derechos importa una especulación y la subrogación un pago. El cesionario pretende hacer un negocio comprando el crédito barato y cobrándolo en su integridad. En la subrogación el tercero que paga sólo cobrará lo que pago. Constituye únicamente una garantía para el que paga, pues subsisten las acciones, derechos, privilegios, prendas e hipotecas del crédito pagado.

En la subrogación, el tercero que paga tiene diferentes acciones para recuperar lo que pagó.

En efecto, va a tener el mismo crédito del acreedor a quien pagó, con sus acciones, garantías y privilegios. Pero también podrá hacer uso de las acciones que deriven de la vinculación que él pueda tener con el deudor. Así, por ejemplo, podría ser fiador y tendrá las acciones de la fianza; si paga con el consentimiento del deudor será su mandatario y tendrá las acciones propias del mandato; el que paga sin la voluntad del deudor será su agente oficioso y tendrá las acciones que como tal le competan.

5.4 Clases de subrogación.

El artículo 1609 del CC distingue entre **subrogación legal y convencional** al disponer: “**Se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor**”.

5.4.1 Subrogación legal. Opera por el sólo ministerio de la ley. El artículo 1610 del CC dispone: “Se efectúa la subrogación por el sólo ministerio de la ley y aun en contra de la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por la ley”. Como opera por el sólo ministerio de la ley es consensual. El artículo 1610 del CC contempla diez casos, pero la norma no es taxativa ya que pueden encontrarse otros casos, como por ejemplo, el del tercer poseedor de la finca hipotecada que paga la hipoteca conforme al artículo 2429 del CC; el del legatario que paga la hipoteca con que la cosa legada estaba gravada conforme al artículo 1366 del CC, etc.

a) Primer caso de subrogación del artículo 1610 del CC: Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca.

La particularidad es que el tercero que paga no es un tercero cualquiera sino uno muy especial, pues es también acreedor del mismo deudor, pero su derecho es de rango inferior al del acreedor pagado, en razón de un privilegio o hipoteca de que goza el crédito de este último. La explicación acerca de la utilidad de esta subrogación es que de esa forma se puede evitar que el acreedor de mejor derecho haga efectivo su crédito, lo que podría perjudicar al tercero que paga, si rematado el bien, no alcanzare para satisfacer ambos créditos.

Para que estemos ante este caso es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

- i. Que el pago lo haga otro acreedor, no un tercero cualquiera.
 - ii. Que el pago se haga a un acreedor de mejor derecho, en virtud de un privilegio o hipoteca.
- En relación con este caso se plantea el problema de determinar si el acreedor que paga el crédito hipotecario debe practicar una nueva inscripción de la hipoteca a su nombre. La respuesta generalmente aceptada es que no se hace de ese modo, pues, si se practicara una nueva inscripción la hipoteca ya no sería la misma sino otra, que al ser más nueva sería de menor grado. Luego, no es necesario practicar una nueva inscripción, bastando a lo sumo con practicar una anotación al margen de la inscripción hipotecaria. En este sentido buena parte de la doctrina.

b) Segundo caso de subrogación del artículo 1610 del CC: Del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está hipotecado.

Opera a favor del comprador de un inmueble hipotecado. No opera si la adquisición ha sido hecha en virtud de otro título distinto al de compra. La utilidad se va a producir respecto del que compra un inmueble gravado con varias hipotecas porque se subroga en los derechos de los acreedores hipotecarios a quienes pague, de manera que si alguno posterior realiza el bien, el comprador se pagará con preferencia y aunque pierda el bien, por lo menos va a recuperar el dinero invertido al pagarse preferentemente con el precio logrado en el remate.

La situación que estamos estudiando pasa a tener mucha importancia en el caso en que se subasta una finca gravada con varias hipotecas, y en que respecto de un acreedor hipotecario no se produce la purga por no haber sido emplazado debidamente. Según la generalidad de la doctrina cabe aplicar el segundo número del artículo 1610 del CC. Para mejor comprensión del tema, demos una explicación breve de lo que significa la purga de la hipoteca. Cuando un predio está gravado con varias hipotecas, y uno de los acreedores hipotecarios, haciendo uso de su derecho real de hipoteca, lo saca a remate, debe notificar personalmente a todos los otros acreedores hipotecarios, con el objeto que dentro del término de emplazamiento hagan valer sus derechos. Pues bien, si cumplidos estos trámites se subasta la finca hipotecada y el resultado del remate no es suficiente para pagar a todos los acreedores hipotecarios, se pagarán los acreedores hipotecarios que alcancen y respecto de los que no alcancen, se entenderá sus hipotecas extinguidas por el modo de extinguir purga de la hipoteca. De esa forma, el que subasta la finca la va a adquirir libre de hipotecas conforme al artículo 2428 del CC. Ahora bien, puede ocurrir que uno de los acreedores hipotecarios no hubiere sido notificado. Producido el remate este tercer acreedor hipotecario mantiene su hipoteca, la subasta le es inoponible, por lo que, haciendo uso de su derecho puede perseguir la finca y sacarla nuevamente a remate. Para estos efectos, la primera y la segunda hipoteca se entienden subsistir y revivir en el comprador que adquirió el bien en la primera subasta, quien pasa a ocupar el lugar de los acreedores hipotecarios pagados en ella. Lo anterior significa que si lo obtenido en el nuevo remate no alcanza sino para pagar las primeras

hipotecas, el tercer acreedor hipotecario no se va a pagar y su hipoteca se va a extinguir por el modo de extinguir purga de la hipoteca.

Hay un caso que no se encuentra establecido en el segundo número del artículo 1610 del CC y es el de la subrogación del tercer poseedor de la finca hipotecada. Primeramente debe establecerse que es tercer poseedor la persona que cumple dos requisitos: primero: no es deudor personal de la deuda garantizada con hipoteca; y, segundo, es el poseedor, normalmente dueño, de la finca hipotecada. Estos requisitos se cumplen respecto del propietario de un inmueble que lo da en hipoteca para garantizar una deuda ajena y del que adquiere una finca que está gravada con hipoteca. Pues bien, si el deudor de la obligación garantizada con hipoteca no paga, el acreedor hipotecario va a perseguir la finca en poder de quien se encuentre, consecuencia de ser la hipoteca un derecho real. En este caso, deberá notificar al tercero poseedor de la finca hipotecada con el objeto de que pague la deuda o abandone la finca. Si paga, se va a subrogar en el derecho del acreedor hipotecario a quien paga, conforme al artículo 2429 del CC.

c) Tercer caso de subrogación del artículo 1610 del CC: Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente.

El codeudor solidario que paga se subroga en los derechos del acreedor a quien paga, para dirigirse en contra de sus codeudores, pero respecto de cada uno sólo por su cuota, conforme al artículo 1522 del CC. En el caso del fiador que paga, pasa a subrogarse en los derechos del acreedor a quien paga, pudiendo dirigirse en contra del deudor principal, con la misma acción que tenía el acreedor a quien pagó, o bien, puede hacer uso de la acción de reembolso que le corresponde como fiador.

d) Cuarto caso de subrogación del artículo 1610 del CC: Del heredero beneficiario que paga con sus propios dineros las deudas de la herencia.

Heredero beneficiario es el que goza de beneficio de inventario, que según el artículo 1247 del CC consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Se trata, entonces, de que este heredero que goza de beneficio de inventario paga más allá de lo que le corresponde; en tal caso, se subroga por este exceso en los derechos del acreedor a quien paga, para cobrarlo a los demás herederos.

e) Quinto caso de subrogación del artículo 1610 del CC: Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor.

Este tercero tiene, además de la acción subrogatoria, la acción propia del mandato, pues al pagar con el consentimiento expreso o tácito del deudor, pasa a ser un mandatario de éste.

f) Sexto caso de subrogación del artículo 1610 del CC: Del que ha prestado dinero al deudor para el pago, constando así en escritura pública del préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el mismo dinero.

Se diferencia de los casos anteriores en que quien se subroga no es el que pagó una deuda ajena, sino quien le prestó dinero al deudor para que pagara la deuda. En doctrina comparada se le llama subrogación consentida por el deudor y se le califica de subrogación convencional pero en Chile es un caso de subrogación legal. Para que opere este caso de subrogación deben concurrir los siguientes requisitos:

- i. Que el tercero preste dinero al deudor para que pague.
- ii. Que el deudor pague la deuda con ese mismo dinero.
- iii. Que el mutuo se otorgue por escritura pública, en que se exprese que se otorga para pagar la deuda.
- iv. Que se deje constancia del pago en una escritura pública donde se manifieste que se hace con dineros que el deudor obtuvo en préstamo.

La ley exige escrituras públicas para evitar colusiones entre el deudor y el que paga. Si la deuda estaba garantizada con hipoteca, al producirse la subrogación esta hipoteca va a quedar garantizando el mutuo, lo que es indudablemente ventajoso para el que presta el dinero. La operación puede llevarse a cabo en una sola escritura pública.

5.4.2 Subrogación convencional.

El artículo 1611 del CC dispone: “Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor cuando éste, recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y acciones que le corresponden como tal acreedor; la subrogación en este caso está sujeta a la regla de la cesión de derechos y debe hacerse en la carta de pago”.

Los requisitos de la subrogación convencional son los siguientes:

- i. Que un tercero no interesado pague la deuda. Si tuviera interés estaríamos frente al caso de subrogación legal del tercer número del artículo 1610 del CC.
- ii. Que pague sin la voluntad del deudor, porque en caso contrario estaríamos frente al caso de subrogación legal del quinto número del artículo 1610 del CC.
- iii. Que el acreedor pagado subroga voluntariamente en sus derechos al tercero que paga. No todos los que reciben el pago pueden subrogar, sino que es preciso, en caso de mandatario, un poder general de administración y no un mero mandato especial para recibir el pago.

- iv. Que la subrogación se haga en forma expresa. Constituye una excepción a los principios generales porque no se acepta la subrogación tácita. Sin embargo, no se requieren términos sacramentales ni que se precisen los efectos de la subrogación.
- v. Que conste en la carta o recibo de pago. Esto implica que se va a hacer en el momento mismo en que se recibe el pago. Si no se hace en esa oportunidad, no habría acción ni derecho que subrogar pues las que habían se habrían extinguido por el pago. La carta de pago o recibo puede constar en instrumento público o privado pues la ley no exige solemnidad especial.
- vi. Que se sujete a las reglas de la cesión de créditos. Significa que el acreedor tiene que entregar el título de la deuda al tercero que paga y que para que la subrogación sea oponible al deudor y terceros se debe notificar al deudor o éste aceptarla pues se aplica la regla del artículo 1902 del CC. Mientras no se cumpla con estas exigencias si el deudor paga al primitivo acreedor el pago está bien hecho. Significa también que los acreedores del primitivo acreedor pueden embargar ese crédito.

5.5 Efectos de la subrogación.

Los efectos de la subrogación legal o convencional son los mismos y los contiene el artículo 1612 del CC que dispone: **“La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, así contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda. Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos, relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito”**. Por lo tanto, el crédito y la obligación correlativa permanecen igual, con la única salvedad que el lugar que ocupaba antes el acreedor, ahora lo ocupa el tercero que pagó. Lo anterior significa, entre otras cosas, las siguientes:

- i. Que si la obligación era mercantil conserva esa naturaleza.
- ii. Si la obligación estaba caucionada, éstas se mantienen garantizando el mismo crédito que ahora tiene otro acreedor. Ya hemos explicado que se traspasa la hipoteca sin una nueva inscripción.
- iii. Que los títulos ejecutivos a favor del acreedor original se mantienen respecto del tercero que paga que podrá usarlos en su beneficio. Para demandar ejecutivamente acompañará el título y el recibo de pago, que es el documento que lo legitima para demandar. Esta conclusión es discutible pues del sólo título ejecutivo no aparece que el acreedor sea el cesionario y el hecho de que se agregue al título el recibo de pago no soluciona el problema pues se produciría una yuxtaposición de títulos que la jurisprudencia reiteradamente ha rechazado.
- iv. Si la obligación generaba intereses, éstos seguirán devengándose.
- v. Si la obligación estaba sujeta a plazo el tercero que paga no podrá cobrar antes que éste se cumpla.

vi. El tercero que paga queda colocado en la misma situación jurídica del acreedor primitivo, o sea, pasa a tener calidad de contratante lo que tiene gran importancia en los contratos bilaterales pues le permitiría deducir la acción resolutoria en caso de incumplimiento, tal como podría hacerlo el accipiens. Nos asisten dudas de que ello sea así porque lo que se traspasa es el crédito y no el contrato. Sin embargo no se aprecia por qué no podría hacerlo desde que pasa a ocupar su lugar.

Se ha fallado que el tercero que paga a la Caja de Crédito Hipotecario y que se subroga en sus derechos no puede cobrar el interés del 2% mensual que esta institución está autorizada para cobrar porque ciertos derechos y privilegios especiales establecidos por la ley en consideración a la persona del acreedor no pueden cederse, fallo que ha sido objeto de controversia.

En cuanto a los plazos de prescripción, la subrogación no altera los plazos de prescripción que estuvieran corriendo. El plazo se cuenta desde que la obligación se hizo exigible y no desde que opera la subrogación conforme al segundo inciso del artículo 2514 del CC.

El inciso segundo del artículo 1612 del CC se refiere al caso de la subrogación parcial, vale decir, que el tercero pague solo una parte de la obligación, y señala: “Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos, relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito”. O sea, tiene derecho a cobrar el saldo insoluto con preferencia al tercero que pagó parte del crédito. Se ha dicho que este principio emana de la naturaleza misma del pago con subrogación, que es un pago, y no puede ciertamente perjudicar al acreedor.

Tema 6: Dación en Pago.

La dación en pago es un modo de extinguir las obligaciones que no está indicado en el artículo 1567 del CC. Tampoco ha sido reglamentado por la ley, si bien varias disposiciones demuestran que no fue ignorado y menos repudiado. Por ejemplo, el artículo 2382 del CC en la fianza expresa que si el acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del debido queda irrevocablemente extinguida la fianza; el artículo 1773 del CC en la sociedad conyugal; el artículo 2397 del CC en la prenda, etc.

6.1 Concepto.

Las partes contratantes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, pueden convenir que la obligación se extinga pagando el deudor con una cosa distinta de la debida. El inciso segundo del artículo 1569 del CC dispone: El acreedor no podrá ser obligado a recibir otra cosa que la que se le deba, ni aun a pretexto de ser de igual o mayor valor la ofrecida”. Ello demuestra que si bien no puede ser obligado, el acreedor puede consentir en recibir otra cosa que la debida, la que puede ser de igual, mayor o menor valor. Delo anterior se infiere que estando de acuerdo las partes, no es necesario que lo que se da en pago valga exactamente lo mismo que lo adeudado.

6.2 Definición.

Podemos definir la dación en pago como una convención entre acreedor y deudor en virtud de la cual el primero acepta en pago una cosa distinta de la debida. También se la ha definido como un modo de extinguir las obligaciones, que se perfecciona por la entrega voluntaria que un deudor hace a título de pago a su acreedor, y con el consentimiento de éste, de una prestación u objeto distinto del debido. Se agrega que para ello se requiere el consentimiento del deudor, a diferencia del pago efectivo, que puede ser contra su voluntad. La Corte Suprema ha dicho que la dación en pago consiste en una convención acerca de un pago por equivalencia, acordada entre el acreedor y el deudor, y en razón del cual éste extingue su obligación o deuda, entregando una cosa distinta de la debida.

6.3 La dación en pago en una convención, no es un contrato.

La dación en pago es un acuerdo de voluntades destinado a extinguir una obligación. Algunos sostienen que además constituye un verdadero título translativo de dominio, pero otros discrepan de dicha conclusión por los siguientes motivos:

- i. La dación en pago es una convención extintiva y no un contrato. La intención de las partes es extinguir la obligación preexistente.
- ii. La dación en pago requiere consentimiento de las partes pero sólo se perfecciona cuando se entrega la cosa.
- iii. La dación en pago transfiere el dominio, y los títulos translativos de dominio, conforme al artículo 703 del CC, son los que sirven para transferirlo.

6.4 Naturaleza jurídica de la dación en pago.

Existen varias teorías para explicar la naturaleza jurídica de esta institución:

a) La dación en pago es una compraventa seguida de una compensación.

El deudor está vendiendo al acreedor el objeto dado en pago. El precio de esta compraventa, que el acreedor debe pagar al deudor, se compensaría con la obligación que el deudor tenía a favor del acreedor. Por tratarse de una venta el deudor está respondiendo del saneamiento de la cosa vendida, como corresponde a todo vendedor. Se la critica porque es artificiosa. Jamás ha estado en lamente de las partes celebrar un contrato de compraventa. Además limita la dación en pago únicamente a las obligaciones de pagar una suma de dinero, pues el precio de la compraventa debe estipularse necesariamente en dinero. Si fuera una compraventa no podría haberlas entre marido y mujer, lo que contradice al artículo 1763 del CC que justamente establece casos de daciones en pago entre cónyuges.

b) La dación en pago sería una novación objetiva.

Pues se sustituiría una obligación por otra con un objeto distinto. No vemos como puede ser novación porque conforme al artículo 1628 del CC en ella se extingue una obligación pero no nace otra que sustituye a la anterior. En la dación en pago no nace una nueva obligación, simplemente se extingue la única obligación existente. Además la novación requiere animus novandi, que no existe en la dación en pago, en donde el único ánimo es extinguir la obligación con una cosa distinta que la debida. Alessandri defiende esta posición amparándose en los artículos 1645 y 2382 del CC que establecen que la novación liberta a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han accedido a ella. En resumen, si el fiador queda desligado de responsabilidad cuando el deudor principal paga con una cosa distinta a la debida, es porque la obligación que estaba garantizada se extinguió por novación.

c) La dación en pago es simplemente una modalidad del pago.

Se argumenta en base al segundo número del artículo 172 de la LDQ que señala que la dación en pago de efectos de comercio equivale al pago en dinero. La consecuencia de estimarla una modalidad del pago es que se le deben aplicar las normas de éste, salvo las del pago por consignación que definitivamente no tendrían cabida.

d) La dación en pago es una figura autónoma.

Nos parece que decir esto no es solución a ningún problema. Nosotros estimamos que es una modalidad del pago, como lo sugiere su propio nombre, y la consecuencia de ello es que se le deben aplicar las reglas del pago, en la medida que no sea contrario a su propia naturaleza.

6.5 Requisitos de la dación en pago.

Los requisitos de la dación en pago son los siguientes:

- 1) Existencia de una obligación que es la que se va a extinguir, y que puede ser de dar, de hacer o de no hacer.
- 2) La obligación se va a extinguir con una prestación diferente a la debida
- 3) Consentimiento y capacidad de las partes.
- 4) Animus solvendi.
- 5) Solemnidades legales en ciertos casos.

➡ Consentimiento y capacidad de las partes.

En cuanto al consentimiento se aplican las reglas generales de cualquier otra convención. Respecto de la capacidad, para nosotros la dación en pago es una modalidad del pago, lo que nos

podría llevar a afirmar que para ella se requiriera la misma capacidad que se exige para el pago, esto es, capacidad de disposición en quien hace el pago y capacidad de administración en quien lo recibe. Pensamos, sin embargo, que la dación en pago, por implicar para el que recibe, una verdadera renuncia a recibir la prestación debida, requiere de capacidad de disposición. Además, como consecuencia de aplicársele las reglas del pago, si mediante ella se da una cosa el que la da debe ser su dueño, en caso contrario la dación en pago va a ser ineficaz, no nula, esto es, no va a extinguir la obligación.

➡ **Animus solvendi.**

Esto quiere decir que las partes deben tener la intención compartida de extinguir de esta manera la obligación.

➡ **Solemnidades legales en ciertos casos.**

Es un acto jurídico consensual, pues la ley no lo ha sometido a ninguna solemnidad especial. Sin embargo, si lo que se da en pago es un inmueble, deberá hacerse por escritura pública e inscribirse, pues la inscripción es la única manera de realizar la tradición.

6.6 Efectos de la dación en pago.

Produce los mismos efectos del pago, esto es, extinguir la obligación con sus accesorios. Si es parcial, subsistirá en la parte no solucionada.

6.7 Evicción de la cosa dada en pago.

Se estima por la generalidad de la doctrina que el deudor tiene la obligación de garantía, pues ella, a pesar de estar reglamentada en el contrato de compraventa, es de alcance general. En virtud de la obligación de garantía, el acreedor que recibió la cosa evicta podrá demandar las indemnizaciones correspondientes. El problema que se plantea es si además mantendría las acciones de la obligación que se había extinguido por la dación en pago. Estimamos que las mantienen las acciones de la obligación que supuso extinguida, en razón de que el pago fue ineficaz.

6.8 Paralelo entre la dación en pago, las obligaciones facultativas y la novación.

1. Que el deudor se obligue a entregar una cosa determinada quedando facultado al momento de celebrar el contrato para pagar con una cosa diferente que se indica en ese momento, constituye la esencia de una obligación facultativa.
2. Que el deudor se obligue a entregar una cosa al momento del contrato pero que al momento de cumplir su obligación entregue otra que el deudor acepte constituye la esencia de la dación en pago.

3. Que el deudor se obligue a entregar una cosa al momento del contrato, pero que antes del vencimiento de la obligación se acuerde entre las partes que se cambiará la obligación por otra, quedando, por consiguiente, la primera extinguida, constituye la esencia de la novación objetiva por cambio de objeto.

Tema 7: Novación.

7.1 Ideas generales.

Este modo de extinguir las obligaciones está expresamente señalado en el segundo número del artículo 1567 del CC, y está tratado en los artículos 1628 a 1651 del CC. El artículo 1628 del CC define a la novación como: “La sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto extinguida”. Es el nacimiento de una nueva obligación lo que produce la extinción de una anterior.

La novación es una figura híbrida de contrato y convención. Ello es así porque produce el doble efecto de generar una obligación nueva, contrato, y de extinguir una obligación anterior, convención extinguidora de derechos y obligaciones.

7.2 Requisitos de la novación.

Los requisitos de la novación son los siguientes:

- i. Una obligación anterior que es la que se va a extinguir.
- ii. Una obligación nueva que va a reemplazar a la anterior.
- iii. Diferencia esencial entre ambas obligaciones.
- iv. Capacidad de las partes para novar.
- v. Intención de novar o animus novandi.

7.2.1 Una obligación anterior que se va a extinguir.

Esta obligación puede ser civil o natural, pero tiene que cumplir dos requisitos:

- i. Debe ser válida;
- ii. No puede ser condicional suspensiva.

La primera de estas exigencias la establece el artículo 1630 del CC que dispone: “Para que sea válida la novación es necesario que tanto la obligación primitiva como el contrato de novación sean válidos a lo menos naturalmente”. La segunda exigencia está en el artículo 1633 del CC que señala: “Si la antigua obligación es pura y simple y la nueva pende de una condición suspensiva, o si por el contrario, la antigua pende de una condición suspensiva y la nueva es pura, no hay novación, mientras esté pendiente la condición, y si la condición llega a fallar, o si antes del

cumplimiento se extingue la obligación antigua no habrá novación. Con todo, si las partes al celebrar el segundo contrato convienen en que el primero quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente, se estará a la voluntad de las partes.

7.2.2 Una obligación nueva que va a reemplazar a la anterior.

Esta nueva obligación también puede ser civil o natural, y no puede estar sujeta a una condición suspensiva. Sin embargo, respecto de la condición pueden las partes convenir en que el primer contrato quede desde luego abolido, sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente.

7.2.3 Diferencia esencial de ambas obligaciones.



Debe existir diferencia esencial entre ambas obligaciones, lo que va a ocurrir en los siguientes casos: primero, cambio de deudor o acreedor; segundo, cambio del objeto de la prestación; y, tercero, cambio de la causa.

Este requisito aparece establecido en el artículo 1631 del CC que dispone: “La novación puede efectuarse de tres modos: 1° Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor; 2° Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor; y, 3° Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre”.

El mismo CC se ha encargado de precisar en los artículos 1646, 1647, 1648, 1649 y 1650 una serie de casos en que por no haber diferencias esenciales no hay novación y que son los siguientes:

- i. No hay novación si la nueva obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género o cantidad a la primera, conforme al artículo 1646 del CC.
Esta disposición está demostrando que no hay novación pues, de haberla, los codeudores solidarios y subsidiarios habrían quedado liberados pues la obligación se encontraría extinguida.
- ii. No hay novación si la nueva obligación se limita a imponer una pena o a establecer otra para el caso de incumplimiento, conforme al artículo 1647 del CC.
Más si en el caso de infracción es solamente exigible la pena, se entenderá novación desde que el acreedor exige sólo la pena, y quedarán por el mismo hecho extinguidos los privilegios, prendas e hipotecas de la obligación primitiva, y exonerados los que solidaria o subsidiariamente accedieron a la obligación primitiva y no a la estipulación penal.
- iii. No hay novación si sólo se cambia el lugar del pago, conforme al artículo 1648 del CC.
- iv. No hay novación por la sola ampliación del plazo, conforme al artículo 1649 del CC.
La jurisprudencia ha resuelto, sin embargo, que pone fin a la responsabilidad de los fiadores y extingue las prendas e hipotecas constituidas sobre otros bienes del deudor,

salvo que los fiadores o los dueños de las cosas empeñadas o hipotecadas accedan expresamente a la ampliación.

- v. La mera reducción del plazo no constituye novación, conforme al artículo 1650 del CC. Pero no podrá reconvenirse a los codeudores solidarios o subsidiarios sino cuando expire el plazo primitivamente estipulado.
- vi. No produce novación el giro, aceptación o transferencia de una letra de cambio, conforme al artículo 12 de la Ley No. 18.092.
- vii. No produce novación la entrega de un cheque o documentos que no se pagan, conforme al artículo 37 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.
- viii. No constituye novación la circunstancia de que el acreedor acepte abonos a cuenta de su crédito, conforme a la jurisprudencia.
- ix. No producen novación las facilidades dadas por el acreedor, conforme a la jurisprudencia.
- x. No hay novación en reducir a un pagaré un crédito contratado en cuenta corriente, conforme a la jurisprudencia.
- xi. No constituye novación dar en prenda un crédito, conforme a la jurisprudencia.

7.2.4 Capacidad de las partes para novar.

El acreedor requiere tener capacidad de disposición, por cuanto va a extinguir su crédito; en cambio, en el deudor basta la capacidad para obligarse.

Puede la novación acordarse a través de mandatarios. En este caso, podrá novar el mandatario que tiene poder especial para ello, el mandatario que administra un negocio respecto del cual incide la novación y el mandatario con poder general de administración, conforme al artículo 1629 del CC.

7.2.5 Intención de novar o animus novandi.

El artículo 1634 del CC dispone: “Para que haya novación es necesario que lo declaren las partes o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera”. De la disposición se desprende que no es necesario que este ánimo se manifieste en forma expresa ya que basta con que aparezca indudablemente la intención de novar. La excepción a ello la encontramos en el artículo 1635 del CC para la novación por cambio de deudor, pues de acuerdo a esta norma la sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. La forma de expresar esta voluntad no

requiere de términos sacramentales, bastando con que en las declaraciones de las partes quede de manifiesto la intención del acreedor de dar por libre al primitivo deudor.

7.3 Clases de Novación.

Del artículo 1631 del CC se desprende que la novación puede ser de dos clases: **objetiva y subjetiva.**

7.3.1 Novación Objetiva.

Está contemplada en el primer número del artículo 1631 del CC y puede darse en dos casos:

- i. Cuando se cambia la cosa debida, por ejemplo, si debo cien pesos y acordamos reemplazar esa obligación por la de dar una silla.
- ii. Cuando se cambia la causa de la obligación, por ejemplo, si debo cien a título de saldo de precio y la reemplazamos por pagar cien a título de mutuo.

Pudiera parecer que la segunda forma es inocua pues no se divisa utilidad en el cambio. Pero, no es así, pues al producirse la novación y extinguirse con ella la primera obligación, ya no se podrá pedir, en el ejemplo propuesto, la resolución o cumplimiento del contrato de compraventa por no pago del precio, pues la obligación de pagar el precio se encuentra extinguida por novación.

7.3.2 Novación Subjetiva.

La novación subjetiva está contemplada en los números dos y tres del artículo 1631 del CC y puede ser de dos tipos:

Por cambio de acreedor. Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándose en consecuencia libre de la obligación primitiva al primer deudor. Se requiere que las tres partes presten su consentimiento: el deudor porque está contrayendo una nueva obligación a favor del nuevo acreedor; el primer acreedor porque tiene que dar por libre al deudor; y, el nuevo acreedor en razón de que nadie puede adquirir derechos en contra de su voluntad. No tiene mayor utilidad esta forma de novación. Lo que con ella se persigue se puede obtener en forma más simple mediante una cesión de créditos o con un pago con subrogación, que no requieren de la voluntad del deudor.

Por cambio de deudor. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Para que se perfeccione se requiere el consentimiento del acreedor dejando libre al primitivo deudor, pues se le va a cambiar un deudor por otro, hecho que no es intrascendente; y el consentimiento del nuevo deudor pues el pasará a quedar obligado. Si el acreedor no expresa su voluntad de dejar libre al primitivo deudor se entenderá que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con él solidaria o subsidiariamente, según aparezca deducirse del tenor o espíritu del acto en conformidad al artículo 1635 del CC.

El artículo 1631 del CC señala que esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Ello se explica porque esta forma de novación sólo favorece al deudor, pues lo libera de la obligación. Por lo demás, no se ve qué razón podría haber para exigir su consentimiento desde el momento en que el CC acepta que se pueda pagar sin la voluntad del deudor de acuerdo al artículo 1572 del CC. Si el deudor presta su consentimiento el segundo deudor es llamado delegado del primero, conforme al inciso final del artículo 1631 del CC.

De lo que se viene diciendo, resulta que pueden darse dos modalidades en la novación por cambio de deudor: primero, que el deudor primitivo acepte; y, segundo, que el deudor primitivo no acepte. En el primer caso se habla de delegación y en el segundo caso de expromisión. Tanto la delegación como la expromisión pueden ser o no novatorias, dependiendo ello de que quede o no libre el primitivo deudor. En la delegación para que haya novación tiene el acreedor que consentir en dejar libre al primitivo deudor y se llama delegación perfecta conforme al artículo 1635 del CC. Si el acreedor no consiente en dejar libre al primitivo deudor, se produce la delegación imperfecta o acumulativa, que no produce novación. En el caso de la expromisión, para que produzca novación tiene también el acreedor que consentir en dejar libre al primitivo deudor, conforme al artículo 1635 del CC, en caso contrario se produce la llamada ad promission o expromisión acumulativa, que no produce novación.

Si se ha producido novación y el nuevo deudor resulta insolvente, no podrá el acreedor dirigirse en contra del primitivo deudor porque consintió en dejarlo libre, salvo en tres casos señalados en el artículo 1637 del CC:

- i. Que en el contrato de novación el acreedor se haya reservado este derecho.
- ii. Que la insolvencia del nuevo deudor haya sido anterior y pública.
- iii. Que la insolvencia del nuevo deudor, aunque no sea pública, haya sido conocida del deudor primitivo.

En el caso en que el acreedor se haya reservado el derecho de perseguir al primitivo deudor para el caso de insolvencia del nuevo, se ha entendido que al dejar libre al deudor lo ha hecho en forma condicional, pero ello sólo puede hacerse al momento de novar y no con posterioridad. En estos casos de excepción se plantea la duda sobre si la acción que tendría el acreedor sería la misma que tenía en contra del primer deudor o una nueva producida por la novación. Lo que se decida es importante en el caso que la primera gozara de privilegios, hipotecas o cauciones. Se ha entendido que en este caso la acción del acreedor es la misma que tenía contra el deudor primitivo, lo que se infiere de la frase se haya reservado que emplea el artículo 1637 del CC.

7.4 Efectos de la Novación.

El efecto propio de la novación es doble:

- 1) Extinguir la obligación novada.

2) Generar una nueva obligación.

La novación extingue la deuda primitiva con sus privilegios, garantías y accesorios, por lo tanto

- 3) Se extinguen los intereses de la obligación primitiva si no se expresa lo contrario, conforme al artículo 1640 del CC.
- 4) La novación libera a los codeudores solidarios o subsidiarios de la obligación primitiva, a menos que accedan a la nueva obligación, conforme a los artículos 1519 y 1645 del CC.
- 5) Si el deudor estaba constituido en mora, cesa la mora y todas sus consecuencias, o sea, la indemnización de perjuicios.
- 6) Los privilegios de la deuda primitiva no pasan a la nueva, conforme al artículo 1641 del CC. No se hace ninguna referencia a una posible reserva como se hace respecto de las cauciones. La explicación radica en que sólo la ley crea los privilegios, no la voluntad de las partes, lo que ocurriría si se aceptase la reserva en esta materia.
- 7) Las prendas e hipotecas de la obligación primitiva no pasan a la obligación nueva, a menos que el acreedor y el deudor convengan expresamente en la reserva conforme al artículo 1642 del CC.

7.4.1 Límites a la reserva de prendas e hipotecas.

- i. La reserva no puede afectar a las garantías constituidas por terceros, a menos que accedan expresamente a la segunda obligación de conformidad con el segundo inciso del artículo 1642 del CC.
- ii. Tampoco vale la reserva en lo que la segunda obligación tenga de más que la primera, por ejemplo, si la primera deuda no producía intereses y la segunda los produce, conforme al inciso final del artículo 1642 del CC.
- iii. Si la novación opera por la sustitución de un nuevo deudor, la reserva no puede tener efecto sobre los bienes del nuevo deudor, ni aun con su consentimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el primer inciso del artículo 1643 del CC.
- iv. Si la novación se opera entre el acreedor y uno de sus deudores solidarios, la reserva no puede tener efecto sino relativamente a éste. Las prendas e hipotecas constituidas por sus codeudores solidarios se extinguen a pesar de toda estipulación contraria, salvo que éstos accedan expresamente a la segunda obligación, conforme lo señalado en el segundo inciso del artículo 1643 del CC.

7.4.2 Las partes pueden convenir garantías para la nueva obligación.

El artículo 1644 del CC dispone: “En los casos y cuantía en que no pueda tener efecto la reserva, podrán renovarse las prendas e hipotecas, pero con las mismas formalidades que si se constituyesen por primera vez, y su fecha será la que corresponda a la renovación”. Esta norma nos parece absolutamente de más, pues es evidente que las partes en virtud del principio de la autonomía de la voluntad pueden establecer estas nuevas cauciones.

Tema 8: Imposibilidad de la Ejecución y Pérdida de la Cosa Debida.



El séptimo número del artículo 1567 del CC contempla la pérdida de la cosa que se debe como una de las formas de extinguir las obligaciones. Los artículos 1670 y siguientes del CC reglan esta materia.

8.1 Definición.

Se define diciendo que es un modo de extinguir las obligaciones provocadas por una causa no imputable al deudor, que sucede con posterioridad al nacimiento de la obligación y que hace imposible la prestación. El principio es que no hay obligación alguna de cosas imposibles. No obstante que este principio es general tanto para las obligaciones de dar, hacer o no hacer, en los artículos 1670 y siguientes del CC sólo se trata de las obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto, seguramente por ser la situación más frecuente. El artículo 1670 del CC dispone: “Cuando el cuerpo cierto que se deba perecer, o porque se destruye o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe, se extingue la obligación, salvo empero las excepciones de los artículos subsiguientes”.

8.2 Requisitos de este modo de extinguir tratándose de las obligaciones de dar o entregar una especie o cuerpo cierto.

Los requisitos son los siguientes:

Imposibilidad absoluta y definitiva de poder cumplir la obligación. El deudor debe estar absoluta y definitivamente imposibilitado de cumplir. Tratándose de las obligaciones de dar o entregar, ello sólo puede ocurrir cuando lo debido es una especie o cuerpo cierto, porque el género no perece conforme al artículo 1510 del CC que señala: “La pérdida de algunas cosas del género no extingue la obligación y el acreedor no puede oponerse a que el deudor las enajene o destruya, mientras subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe”.

Que la imposibilidad sea fortuita. La pérdida debe ser fortuita pues si es culpable o si la cosa perece por culpa del deudor la obligación subsiste pero varía de objeto, quedando en deudor obligado al pago del precio de la cosa más indemnización de perjuicios conforme al artículo 1672 del CC. Si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortuito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, sólo se deberá la indemnización de los perjuicios por la mora, de acuerdo al segundo inciso del artículo 1672 del CC. El CC presume que la pérdida de la cosa es culpable, pues el artículo 1671 señala: “Siempre que la cosa perece en poder del deudor se presume que ha sido por hecho o culpa suya”. Esta disposición es concordante con el artículo 1674 del CC en cuanto esta norma obliga al deudor a probar el caso fortuito que alega, y para el caso que alegue que un caso fortuito habría sobrevenido del mismo

modo aunque no estuviere en mora, será también obligado a probarlo. En todo caso, no se aplican estas reglas si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de algunos en particular, caso en que se observará lo pactado conforme al artículo 1673 del CC. El CC no acepta que quien ha hurtado o robado un cuerpo cierto alegue que la cosa ha perecido por caso fortuito, aun de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del deudor, conforme al artículo 1676 del CC.

Que la imposibilidad sea posterior al nacimiento de la obligación. Si es anterior, tal obligación carecería de objeto o tendría un objeto imposible de acuerdo al artículo 1461 del CC.

8.3 Cesión de acciones del deudor al acreedor.

El artículo 1677 del CC dispone: “Aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor, podrá exigir al acreedor que se le cedan los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa”.

8.4 En el hecho o culpa del deudor se comprende el de las personas por quienes fuere responsable.

Así lo establece el artículo 1679 del CC. Debe entenderse que el deudor es responsable de las personas que están a su cuidado, principio contenido en el primer inciso del artículo 2320 del CC.

8.5 Responsabilidad del deudor después que ha ofrecido la cosa al acreedor.

Si la cosa se destruye en poder del deudor después que ha sido ofrecida al acreedor y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino por culpa grave o dolo conforme al artículo 1680 del CC.

8.6 Requisitos de este modo de extinguir en las obligaciones de hacer.

El CC no trató el tema. El artículo 534 del CPC dispone que, además de las excepciones mencionadas en el artículo 464, se podrá oponer la excepción de la imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra debida.

8.7 Requisitos de este modo de extinguir en las obligaciones de no hacer.

En una obligación de no hacer el deudor la incumple cuando realiza aquello sobre lo que debía abstenerse. El acreedor tiene derecho a que se exija que el deudor deshaga lo hecho, siempre que en conformidad al artículo 1555 del CC sea posible deshacerlo hecho y que la destrucción sea necesaria para el objeto que se tuvo en vista al contratar. En tal caso, el deudor puede oponer la excepción del artículo 534 del CPC: imposibilidad absoluta de deshacer lo hecho.

Tema 9: De la Prescripción.

El número diez del artículo 1567 del CC señala a la prescripción como un modo de extinguir las obligaciones. Está tratada en los artículos 2492 a 2524 del CC.

Como es sabido, la prescripción puede ser de dos clases: prescripción adquisitiva o usucapion, que es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales; y, la prescripción extintiva o liberatoria, que es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos.

9.1 Definición.

El artículo 2492 del CC define en forma conjunta a la prescripción adquisitiva y extintiva, disponiendo: “La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción”. De esta definición extraemos que la prescripción extintiva es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

La prescripción sólo extingue la acción, no el derecho ni la obligación correlativa. Lo que se extingue con la prescripción es la acción para reclamar el derecho, no el derecho mismo ni la obligación correlativa, porque de conformidad al segundo número del artículo 1470 del CC, las obligaciones civiles extinguidas por prescripción pasan a transformarse en naturales.



9.2 Paralelo entre prescripción adquisitiva y extintiva.

La prescripción adquisitiva es un modo de adquirir el dominio y los demás derechos reales; en cambio, la extintiva, es un modo de extinguir las acciones de los derechos ajenos. Otra diferencia importante es que en la prescripción adquisitiva la posesión es un requisito sine qua non; en cambio, la posesión no juega ningún rol respecto de la prescripción extintiva. No obstante ambas prescripciones cumplen funciones distintas, tienen en común algunos elementos: primero, la inactividad de una parte; y, segundo, ambas cumplen la función de dar estabilidad a los derechos y relaciones jurídicas, lo que explica que haya reglas comunes a ambas prescripciones, como los artículos 2493, 2494 y 2497 del CC.

9.3 Requisitos de la prescripción extintiva.

Los requisitos de la prescripción extintiva son los siguientes:

- Reglas comunes a toda prescripción.
- Acción prescriptible.
- Inactividad de las partes.
- Tiempo de prescripción.

9.3.1. Reglas comunes a toda prescripción.

Elas operan tanto respecto de la prescripción adquisitiva como de la extintiva. Son las siguientes:

a) Toda prescripción debe ser alegada. El artículo 2493 del CC dispone: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, el juez no puede declararla de oficio”. Ello es así por imperar en materia procesal civil el principio de la pasividad de los tribunales, consagrado en el artículo 10 del COT. Las razones que justifican que la prescripción deba ser alegada son, en primer lugar, el deudor debe probar en juicio que se encuentran cumplidos los requisitos de la prescripción. En seguida, porque es necesario dar al hacedor la oportunidad procesal para que pueda renunciar a la prescripción. En el caso de los comuneros se ha fallado que si la prescripción es alegada por uno de los comuneros demandados, falla ultra petita la sentencia que la acoge a favor de todos.



¿Cómo se alega la prescripción?

La prescripción adquisitiva sólo puede alegarse como acción, mediante la reconvención. La prescripción extintiva, en cambio, puede alegarse como acción y como excepción. Como excepción lo dice expresamente el artículo 310 del CPC, debiendo recordarse que es una de las excepciones que se pueden plantear en cualquier estado de la causa, pero no se admitirán si no se alegan por escrito antes de la citación para oír sentencia en primera instancia, o de la vista de la causa en segunda instancia. En el caso del juicio ejecutivo, la situación es distinta pues la prescripción extintiva, sea de la deuda o de la acción ejecutiva, sólo puede oponerse en el escrito de excepciones. Se ha discutido por algunos si la prescripción extintiva se puede alegar por vía de acción. El principio es que si hay interés hay acción. Por ello, al tener el deudor interés en ser librado de su obligación, nos parece incuestionable que pueda alegar la prescripción extintiva como acción, y así por lo demás lo ha entendido la doctrina.

La prescripción debe ser alegada con precisión. La alegación de la prescripción no puede ser hecha en términos generales, sino que el deudor debe expresar de un modo preciso el tiempo desde cuando el plazo de prescripción ha empezado a correr.

Excepciones a la regla de que toda prescripción debe ser alegada. Hay algunos casos en que no es necesario alegar la prescripción, debiendo el tribunal declararla de oficio. Ello ocurre en las siguientes situaciones:

- i. En la prescripción de la acción ejecutiva, pues el artículo 441 del CPC obliga al tribunal a examinar el título ejecutivo y el artículo siguiente señala que el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de tres años desde que la obligación se haya hecho exigible.
- ii. La prescripción de la acción penal y de la pena, conforme al artículo 102 del CP.

b) Toda prescripción puede ser renunciada una vez cumplida. Así lo establece el primer inciso del artículo 2494 del CC. Se explica la exigencia pues de hacerse antes del vencimiento del plazo la actitud del acreedor importaría una interrupción natural de la prescripción, conforme al segundo inciso del artículo 2518 del CC. Además, si se aceptare la renuncia en forma anticipada pasaría a ser cláusula de estilo en todos los contratos, con lo que se perdería el efecto estabilizador de derechos que persigue la prescripción.

La renuncia puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se hace en términos formales y explícitos; y, es tácita cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. La Corte Suprema ha dicho que la renuncia de una prescripción importa una manifestación inequívoca y unilateral de voluntad en orden a abandonar la facultad de pedir que se declare extinguido por la prescripción el derecho que otro tiene, manifestación de voluntad que debe hacerse sin compensación, por mera liberalidad o moralidad; la transacción tiene una naturaleza jurídica distinta de la renuncia de la prescripción. También se ha fallado que el reconocimiento de firma no importa renuncia a la prescripción. La confesión de deuda comporta un reconocimiento del crédito y, por lo tanto, implica renuncia a la prescripción; mientras el reconocimiento de firma sólo confiere autenticidad al instrumento, pero nada agrega en relación con el crédito, de modo que no impide oponer con éxito la excepción de prescripción. La renuncia sólo puede hacerse antes de alegar la prescripción. Con posterioridad, sólo cabe el desistimiento de la prescripción.

Capacidad para renunciar la prescripción. El artículo 2495 del CC dispone: “No puede renunciar la prescripción sino el que puede enajenar”.

Efectos de la renuncia. La renuncia de la prescripción es de efectos relativos, sólo afecta al que la hace. Luego, no alcanza a los terceros obligados. El artículo 2496 del CC señala: “El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor”. No obstante los términos limitativos de la norma, que hacen referencia únicamente a los fiadores, es obvio que el principio tiene alcances más amplios, habiéndose fallado que el tercer poseedor de la finca hipotecada puede oponer prescripción aunque la haya renunciado el deudor principal.

c) Corre por igual en contra de toda clase de personas. Así lo establece el artículo 2497 del CC. Esta norma tiene más bien una explicación histórica. Antiguamente se establecían plazos distintos para prescribir, considerando la calidad de las personas. A nuestro juicio, esta regla tiene hoy día respaldo constitucional, ya que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias, conforme al inciso final del segundo número del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Excepciones a las reglas de la igualdad. La parte final del artículo 2497 del CC deja en claro que la regla de la igualdad se aplica a los particulares que tienen la libre disposición de lo suyo. Lo anterior está dicho para compatibilizar esta disposición con la institución de la suspensión de la prescripción del artículo 2509 del CC, pues ésta implica que respecto de ciertas personas los plazos de prescripción se prolonguen. Otra excepción la da el artículo 100 del CP al establecer que el reo que se fugue del territorio de la República solo podrá prescribir la acción penal o la pena contando un día por cada dos de ausencia.

9.3.2 Acción prescriptible.

La regla es que toda acción se prescriptible. Sin embargo, y por razones superiores, se establecen algunas excepciones:

- i. La acción de partición del artículo 1317 del CC.
- ii. La acción para reclamar el estado civil de hijo o de padres conforme al artículo 320 del CC.
- iii. La acción de demarcación o cerramiento por tratarse de una manifestación del derecho de dominio que no se extingue por el no uso.

9.3.3 Inactividad de las partes.

Con más exactitud, el acreedor no debe haber requerido judicialmente a su deudor exigiéndole el cumplimiento de la obligación. De manera que la prescripción extintiva viene a ser una especie de sanción para el acreedor indolente que deja pasar periodos prolongados, sin hacer efectivos sus créditos. Pero no basta con la inactividad del acreedor. También el deudor tiene que haber mantenido una actitud pasiva pues, en caso contrario, se produce una interrupción natural que obsta a la prescripción.

a) Interrupción de la prescripción extintiva.

El artículo 2518 del CC dispone: “La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya naturalmente, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresamente, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente, por la demanda judicial, salvo en los casos enumerados en el artículo 2503 del CC”. Podemos decir entonces que la interrupción es el hecho impeditivo de la prescripción que se produce al cesar la inactividad del acreedor o del deudor. En el primer caso la interrupción será civil y en el segundo caso, natural.

➡ Interrupción natural.

Se produce por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente, conforme al segundo inciso del artículo 2518 del CC. La norma es bastante amplia por lo que queda comprendido cualquier acto que suponga reconocimiento de la deuda, por ejemplo, pedir prórrogas, abonos, etc. Este reconocimiento del deudor tiene que hacerse mientras el plazo de prescripción está pendiente, pues, en caso contrario, esa actitud constituye renuncia tácita a la prescripción conforme al segundo inciso del artículo 2494 del CC.

➡ Interrupción civil.

El tercer inciso del artículo 2518 del CC dispone que se interrumpe civilmente la prescripción por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503 del CC. Relacionando los artículos 2503 y 2518 del CC se tiene que para que haya interrupción civil deben cumplirse los siguientes requisitos:

Demanda judicial. La Corte Suprema ha dicho que la interrupción civil no deriva tanto de la demanda que la origina como de la sentencia que acoge esa demanda. En todo caso, esclaro que ningún requerimiento privado es suficiente para interrumpir la prescripción. El problema radica en determinar si cualquier gestión judicial es suficiente para interrumpir la prescripción, o si, por el contrario, tiene que tratarse de la contemplada en el artículo 254 del CPC, destinada a hacer cumplir la obligación. La jurisprudencia de los últimos años está por el sentido amplio. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que para que la demanda interrumpa la prescripción debe existir una conexión directa entre la acción ejercida y la acción de cuya extinción prescriptiva se trata. Se ha fallado en forma reiterada que la demanda presentada ante tribunal incompetente interrumpe la prescripción, lo que parece atendible desde que desaparece la situación de pasividad del acreedor que es el supuesto de la prescripción extintiva. Se ha fallado también que si un ejecutante ejerce la acción de cobro que emana de un pagaré y no la que emana de la hipoteca, se debe aplicar en materia de prescripción las normas del artículo 100 de la Ley No. 18.092, por lo que debe acogerse la excepción de prescripción si ha transcurrido más de un año entre el vencimiento y la notificación de la demanda.

Notificación de la demanda. Para que opere la interrupción no basta la presentación de la demanda sino que es necesario que ésta se encuentre legalmente notificada. Tradicionalmente se ha entendido que para que opere la interrupción la demanda tiene que notificarse antes del vencimiento del plazo de prescripción, por aplicación del primer número del artículo 2503 del CC. Se ha fallado que la interrupción civil de la prescripción se cuenta desde la presentación de la demanda o del recurso judicial, y si bien sin su notificación ella carece de significado procesal, una vez efectuada la notificación ella se retrotrae en sus efectos a la fecha de la presentación de aquélla. Sin la respectiva notificación la sola presentación de la demanda carecería de significación en lo procesal, los efectos de esa notificación se retrotraerán necesariamente y sin embargo a la fecha de la presentación de la demanda una vez realizado el trámite. Sin embargo este fallo merece críticas, porque si conforme al artículo 2503 del CC no hay interrupción de la prescripción cuando la demanda no ha sido hecha en forma legal, no se divisa de qué manera y bajo que artificio interpretativo se podría llegar a afirmar que la falta completa de la notificación es capaz de producir más consecuencias jurídicas que una notificación imperfectamente realizada.

Que no se haya producido alguna de las situaciones contempladas en el artículo 2503 del CC, o sea, abandono del procedimiento, desistimiento de la demanda o sentencia absolutoria. No obstante haberse demandado con oportunidad, no se produce la interrupción civil en los siguientes casos:

- i. Cuando la demanda no ha sido notificada en forma legal conforme al primer número del artículo 2503 del CC.
- ii. Cuando el actor se ha desistido de su demanda conforme al segundo número del artículo 2503 del CC.
- iii. Cuando se ha producido abandono del procedimiento conforme al segundo número del artículo 2503 del CC.
- iv. Cuando el demandado obtuvo sentencia absolutoria conforme al tercer número del artículo 2503 del CC. Sobre este punto, se ha fallado que no constituye sentencia absolutoria la que rechaza la demanda ejecutiva por faltar la ejecutividad del título. También se ha resuelto que la sentencia que declara la incompetencia del tribunal no es absolutoria y, por lo tanto, ha operado la interrupción de la prescripción.

b) Efectos de la interrupción.

El efecto de la interrupción civil o natural es hacer perder todo el tiempo anterior. Favorece, en consecuencia, al acreedor y perjudica al deudor. La regla es que los efectos son relativos, pues si es civil supone un juicio que sólo afecta a las partes litigantes; y si es natural, importan una manifestación de voluntad, expresa o tácita, que sólo produce efectos para quien la hace. Esta regla está consagrada en la primera parte del artículo 2519 del CC que dispone: “La interrupción que obra a favor de uno o varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno o varios codeudores, perjudica a los otros”. Esta regla, sin embargo, tiene las siguientes excepciones:

- i. En el caso de la solidaridad; como lo consigna la parte final del artículo 2519 del CC al señalar: “...a menos que haya solidaridad y ésta no se haya renunciado”. Una excepción a esta regla se encuentra en el artículo 100 de la Ley No. 18.092 sobre letras de cambio, pues no obstante que todos los obligados al pago se encuentran obligados solidariamente, la prescripción se interrumpe sólo respecto del obligado a quien se notifique la demanda judicial de cobro de la letra, o la gestión judicial necesaria o conducente para deducir dicha demanda o preparar la ejecución.
- ii. Cuando las obligaciones son indivisibles; el artículo 1529 del CC dispone: “La prescripción interrumpida respecto de uno de los deudores de la obligación indivisible lo es igualmente respecto de los otros”. Al respecto se ha fallado que tratándose de la obligación de suscribir un contrato de compraventa, obligación de hacer generada de un contrato de promesa, la notificación a un comunero interrumpe la prescripción respecto de todos, por tratarse de una obligación indivisible.

La interrupción de la prescripción de la obligación principal interrumpe la prescripción de la obligación accesoria. Si aplicamos la regla general de que la interrupción es de efectos relativos, habría que entender que sólo afectaría al deudor principal, pero no a los terceros interesados, conclusión que repugna con el principio accesorio de toda caución. Las acciones accesorias, como la que tiene el acreedor contra el tercer poseedor de la finca hipotecada o contra el fiador, no tiene un plazo propio de prescripción, sino que corren la suerte de la principal, de donde se sigue que,

interrumpida la prescripción de ésta última, el acto interruptivo es oponible al tercer poseedor y al fiador en su caso, quienes no pueden alegar la prescripción. A la inversa, la interrupción de la prescripción de la acción accesoria no afecta a la prescripción de la acción principal, pudiendo oponer esta última el deudor al acreedor demandante.

9.3.4 Tiempo de prescripción.

Es importante tener presente que en toda prescripción extintiva el tiempo se cuenta desde que la obligación se haya hecho exigible, conforme al segundo inciso del artículo 2514 del CC.

En relación con este requisito, que es el más característico de la prescripción extintiva, debemos distinguir entre:

a) Prescripciones de largo tiempo.

- i. **Prescripciones de acciones personales ordinarias.** La prescripción de las acciones personales ordinarias es de cinco años contados desde que la obligación se ha hecho exigible, conforme al artículo 2515 del CC.
- ii. **Prescripciones de acciones ejecutivas.** La prescripción de la acción ejecutiva es de tres años desde que la obligación se haya hecho exigible, conforme al artículo 2515 del CC. Esta regla tiene algunas excepciones en que la ley ha fijado plazos especiales como ocurre, por ejemplo, con el cheque protestado en que la acción contra los obligados prescribe en un año desde la fecha del protesto. Respecto de la prescripción de la acción ejecutiva, cabe tener presente lo siguiente:
 - Que transcurridos tres años la acción ejecutiva se transforma en ordinaria por dos años más en conformidad al artículo 2515 del CC.
 - Que puede ser declarada de oficio conforme al artículo 442 del CPC, lo que ha hecho que un sector de la doctrina afirme que se trata de un caso de caducidad más que de prescripción.
 - Que el solo reconocimiento por el deudor de la vigencia de la deuda no importa renuncia de la prescripción de la acción ejecutiva.
- iii. **Prescripción de acciones cambiarias.** Se entiende por acciones cambiarias aquellas emanadas de la letra de cambio o del pagaré, que se estiman diversas e independientes de las acciones extracambiarias o derivadas del negocio causal. El artículo 98 de la Ley No. 18.092 señala: “El plazo de prescripción de las acciones cambiarias del portador contra los obligados al pago es de un año, contado desde el día del vencimiento del documento”. Hace excepción a esta regla las acciones de reembolso de que trata el artículo 82 de la misma ley, que prescriben en seis meses contados desde el día del pago cuyo reembolso se reclama. Se ha resuelto que como en la prescripción de las acciones cambiarias la ley no distingue entre la acción ejecutiva y la ordinaria, debe entenderse que el plazo de prescripción de ambas es de un año.
- iv. **Prescripciones de obligaciones accesorias.** El artículo 2516 del CC dispone: “La acción hipotecaria, y las demás que procedan de una obligación accesoria, prescriben junto con la

obligación principal a que acceden”. Luego, las acciones provenientes de las cauciones reales o personales no tienen un plazo propio de prescripción, sino que, en virtud del principio de lo accesorio, prescriben junto con la obligación principal que garantizan.

- v. **Prescripciones de acciones reales de dominio y herencia.** El artículo 2517 del CC dispone: “Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho”. Ello explica que la acción reivindicatoria no tenga un plazo de prescripción, pudiendo interponerse mientras se sea dueño de la cosa. Por la misma razón, la acción de petición de herencia va a prescribir en el plazo de diez o cinco años, que son los plazos de prescripción adquisitiva del derecho de herencia.
- vi. **Prescripciones reales provenientes de las limitaciones del dominio.** Debe distinguirse entre los derechos de usufructo, uso y habitación, por un lado, y derecho de servidumbre, por otro. En el caso del usufructo deben diferenciarse dos situaciones:
 - i. La acción para reclamar el derecho de usufructo poseído por un tercero, se podrá intentar en cualquier tiempo mientras este tercero no haya adquirido el usufructo por prescripción adquisitiva de acuerdo al artículo 2517 del CC.
 - ii. El cuadro se complica en el caso que el usufructuario no reclame su derecho al nudo propietario, porque el artículo 806 del CC dispone que el usufructo se extingue también por prescripción. Claro Solar estima que cuando el usufructuario no reclama su derecho de usufructo al nudo propietario, su derecho se extingue por prescripción adquisitiva. Alessandri estima que para que prescriba el derecho de usufructo no basta el simple no uso, pues las acciones para reclamar un derecho se extinguen por la prescripción adquisitiva del mismo derecho conforme al artículo 2517 del CC, y, además, dentro de las concepciones de nuestro CC el usufructuario tiene el derecho de dominio sobre su usufructo, dominio que no se pierde mientras otra persona no lo haya ganado por prescripción adquisitiva.Lo que acabamos de decir del derecho de usufructo es aplicable también a los derechos de uso y habitación, atendiendo lo dispuesto en el artículo 812 del CC. Finalmente, en el caso de las servidumbres, si el titular las deja de gozar por tres años, se produce prescripción extintiva de acuerdo al quinto número del artículo 885 del CC.
- vii. **Suspensión de la prescripción extintiva de largo tiempo.** La suspensión de la prescripción es un beneficio especial que la ley otorga a ciertas personas, las enumeradas en el artículo 2509 del CC, de que no corra el plazo de prescripción en su contra. El artículo 2520 del CC establece que la prescripción que extingue las obligaciones se suspende a favor de las personas enumeradas en el artículo 2509 del CC, pero que transcurridos diez años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas. Esta suspensión se aplica a la prescripción ordinaria y extraordinaria, pero no a la ejecutiva.

b) Prescripciones de corto tiempo.

Están tratadas en los artículos 2521 a 2524 del CC. Se trata de casos especiales que constituyen excepciones a la regla de prescripción del artículo 2515 del CC, y se clasifican en:

i. **Prescripciones de tres años.** El primer inciso del artículo 2521 del CC dispone: “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”.

ii. **Prescripciones de dos años.** El inciso segundo del artículo 2521 del CC dispone: “Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores, los de médicos y cirujanos, los de directores o profesores de colegios y escuelas, los de ingenieros y agrimensores y, en general, de los que ejercen cualquier profesión liberal”. Se refiere a honorarios profesionales por lo que si el profesional tiene un contrato de trabajo no rigen estas normas sino las de la legislación laboral. Como sabemos, la prescripción comienza a correr desde que la obligación de pagar los honorarios e ha hecho exigible.

iii. **Prescripciones de un año.** El artículo 2522 del CC dispone: “Prescriben en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc.”. Las actividades que se señalan no son taxativas sino que lo importante para que tenga aplicación es que se trate de servicios accidentales o que se prestan en forma periódica.

Las prescripciones de corto tiempo de los artículos 2521 y 2522 del CC no se suspenden. Así lo señala el artículo 2523 del CC al disponer que corran contra toda clase de personas y que no admitan suspensión alguna.

Intervención de las prescripciones de corto tiempo. El artículo 2523 del CC establece que estas prescripciones de corto tiempo se interrumpen:

- i. Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor.
- ii. Desde que interviene el requerimiento.

El efecto que produce esta interrupción es que en ambos casos sucede a la prescripción de corto tiempo la del artículo 2515 del CC, y es lo que, en doctrina, se denomina Intervención de la prescripción.

c) Prescripciones especiales. El artículo 2524 del CC dispone: “Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se señale otra regla”. Respecto de estas prescripciones especiales debe tenerse presente lo siguiente:

- i. Que son prescripciones de corto tiempo, o sea, de menos de cinco años.
- ii. Que corren contra toda persona, o sea, no se suspende, salvo situaciones especiales.

iii. Que no se aplican respecto de ellas las reglas especiales de prescripción contempladas en el artículo 2523 del CC.

c) Cláusulas modificatorias de los plazos de prescripción.

La pregunta que cabe formular es si la partes contratantes pueden modificar los plazos de prescripción, aumentándolos o acortándolos. Se estima que las partes no pueden ampliar los plazos de prescripción, pero pueden acortarlos. No los pueden ampliar pues ello sería contrario al orden público, ya que el interés social hace necesario que las relaciones jurídicas se establezcan en plazos que no pueden quedar entregados al arbitrio de los contratantes. Este argumento no juega para el caso contrario, o sea, reducir los plazos, y, por ello, no se ve inconveniente en que ello pueda realizarse. Se da como argumento que el propio CC deja entregado a la voluntad de las partes la reducción de los plazos de prescripción, como ocurre en la prescripción del pacto comisorio del artículo 1880 del CC y del pacto de retroventa del artículo 1885 del CC. Este argumento, sin embargo, aparece débil toda vez que el CC también en un caso consagrado en el artículo 1866 del CC permite a las partes ampliar o restringir el plazo de prescripción de la acción redhibitoria.

Se señala que el problema de los plazos de prescripción puede ser presentado como un conflicto entre dos intereses privados, el del deudor y el del acreedor, o bien entre dos intereses de orden público: no prolongar la incertidumbre sobre el ejercicio de los derechos y no coartar ese ejercicio más allá de lo razonable. Los plazos de prescripción son la solución legal de ese conflicto, marcan el justo medio. Todo acortamiento o prolongación afecta el equilibrio del sistema y debe ser repudiado. En general, la tendencia de la legislación comparada es a no permitir las cláusulas modificatorias de los plazos de prescripción.

9.4 Prescripción y caducidad.

Guardan semejanza en cuanto en ambas se produce la pérdida de un derecho como consecuencia de la inactividad de su titular durante un determinado plazo. Pero claramente se trata de dos instituciones diferentes. La caducidad abarca todos aquellos plazos legales por cuyo transcurso se produce la extinción de un derecho, de una manera diversa y más enérgica que si estuvieran sometidos a prescripción común. La caducidad de un derecho significa que el legislador ha señalado un término fatal, sin atender a lo que haga el obligado; la existencia del derecho está limitada desde un principio a un plazo prescrito de antemano. La caducidad es la pérdida de la facultad de hacer valer un derecho como consecuencia de la expiración de un plazo fatal. Lo que da fisonomía a la caducidad es la circunstancia de tratarse de un plazo fatal, generalmente breve, dentro del cual si el derecho no se ejerce se extingue de pleno derecho. Se trata de derechos que se extinguen irremediabilmente si no se ejercen dentro del plazo fatal fijado por la ley.

9.4.1 Caducidad en el Código Civil.

No está especialmente regulada y, desde luego, no figura en la enumeración del artículo 1567 del CC. Sin embargo, el CC contempla casos de acciones que caducan y no prescriben como ocurre,

por ejemplo, con los plazos para impugnar la paternidad de los artículos 212, 214, 216, 217 y 218 del CC; y en los testamentos privilegiados de los artículos 1044, 1046 y 1053 del CC.

9.4.2. Diferencias entre prescripción y caducidad.

Las principales diferencias que señala la doctrina son las siguientes:

- i. La prescripción debe ser alegada, conforme al artículo 2493 del CC; la caducidad, en cambio, opera por el solo vencimiento del plazo.
- ii. Los plazos de caducidad son fijos e invariables. No operan a su respecto las instituciones de la interrupción y suspensión de la prescripción. Consecuencia del anterior es que cuando se invoca un derecho sujeto a caducidad basta, para que la caducidad no se produzca, que la demanda se presente al tribunal dentro del plazo aun cuando la notificación se realice posteriormente. En el caso de la prescripción la situación es diferente, porque es la notificación de la demanda la que interrumpe civilmente la prescripción de acuerdo al artículo 2503 del CC.
- iii. La prescripción, según hemos visto, no extingue el derecho personal o crédito. Únicamente pone fin a la acción para demandarlo; y las obligaciones civiles prescritas se transforman en naturales. En el caso de la caducidad, es el derecho mismo el que se extingue.
- iv. La prescripción es renunciable conforme lo dispuesto en el artículo 2494 del CC. La caducidad no lo es, porque no está en juego sólo el interés de las partes sino que hay razones de orden público que hacen necesario consolidar los derechos en forma definitiva.